
RODRIGO VALGAS DOS SANTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO

MARÇAL JUSTEN FILHO | PREFÁCIO
RUY SAMUEL ESPÍNDOLA | APRESENTAÇÃO

Confira vídeo
exclusivo de
apresentação da obra:



THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS**

RODRIGO VALGAS DOS SANTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO

*Risco e fuga da responsabilização
dos agentes públicos*

THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS

Sumário

Agradecimentos	7
Apresentação	13
Prefácio	17
Lista de Abreviaturas e Siglas	21
Introdução	31
Capítulo 1 — Separação de poderes: origem, crise e novos arranjos institucionais	55
1.1. Separação de poderes e formação do direito administrativo	58
1.2. O problema do ativismo judicial e o desequilíbrio da balança dos poderes	67
1.3. O conflito entre política e burocracia na separação de poderes	83
1.4. Novos arranjos institucionais na teoria da divisão dos poderes: órgãos constitucionais e ascensão dos não eleitos	92
1.5. Conclusões acerca dos novos arranjos institucionais	111
Capítulo 2 — Disfunções do controle externo decorrentes da interpretação e da aplicação do direito no Brasil	119
2.1. Conceito operacional de disfunção	121
2.2. Fundamentos ideológicos do controle externo capazes de produzir disfuncionalidades	127

2.3. Influxos do decisionismo e do protagonismo judicial na interpretação e na aplicação do direito no Brasil.....	137
2.4. Os problemas na aplicação da teoria dos princípios no Brasil e suas conexões com o controle externo.....	146
2.5. Conclusões acerca das premissas ideológicas do controle externo.....	156
Capítulo 3 – A casuística disfuncional nas ações de improbidade, tribunais de contas e justiça eleitoral.....	159
3.1. Considerações iniciais.....	162
3.2. As disfunções nas ações de improbidade.....	163
3.2.1. Conceito de Improbidade Administrativa na Lei 8.429/1992 a partir da Constituição da República.....	169
3.2.2. Os principais problemas na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa – LIA.....	174
3.2.2.1. Os tipos abertos da Lei de Improbidade Administrativa.....	174
3.2.2.2. Dolo e culpa nas ações de Improbidade Administrativa.....	177
3.2.2.3. Falta de critérios adequados para dosimetria das suas sanções.....	180
3.2.3. Números impressionantes: a incrível quantidade de ações de improbidade aforadas no Brasil.....	184
3.2.4. Casos que demonstram como é fácil ser ímprobo no Brasil.....	187
3.2.4.1. O caso do prefeito dançarino da cidade de Capela do Alto Alegre.....	189
3.2.4.2. O caso das fotos oficiais de prefeito em órgãos do município....	190
3.2.4.3. Casos de aplicação do dano <i>in re ipsa</i> pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.....	191
3.2.4.4. O caso de condenação por cegueira deliberada.....	193
3.2.4.5. O Caso do Prefeito condenado por adotar o lema: “SP cidade linda”.....	194

3.2.4.6. O Caso de improbidade por uso de 14 folhas de papel timbrado.....	195
3.3. As disfunções nos tribunais de contas.....	196
3.3.1. Considerações acerca da composição dos tribunais de contas no Brasil e seus reflexos no controle externo.....	196
3.3.2. As presunções de responsabilidade civil dos ordenadores primários, autoridades ou responsáveis nos tribunais de contas.....	201
3.3.3. A falta da defesa técnica.....	204
3.3.4. O problema da rejeição de contas por ato doloso de improbidade administrativa pelos tribunais de contas.....	207
3.3.4.1. Contas anuais.....	208
3.3.4.2. Contas dos administradores.....	210
3.3.5. Da incompetência dos tribunais de contas para aferir irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa.....	212
3.3.6. A problemática do julgamento político das contas anuais.....	213
3.3.7. <i>Due process of law</i> nas cortes de contas: o problema da prova testemunhal e pericial.....	216
3.3.8. A expansão do poder cautelar dos tribunais de contas.....	219
3.4. Disfunções na Justiça Eleitoral: a soma de todos os medos.....	223
3.4.1. Considerações iniciais.....	223
3.4.2. Controle de convencionalidade da Lei Complementar nº 64/1990 em face da Convenção Americana de Direitos Humanos.....	228
3.4.3. Algumas reflexões sobre as pródigas hipóteses de inelegibilidade da LC nº 64/1990.....	237
3.4.3.1. A inelegibilidade decorrente de exclusão do exercício da profissão (art. 1º, I, “m”, da LC 64/1990).....	237
3.4.3.2. Inelegibilidade por demissão do serviço público (art. 1º, I, “o”, da LC 64/1990).....	238

3.4.3.3. Inelegibilidade por renúncia ao mandato desde o oferecimento de representação ou petição, capaz de autorizar a abertura de processo por infringência à Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Distrital ou Lei Orgânica Municipal (art. 1º, I, "k", da LC 64/1990)	239
3.4.3.4. Inelegibilidade por rejeição de contas por ato doloso de improbidade administrativa (art. 1º, I, "g", da LC 64/1990)	241
3.4.3.5. Inelegibilidade por condenação em ação de improbidade administrativa (art. 1º, I, "l", da LC 64/1990)	248
3.4.4. A insegurança jurídica da jurisprudência eleitoral	249
3.4.5. Considerações finais acerca das hipóteses de inelegibilidades da LC 64/1990 e da insegurança da jurisprudência eleitoral no Brasil	253
Capítulo 4 – Limitação legal da responsabilidade civil dos agentes públicos e gestão de riscos como prevenção	257
4.1. Considerações iniciais	259
4.2. A limitação da responsabilidade e proteção legal do agente público pelos riscos da tomada de decisão: interconexões entre a <i>business judgment rule</i> – BJR e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB	260
4.2.1. Origem e conteúdo da <i>Business Judgment Rule</i> – BJR	263
4.2.2. A <i>Business Judgment Rule</i> – BJR e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB: correlações possíveis	267
4.2.3. A limitação da responsabilidade pessoal dos agentes públicos por normas infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro	271
4.2.4. A limitação da responsabilização pessoal de certos agentes públicos por dolo ou culpa grave no direito comparado	277
4.2.4.1. Portugal	278
4.2.4.2. Uruguai	280
4.2.4.3. Colômbia	280
4.2.4.4. Costa Rica	281

4.2.4.5. Espanha	281
4.2.4.6. Alemanha	282
4.2.4.7. Itália	283
4.2.4.8. França	283
4.2.5. Breves considerações acerca da necessidade de limitação legal da responsabilização dos agentes públicos, em face dos riscos a que estão submetidos: parâmetros para tolerabilidade ao erro do administrador	284
4.2.6. A conceituação de erro grosseiro e suas correlações com a culpa grave nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB	287
4.2.7. A constitucionalidade da MP 966 que tratou da responsabilização dos agentes públicos relacionada com a pandemia da Covid-19	291
4.3. Gestão de riscos na atividade administrativa: parâmetros normativos e técnicas para tratamento dos riscos a que estão submetidos os agentes públicos	295
4.3.1. Regramento normativo da gestão de riscos	299
4.3.2. Metodologias de gestão de riscos	305
4.3.2.1. <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> – COSO	305
4.3.2.2. ABNT NBR ISO 31000	308
4.3.3. Matriz de Riscos	309
4.3.4. Escala de Probabilidade	310
4.3.5. Escala de Impacto	310
4.3.6. Escala de nível de risco	311
4.4. Considerações finais acerca da gestão de riscos como modo de evitar-se a responsabilização dos agentes públicos	312
Capítulo 5 – Risco na administração pública e estratégias de fuga da responsabilização	317
5.1. Conceito operacional de risco e conceitos afins: perigo, risco residual, probabilidade e possibilidade	319

5.2. O risco de responsabilização dos agentes públicos	324
5.3. Interações entre risco e medo: as consequências do medo no processo de tomada de decisão	332
5.4. Os agentes públicos nos mundos da fuga da responsabilização	339
5.5. Estratégias de fuga da responsabilização: considerações preliminares	341
5.6. Tipos de estratégias de fuga da responsabilização	344
5.6.1. Estratégias de manipulação	346
5.6.2. Estratégias de atuação	348
5.6.2.1. Delegação	349
5.6.2.2. Reorganização defensiva	350
5.6.2.3. Coletivização das decisões	351
5.6.2.4. Governo pelo mercado	352
5.6.3. Estratégias de política pública ou estratégias operacionais	354
5.6.3.1. Protocolização	354
5.6.3.2. Gregarismo	354
5.6.3.3. Individualização da responsabilização ou eleição de bode expiatório	355
5.6.3.4. Inação ou imobilismo decisório: a paralisia administrativa ...	355
5.6.4. Estratégias de judicialização ou substituição decisória externa	360
5.6.5. Estratégia de relacionamento informal interadministrativo	362
5.6.6. Estratégia de Blindagem Patrimonial	367
5.7. Considerações finais: as estratégias de fuga da responsabilização são algo positivo ou negativo?	369
5.7.1. Efeitos positivos	369
5.7.2. Efeitos negativos	370
Conclusão	373
Referências Bibliográficas	381

Introdução

Público e dos *Tribunais de Contas*, que desempenham papel institucional comparável aos desenvolvido pela tríade clássica da separação de poderes. A terceira razão está assentada na crescente tensão entre *classe política* e *burocracia*, o que levou à *captura* pela burocracia da classe política.

A luz do que vimos neste Capítulo, nos é lícito concluir que o controle disfuncional da Administração Pública está diretamente ligado à divisão disfuncional dos poderes. Suas funções refletem diretamente esses desequilíbrios e manifestam-se concretamente na prática de atos de controle incompatíveis com uma adequada divisão de poderes. Afinal, a conhecida doutrina de Feliciano Benvenutti nos ensina que *função* implica a concretização de um *poder*, sua transformação em ato. O desenvolvimento da função no tempo exige uma forma específica que traduz-se no procedimento (BENVENUTI, 1952). Portanto, os procedimentos de controle, quando traduzem a concretização do poder disfuncionalizado, implicam controles inadequados e não atendem às finalidades públicas⁸¹.

81. Na clássica definição de função vale a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Tem-se função apenas quando alguém está assujeitado ao dever de buscar, no interesse de outrem, o atendimento de certa finalidade. Para desincumbir-se de tal dever, o sujeito de função necessita manejar poderes, sem os quais não teria como atender à finalidade que deve perseguir para a satisfação do interesse alheio. Assim, ditos poderes são irrogados, única e exclusivamente, para propiciar o cumprimento do dever a que estão jungidos; ou seja: conferidos como meios impostergáveis ao preenchimento da finalidade que o exercente de função deverá suprir. Segue-se que tais poderes são instrumentais: servientes do dever de bem cumprir a finalidade a que estão indissolavelmente atrelados. Logo, aquele que desempenha função tem, na realidade, deveres-poderes. Não ‘poderes’, simplesmente. Nem mesmo satisfaz configurá-los como ‘poderes-deveres’, nomenclatura divulgada a partir de Santi Romano. Com efeito, fácil é ver-se que a tônica reside na ideia de dever, não na de ‘poder’. Daí a conveniência de inverter os termos deste binômio para melhor vincar sua fisionomia e exibir com clareza que o poder se subordina ao cumprimento, no interesse alheio, de uma dada finalidade.” (BANDEIRA DE MELLO, 2015, p. 100-101).

Capítulo 2

Disfunções do controle externo decorrentes da interpretação e da aplicação do direito no Brasil

Confira vídeo exclusivo de apresentação do capítulo



SUMÁRIO: 2.1. Conceito operacional de disfunção. 2.2. Fundamentos ideológicos do controle externo capazes de produzir disfuncionalidades. 2.3. Influxos do decisionismo e do protagonismo judicial na interpretação e na aplicação do direito no Brasil. 2.4. Os problemas na aplicação da teoria dos princípios no Brasil e suas conexões com o controle externo. 2.5. Conclusões acerca das premissas ideológicas do controle externo.

2.1. Conceito operacional de disfunção

O conceito de *disfuncionalidade* permeia todo nosso texto. Em diversos momentos enfrentamos os problemas das disfunções na separação de poderes e ao longo deste livro trataremos do conceito de disfunção no processo de tomada da decisão, no exercício do controle externo no Brasil; no conceito de risco, suas interações com o medo e ainda nas estratégias de fuga da responsabilização por parte dos gestores que igualmente podem ter aspectos altamente disfuncionais.

Nossa perspectiva do controle externo disfuncional irá incluir como foco principal o Poder Judiciário (incluindo a Justiça Eleitoral), o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Entendemos que estes três espaços de controle da Administração são os mais relevantes para se aferir as disfunções a serem enfrentadas neste trabalho. Todos são exemplos de controle externo da Administração e por isso mesmo implicam em exercício de controle por entes externos e com capacidade de interferência nas decisões administrativas, seja invalidando atos, aplicando sanções ou restringindo direitos políticos fundamentais.

O conceito de disfunção é plurívoco, comportando diversos enfoques e perspectivas. Pode ser compreendido como o estudo de patologias da desorganização administrativa e a verificação concreta de tais violações (GASPARRI, 1956).

A obra de Pietro Gasparri (*Corso di diritto amministrativo: Le disorganizzazioni e le disfunzioni amministrative*) de 1956, foi a primeira obra jurídica a trabalhar o fenômeno da disfunção no âmbito do Direito Administrativo. Sua abordagem pouco usual trata da disfunção como fenômeno patológico, partindo da premissa que existem deformidades em relação ao modelo legislativo de como devem portar-se as diversas partes do "organismo social". Segundo o autor, um *organismo social* pode funcionar de modo diferente da constituição e das demais normas jurídicas, quando esteja mal organizado ou desorganizado (GASPARRI, 1956, p. 7).

Suas curiosas correlações do Direito com a Biologia, ao falar do Direito como um *organismo social* ou em *fisiologia e patologia jurídica*, compreendendo a percepção que num sistema normativo específico há fisiologia jurídica, no sentido de conformidade à vontade do legislador. De acordo com Gasparri, há *patologia jurídica*,

quando o próprio legislador reprova como funciona concretamente a Administração Pública, constituindo *doença* no ordenamento. (GASPARRI, 1956, p. 7).

Referida associação de disfunções jurídicas com a biologia¹ começam a ocupar os juristas, a exemplo do conceito de *iatrogenia*, que ocorre quando o remédio acaba tendo efeito mais devastador que a própria doença. A origem da expressão decorre das expressões gregas, *iatros* (médico) e *genia* (origem), é dizer: quando o próprio médico causa malefícios ao paciente ao tratar da sua doença. No contexto deste trabalho, as disfunções do controle externo ocorrem quando os *órgãos e sistemas de controle externo acabam por estimular condutas ou resultados indesejáveis ao exercício de função administrativa*.

A abordagem de Pietro Gasparri pretende limitar-se a questões jurídicas do fenômeno das disfunções, mas não deixa de estar influenciada por uma visão sociológica e comportamental. Ao menos formalmente, pretende estudar as disfunções sob uma perspectiva estritamente jurídica do problema, a partir do momento que o sistema jurídico pode ser concretamente violado.²

Faz distinção entre *disfunção negativa* (v.g. quando há desorganização pela inação de um órgão legalmente previsto ou falta de nomeação de um responsável), e *disfunção positiva* que, ao contrário, consiste na existência de um órgão, mas cuja atuação é desconforme à lei, especialmente quando exerce funções não previstas em lei (*sovra-organizzazioni*); quando alguém legalmente investido de função pública, usurpa competências do seu real titular (*contro-organizzazione*); ou quando alguém comporta-se como titular de função pública, como na existência dos “funcionários de fato” (*pseudo-organizzazioni*) ou, finalmente, quando um ordenamento jurídico delega competência a uma pessoa, mas essa carece de requisitos pessoais necessários para seu exercício, como na falta de sanidade mental, de aptidão intelectual ou idoneidade moral, portanto, quando há um agente legalmente titular de competência mas que não deveria sê-lo (*male-organizzazioni*) (GASPARRI, 1956, p. 15-36).

1. No plano epistemológico, o trabalho de Humberto Maturana (biólogo de formação) aborda a transdisciplinariedade entre os diversos ramos do saber, como: anatomia, biologia, genética, antropologia, cardiologia e filosofia, especialmente quando propôs sua *teoria da autopoiese* ou *biologia do conhecer*, cujo trabalho influenciou a muitos filósofos e juristas. (MATURANA, 2001).

2. Nessas interações assim sinaliza Pietro Gasparri: “Ma a noi giuristi, come tali, non interessa il problema: se il modello di organizzazione amministrativa indicato dal legislatore sia o no sociologicamente corretto; cio interesserà gli studiosi della scienza sperimentale dell' amministrazione e precisamente costituirà quel capitolo di detta scienza che può chiamarsi, appunto scienza della organizzazione amministrativa. Noi giuristi partiamo dal presupposto che un modello di organizzazione amministrativa, sia, dato dal legislatore, e studiamo il modo in cui questo modello può risultare in concreto violato.” (GASPARRI, 1956, p. 14).

Gasparri inclui na categoria de suas disfunções os vícios dos elementos do ato administrativo, de modo a trabalhar os defeitos na produção do ato sob o ângulo de sua teoria das disfunções, viés que possibilita considerável abertura ao conceito de disfunção. (GASPARRI, 1956, p. 123-154).

Bem se percebe que o conceito de Gasparri para disfunção é bastante amplo, portanto não coincidente com nosso ponto de vista, além disso, trata como disfunção questões hoje comumente tratadas na teoria dos atos administrativos, a exemplo da invalidação ou convalidação de atos em face dos seus elementos constitutivos, que não precisam ser tratadas como disfuncionalidades, mas ilegalidades na produção do ato.

Linha assemelhada é seguida por Francesco Bocchini, para quem as disfunções negativas: “*si concretano in una indebita inerzia nella mancata produzione di un effetto che doveva essere prodotto in adempimento di un dovere*” e as disfunções positivas: “*si concretano in una violazione di un dovere negativo inerente ad un ufficio, e, cioè, in un indebito fare.*” (BOCCHINI, 2011, p. 147).

Igualmente relevante a proposta de Norberto Bobbio sobre disfunções, que distingue *disfunção de função negativa*.³ *Disfunção* ocorre quando um instituto executa mal sua *função positiva*. Está ligada à patologia da função. Para um funcionalista

3. Destaca Norberto Bobbio: “Portanto, não se deve confundir a função negativa com a perda de função, que já mencionei, e tampouco com a disfunção, que se verifica quando um instituto executa mal a sua função positiva. A disfunção pertence à patologia da função, a função negativa, à fisiologia (uma vez que toda análise funcional está ligada a uma concepção organicista da sociedade, as metáforas extraídas do comportamento do corpo humano são inevitáveis). A disfunção diz respeito ao funcionamento de um determinado instituto, a função negativa, à sua funcionalidade. Um instituto com funcionalidade positiva pode funcionar mal sem que, por isso, sua função se torne negativa, assim como um instituto com funcionalidade negativa pode funcionar bem sem que a sua função se torne positiva. Pode-se, ainda, admitir como hipótese que uma disfunção de longa data transforme uma função positiva em negativa, mas isto não impede a distinção entre os dois conceitos e a necessidade de assim os manter. (...) Abordando o direito em seu todo, quando se diz que ele tem uma função social e se busca definida, quer-se dizer que tem uma função positiva? De um ponto de vista funcionalista, a resposta não pode ser dúbia: para um funcionalista não podem existir funções negativas. O funcionalismo é uma concepção da sociedade para a qual poderia valer uma máxima construída por analogia à célebre máxima hegeliana: o que é funcional é real, e o que é real é funcional. O funcionalista não conhece funções negativas, conhece somente disfunções (e, quando muito, funções latentes, além das manifestas), isto é, defeitos que podem ser corrigidos no âmbito do sistema, enquanto a função negativa exige a transformação do sistema. Além disso, em uma concepção em que as várias partes de um sistema social são consideradas em função do todo, o direito tem não apenas uma função positiva, mas uma função positiva primária, já que é o instrumento de conservação por excelência, e o subsistema do qual depende, em última instância, a integração do sistema, o limite extremo para além do qual há a inevitável desagregação do sistema”. (BOBBIO, 2007, p. 92-93).

não há funções negativas, ou a função funciona, ou não. Na perspectiva funcionalista as funções podem ser corrigidas em seus defeitos, já a *função negativa* diz respeito à própria funcionalidade de um instituto, quando seus resultados são o oposto do pretendido, a exemplo sistema carcerário, que em vez de recuperar o criminoso, pode transformar-se em escola do crime. (BOBBIO, 2007, p. 92-93).

A perspectiva de disfunção que nos parece mais próxima ao adotado neste livro é a de Christopher Hood, no texto: *Administrative diseases: some types of dysfunctionality in administration*⁴, esse pioneiro trabalho de 1974 já aponta algumas importantes disfunções na Administração Pública como nas hipóteses de corrupção e suborno, mas destacando importantes disfuncionalidades relacionadas ao excesso de burocracia (*red tape*)⁵, microimperialismo dos agentes públicos e excessiva processualidade em que os ritos tornam-se fins em si mesmos (HOOD, 1974).

4. Acerca da ideia de disfunção administrativa, assim sintetiza Christopher Hood: "The basic problem with the idea of dysfunctionality is that it runs together at least three separate problems. First, some cases of administrative failure can be explained simply in terms of 'dilemmas', but there are 'non-linearities' too, as will be explained below. Second, there are at least four quite different types of administrative failure. Third, some distinction has to be made between those types of administrative failure which are created by impossible 'external' demands and those which are internally generated. The second major problem with the concept of dysfunctional bureaucracy is that the mechanisms by which administration becomes ineffective are relatively obscure. Traditionally, two chief mechanisms have been identified. One is 'bribery and corruption'. The other is excessive 'red tape', the micro-imperialism of officials, succession of goals and ritualized procedures which become ends in themselves and are adhered to, no matter how inappropriate the situation. To that should be added those types of bureaucratic dysfunction which have been located in excessive 'clientelism' and professional fragmentation. But these traditional processes are not the only mechanisms by which administration becomes ineffective, nor do they involve a single type of ineffectiveness. Thus a broader range of mechanism can be sketched out once the various dimensions of dysfunctionality have been disentangled". (HOOD, 1974).

5. O conceito de *red tape* quer significar o excesso de regulação ou rigidez burocrática no processo de tomada de decisão, especialmente quando devem ser cumpridas rigorosas normas de controle, impondo aos administradores demasiado gasto de tempo e preocupações. A origem da expressão advém da utilização de "fita vermelha" para indicar os processos administrativos mais complexos de modo a distingui-los dos demais, e teve como origem a administração espanhola do século XVI, ao tempo do rei Carlos V. Para adequada compreensão de *red tape*, fazemos referência a Barry Bozeman ao enfrentar o fenômeno como *patologia burocrática* (*Bureaucratic Pathology*): "As discussed in the previous section, one of the major points of confusion in the formal literature on red tape is whether it is bad, neutral, or, at least in some instances, good. Since red tape is not a natural phenomenon but a social construction, the issue is not what is its essence but what is its most useful conception. The concept employed in the present theory assumes that red tape is a 'pathology'. There are several reasons to take this view. In the first place, it is clearly consonant with popular usage. Citizens and organizational members discussing red tape rarely assume that it is positive. Popular usage is not a sufficient criterion for development of a scientific concept (e.g., Hall 1963), but flaunting popular usage

Especialmente o conceito de disfunção associada a fenômenos como a superorganização e a suborganização (*over and under-organization*) é tratado por Hood. A suborganização quando a inefetividade decorre da organização inadequada. A ideia de superorganização, aponta a organização excessiva, indicando sistemas de controle como autodestrutivos e contraproducentes. Exemplo disso é a *big stick syndrome*, que significa a utilização de mecanismos desproporcionais de controle para se atingir determinados objetivos, tal qual o uso de "marreta" para se quebrar uma noz. (HOOD, 1974).

O conceito de *big stick syndrome* enquadra-se à perfeição como uma das disfuncionalidades do controle externo que estamos a estudar. De regra, o exercício do controle externo brasileiro adota medidas desproporcionais e excessivas que em vez de coibir a violação da norma, efetivamente a fomentam. É exatamente o que alude Hood quando exemplifica que a aplicação de pesadas sanções pela demora na entrega do objeto licitado, acaba por gerar disfunções na medida que licitantes deixam de participar de licitações com prazo de entrega muito curto, impondo gradativo aumento de prazo e consequente prejuízo à Administração. O mesmo se sucede com a aplicação de penas severas para infrações leves, como no exemplo de Hood acerca da antiga pena de morte na Inglaterra para o furto de ovelhas, o que posteriormente levou os magistrados a deixarem de reconhecer a própria culpabilidade dos acusados (mesmo que evidente), diante da possibilidade da pena capital (HOOD, 1974).

Adaptando esses exemplos para nossa realidade, a aplicação de penas exageradas por improbidade administrativa e seus respectivos tipos abertos⁶, estão a gerar

at least requires a good reason. One possible good reason, suggested by Kaufman's (1977) work is that many procedures and controls that seem vexing actually serve legitimate and important social and organizational purposes. That is a good reason to not view all procedures and controls, even extensive ones, as red tape; it is not a good reason to view red tape as beneficial. A second good reason to view red tape as negative is that there is already a set of organizational concepts that deals adequately with certain empirical aspects of rules and procedures. The extensive literature on formalization concerns itself with rules and procedures, without in most instances assuming any negative implications or impacts of rules and procedures (exceptions include Michaels et al. 1988; Podsakoff et al. 1986 who show harmful effects of formalization). Moreover, it seems useful to view formalization as part of the 'physiology' of the organization and red tape as a pathological aspect of that physiology (see Bozeman and Scott 1992 for an elaboration of the argument). Another argument that might be advanced against a negative or pathological concept of red tape relates to the social construction of reality. According to Waldo, 'one man's red tape is another man's system'. Kaufman stated much the same view: 'One man's red tape is another's treasured procedural safeguard'. This point, while certainly valid, is not a strong argument against red-tape-as-pathology. Rather, it is a good reason to note that red tape is best viewed as subject dependent and that rules and procedures have multiple impacts." (BOZEMAN, 1993).

6. Mauro Mattos assevera o caráter aberto dos tipos da Lei de Improbidade Administrativa (MATTOS, 2011).

inúmeras disfuncionalidades, a exemplo da blindagem patrimonial do agente público antes de se assumir qualquer cargo público no Brasil, o que importa na própria ausência de possibilidade de punição patrimonial daquele verdadeiramente ímprobo. Outro grave problema é que o excesso de punição por improbidade administrativa, acaba incentivando a própria improbidade, pois se a punição é inevitável quer se esteja de boa ou má-fé, então incentiva-se o agente público a locupletar-se, quer para garantir a futura contratação de advogados para sua defesa, quer para apropriar-se ilícitamente de recursos públicos para o período de infortúnios que se seguirá ao exercício do cargo⁷ e período de afastamento das funções públicas ou mesmo cumprimento de sentença penal.

Tais disfunções podem levar a uma Administração Pública pautada pelo medo em decidir, a reagir de modo errático e túbio nas questões jurídicas e administrativas a ela submetidas, sempre delegando responsabilidades a subordinados ou mesmo incentivando o cidadão a procurar a via jurisdicional para obter pleito que seria viável em sede administrativa, justamente pelo medo de ordenar despesa pública sem o beneplácito dos órgãos de controle.

Adotamos como conceito operacional de disfunção administrativa decorrente do controle externo *toda atuação insuficiente, ineficiente ou ilegal da Administração decorrente da atuação direta ou indireta dos órgãos de controle externo, que podem produzir condutas ou resultados prejudiciais ao desempenho de função administrativa.*

Essa nova maneira de “reorganizar” a Administração Pública é causa de profundas disfuncionalidades, mormente quando suas causas são mais externas que internas à própria Administração. Isso também leva a reorganizações de fachada que são ineficazes, a exemplo da mera alteração de nome de órgãos públicos sem realizar-se qualquer mudança estrutural mais profunda. A reorganização da Administração Pública pode ser contraprodutiva por envolver custos, por vezes afetando uma atividade que já vinha sendo desenvolvida regularmente, mas que fica obstaculizada em face da “reorganização” (HOOD, 1974).

Como visto, o conceito de disfuncionalidade é *plurívoco*. Para o recorte dessa pesquisa interessa-nos as *disfuncionalidades decorrentes do controle externo*. É dizer: o exercício do controle externo da Administração Pública no Brasil tem gerado graves disfuncionalidades no modo exercício da função pública, com

7. Acera do ponto Hood assevera que quando os inimigos de guerra são maltratados após a captura, se incentiva que lutem até a morte para não serem capturados. (HOOD, 1974, p. 447). Trazendo o tema para a improbidade, a certeza de que os agentes públicos serão punidos por suas decisões administrativas, pouco importando se agiram de boa ou má-fé, pode estimular que incorram em práticas ímprobas para resguardarem-se econômica e ilícitamente das penalidades futuras. Estas externalidades negativas são estudadas na Análise Econômica do Direito (AED), especialmente por Richard Posner (POSNER, 1986).

sérias consequências para gestão eficiente de recursos públicos e no modo de tomada de decisão.

Adiante tentaremos minudenciar quais as possíveis causas dessas disfuncionalidades, a exemplo dos fundamentos ideológicos que lhe dão sustento; a má compreensão da teoria dos princípios como fator de fragilização da segurança jurídica; o risco e o medo decisório; e as estratégias de fuga da responsabilização dos agentes públicos como forma de blindagem contra condenações judiciais ou administrativas a que estão sujeitos.

2.2. Fundamentos ideológicos do controle externo capazes de produzir disfuncionalidades

O controle externo disfuncional está assentado em premissa ideológica que norteia – de modo geral – como os poderes e órgãos de controle enxergam o agente público e a Administração Pública. Interessa-nos a premissa ideológica⁸ potencialmente capaz de gerar disfuncionalidades. Toda generalização é perigosa, especialmente as ideológicas, mormente quando se está a atribuir tal característica não a uma ou outra pessoa, mas as instituições e os poderes que exercem o controle externo no Brasil.

É certo que considerável parte dos agentes que exercitam função de controle externo o fazem de modo adequado e consentâneo à Constituição. Muito devemos ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas e ao Judiciário na fiscalização da administração pública, coibindo desvios e reprimindo a corrupção e a improbidade.

8. O termo *ideologia* foi utilizado pela primeira vez em 1789 por Antoine Destutt de Tracy. Em sua origem queria significar uma disciplina filosófica fosse fundamento para as demais ciências, bem aos moldes do iluminismo que propugnava ciência neutra e universalista que servisse de base para as demais. O sentido de ideologia que adotamos na presente obra é aquele propugnado por Norberto Bobbio, que distinguiu ideologia no sentido fraco (aqui aplicado) e no sentido forte. No sentido fraco, ideologia quer significar: “(...) o *genus*, ou espécies diversamente definidas, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos.” Já em seu sentido forte: “tem origem no conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa consciência das relações de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores, a noção da falsidade: a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia é um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. No significado forte, Ideologia é um conceito negativo que denota precisamente o caráter mistificante de falsa consciência de uma crença política”. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 585). Portanto, queremos significar ideologia em seu sentido fraco, como representação do conjunto de ideias ou valores que permeiam uma pessoa ou instituição, aqui especialmente os órgãos de controle.

A premissa ideológica que pretendemos destacar é aquela *potencialmente produtora de disfuncionalidades e do medo no gestor público*. Por certo não podemos reduzir as premissas ideológicas do controle externo ao recorte que estamos a fazer neste livro. Muitas são as premissas ideológicas e, diga-se de passagem, diversas delas extremamente positivas, pois é certo que os órgãos de controle visam uma administração mais proba, eficiente, e o pleno atendimento ao interesse público.⁹

Justamente por discutir neste texto o problema das disfunções, reflexos do medo e das estratégias de fuga da responsabilização dos agentes públicos quando exaram suas decisões, recortamos nossa pesquisa quanto às premissas ideológicas relacionadas a esses aspectos. Por certo que inúmeras outras facetas ideológicas poderiam ser pesquisadas. Mas parece não faltar na doutrina nacional o destaque as demais premissas ideológicas, asseverando o papel positivo dos órgãos de controle na promoção do interesse público e da necessidade de combate à corrupção.

Após anos atuando no Direito Administrativo e acompanhando inúmeros processos judiciais e administrativos decorrentes do controle da Administração e dos agentes públicos, e, sobretudo, em razão dos inúmeros relatos de grande parte dos publicistas brasileiros que atuam diuturnamente junto à Administração Pública, percebe-se crescente prevenção dos órgãos de controle e fiscalização contra os agentes públicos (especialmente o agente político) e a atuação por vezes desmedida, irracional e, por isso mesmo, disfuncional¹⁰.

Não raro os órgãos de controle acreditam que o espaço da política e da administração pública são — de regra — exercidos com falta de ética e com desonestidade, levando ao menoscabo dos agentes políticos submetidos ao controle jurisdicional,

frequentemente levando os Tribunais de Contas, o Judiciário¹¹ e o Ministério Público à tentação de “administrar” e definirem as escolhas que lhes pareçam mais adequadas e, mais que isso, responsabilizando os agentes públicos pelas decisões por eles adotadas ainda que fundamentadas e amparadas no direito, mas discrepantes dos parâmetros fixados pelos órgãos de controle externo. Tal postura — ainda que não generalizável — realmente amedronta¹².

Em especial, a desconfiança recai no agente político, cujos episódios de envolvimento com corrupção divulgados pela mídia, ainda que não sejam regra, já são suficientes para gerar permanente estado de dúvida acerca da credibilidade das decisões administrativas por eles tomadas, o que em última análise tira a legitimidade da sua decisão — com consequente falta de deferência dos órgãos de controle — levando à grande interferência dos órgãos de controle externo na atividade administrativa.

Por certo tal percepção não é distante — ou é reflexa — da curial apreensão do fenômeno pela sociedade civil, influenciando as instituições de controle e a mídia num processo de *input* e *output*. Como singela evidência do que estamos a sustentar, basta que qualquer um de nós saia às ruas para perguntar o que pensam nossos concidadãos dos políticos brasileiros, para verificar a péssima (para ser eufêmico) opinião que se tem da classe política.

É certo que parcela dos políticos brasileiros fazem por merecer tal reputação, quer por envolvimento em episódios de corrupção, quer pelo gradativo desprestígio da intelectualidade na composição dos parlamentos, ou mesmo pela falta de lideranças que façam a defesa do parlamento com altivez e independência moral, sem preocupação com as repercussões negativas de tal intento perante o eleitorado

9. Neste aspecto valem as considerações de Fernando Vernalha Guimarães ao tratar da necessidade do controle como forma de inibir condutas improbas e ilegais, mas igualmente ressalta a outra face da moeda, quando o excesso de controle gera ineficiências: “É claro que o controle sobre a atividade administrativa é algo imprescindível e inevitável, inclusive aquele de natureza burocrática, uma vez que necessitamos de instrumentos eficazes para inibir condutas arbitrárias, improbas e ilegais, assim como para fiscalizar as ações do gestor do interesse coletivo. E é certo também que o controle, por si, gera ineficiências. É da sua essência interferir no funcionamento da atividade administrativa, criando travas e fricções burocráticas (por assim dizer). O ponto que parece merecer maior reflexão é precisamente a cultura do *excesso* de controle, que vem gerando efeitos colaterais indesejáveis, favorecendo a proliferação de ineficiências. É necessário perceber, enfim, as ‘externalidades negativas’ do controle, que devem ser consideradas para o fim da calibragem desse sistema”. (GUIMARÃES, 2016).

10. Dentre os autores nacionais que detectaram o mesmo problema destacamos: Carlos Ari Sundfeld (SUNDFELD, 2014), Fernando Vernalha Guimarães (GUIMARÃES, 2016), Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (MASCARENHAS, 2016), Joel de Menezes Niebuhr e Pedro Menezes Niebuhr (NIEBUHR; NIEBUHR, 2017), Floriano de Azevedo Marques Neto (MARQUES NETO; FREITAS, 2018), Rafael Vêras de Freitas (FREITAS, 2018), Gustavo Binenbojm e André Cyrino (BINENBOJM; CYRINO, 2018) e ainda Bruno Dantas (DANTAS, 2018).

11. Sobre o modo de pensar dos juizes, digna de nota a análise de Richard Posner: “Los jueces, al igual que otras personas ‘refinadas’ en nuestra sociedad, son reacios a hablar de sexo, pero son también reacios a hablar sobre la actividad de juzgar, especialmente a hablar de ese tema con franqueza, sea a sus colegas o a un auditorio profesional más amplio. Esta reticencia hace que el estudio académico del comportamiento judicial sea al mismo tiempo un desafío y algo imprescindible.” (POSNER, 2011, p. 17).

12. O fenômeno também é percebido na França, conforme análise de Jacques Chevallier: “De modo mais amplo, a destituição cada vez mais frequente na França dos eleitos localmente ou funcionários no âmbito penal, em virtude de ‘delitos não intencionais’, vale dizer, sem que exista um liame direto entre a culpa e o prejuízo, testemunha a intrusão do juiz penal na esfera pública. (...) Ainda que a repressão administrativa se estenda sempre mais, notadamente sob a cobertura de instituições e autoridades administrativas independentes dotadas de um poder de sanção, ela se encontra progressivamente alinhada sobre a repressão penal: e o próprio juiz administrativo é conduzido, quando delibera sobre as condições de pronúncia das sanções, a assumir uma missão de ordem repressiva, ainda que tradicionalmente o objeto da justiça administrativa é, de modo mais amplo, ‘restitutivo’ e não ‘repressivo’.” (CHEVALLIER, 2009, p. 143).

e a imprensa. Mas não devemos esquecer que o povo brasileiro, publicamente tão defensor da ética e dos bons costumes, tem grande responsabilidade na qualidade da composição da classe política brasileira, afinal, é pelo voto que os políticos que são guindados ao mandato eletivo.

A cisão entre a vontade popular e a classe política brasileira é apenas aparente, pois muitos dos agentes políticos, por mais pitorescos e pouco ortodoxos que sejam, efetivamente representam vontade de parte do eleitorado, em que pese algumas disfunções decorrentes da aplicação do quociente eleitoral que eximiriam a responsabilidade do eleitor.

As ambivalências emocionais entre o sagrado e o profano do povo brasileiro com sua classe política, traduz muito das contradições desse mesmo povo com sua própria individualidade. Exigimos do político um comportamento diverso do nosso, mas muitos incorrem nos mesmos vícios nas questões mais cotidianas. Por exemplo: é elevadíssimo o número de brasileiros que: i) dirigem acima da velocidade; ii) ingerem álcool antes de dirigir; iii) sonegam tributos; iv) constroem irregularmente; v) solicitam nota fiscal acima do valor efetivamente consumido para serem ressarcidos pela empresa em que trabalham; vi) “colam” nos exames; etc. Para muitos isso são meros pecadilhos, pois somos “diferentes” da classe política, e, tal qual o antigo *ritual de malhação de Judas*, precisamos dizer que não somos parecidos com a classe política que nos representa pois, no íntimo, não nos conformamos em saber que somos tão parecidos com aquilo que conjuramos. Acerca de tais ambivalências valemos-nos de Freud no seu clássico: *Totem e Tabu*.¹³

Nesse contexto de ambivalência, o agente político assume a feição do novo *homo sacer* (Giorgio Agamben). *Mutatis mutandis*, o agente político (tal qual o *homo sacer*) está cada vez mais excluído da sua comunidade pois incorpora o novo

13. Vejam a análise de Freud sobre a ambivalência entre o sagrado e o profano: “En este punto nos acordamos de la noticia, confusa por su falta de claridad, que Wundt nos ofrecía sobre el doble significado de la palabra «tabú»: sagrado e impuro (cf supra [pág. 33]). Y agregaba que en su origen ella no significaba todavía sagrado e impuro, sino que designaba lo demoníaco, lo que no está permitido tocar; y así ponía de relieve un importante rasgo común a ambos conceptos extremos, pero la persistencia de esa comunidad probaba que entre los dos ámbitos, el de lo sagrado y el de lo impuro, reinaba una concordancia originaria que sólo más tarde dio lugar a una diferenciación. En oposición a ello, nosotros deducimos sin trabajo, de nuestras elucidaciones, que a la palabra «tabú» le cupo desde el comienzo el mencionado significado doble, pues servía para designar una determinada ambivalencia y todo lo que nacía sobre el suelo de ella. La misma palabra «tabú» es ambivalente, y ahora, con posterioridad, nos parece que del solo sentido acuñado en esta palabra se habría podido colegir lo que hemos obtenido tras laboriosa indagación, a saber, que la prohibición del tabú debe comprenderse como el resultado de una ambivalencia de sentimientos. El estudio de las lenguas más antiguas nos ha enseñado que antaño existían muchas palabras así, que abarcaban opuestos; en cierto sentido —aunque no exactamente en el mismo— eran ambivalentes como la palabra ‘tabú’” (FREUD, 1988, p. 72).

bandido. Destarte, qualquer cidadão reveste-se do direito — hoje metafórico — de “matá-lo” e sua existência está despojada de seus bens (como efeito da indisponibilidade de bens por improbidade ou processo crime) e de todo o direito.¹⁴

A figura do político profissional¹⁵, aqui entendido como aquele que pretende fazer carreira política, ocupar diversos cargos públicos que o habilite para a gestão pública e adquirir experiência administrativa, é vista como algo indesejável¹⁶, em curioso contraste com qualquer vocação ou carreira, onde não apenas é desejável, mas necessário aperfeiçoar-se e manter-se em sua profissão.

14. Giorgio Agamben assim resume a figura do *homo sacer*: “Observemos agora a vida do *homo sacer*, ou aquelas, em muitos aspectos similares, do bandido, do *Friedlos*, do *acquae et igni interdictus*. Ele foi excluído da comunidade religiosa e de toda vida política: não pode participar dos ritos de sua gens, nem (se foi declarado *infamis et instabilis*) cumprir qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua inteira existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a todo instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em perene relação com o poder que o baniu. Ele é pura zoé, mas a sua zoé é capturada como tal no bando soberano e deve a cada momento ajustar contas com este, encontrar o modo de esquivá-lo ou de enganá-lo. Neste sentido, o sabem os exilados e os bandidos, nenhuma vida é mais ‘política’ do que a sua.” (AGAMBEN, 2002, p. 189).

15. O conceito de “político por profissão” também nos remete a obra: *Ciência e política*: duas vocações de Max Weber, que assevera: “Nunca existem, portanto, mais de duas possibilidades. Ou a atividade política se exerce ‘honorificamente’ e, nessa hipótese, somente pode ser exercida por pessoas que sejam, como se costuma dizer, ‘independentes’, isto é, por pessoas que gozam de fortuna pessoal, traduzida, especialmente, em termos de rendimentos; ou as avenidas do poder são abertas a pessoas sem fortuna, caso em que a atividade política exige remuneração. O homem político profissional, que vive ‘da’ política, pode ser um puro ‘beneficiário’ ou um ‘funcionário’ remunerado. Em outras palavras, ele receberá rendas, que são honorários ou emolumentos por serviços determinados - não passando a gorjeta de uma forma desnaturada, irregular e formalmente ilegal dessa espécie de renda - ou que assumem a forma de remuneração fixada em dinheiro ou espécie ou em ambos ao mesmo tempo.” (WEBER, 2011, p. 67).

16. Como assinala Enrique Dussel, “É impossível motivar a juventude que decide empreender o ofício de político (ou os que já o escolheram em sua juventude faz tempo) por virtudes de antigamente, ou por valores abstratos de uma sociedade aristocrática em decadência. O jovem, bombardeado pela midiocracia, pela moda, pela totalidade do mundo cotidiano imerso dentro do horizonte de uma sociedade capitalista, que impõe pelo mercado seus ideais de ostentação, superficialidade, dificilmente pode superar as exigências de aumentar sua riqueza para poder comprar e mostrar esses sinais caros (monetariamente) de diferença (diria J. Baudrillard).” (DUSSEL, 2007, p. 38). Ainda que muitas das críticas Dussel contra o político profissional sejam pertinentes, discordamos de sua perspectiva “idealista” do que entende ser o político “por vocação”, eis que numa sociedade complexa não nos parece cindível os múltiplos interesses encarnados na figura do político, desde a busca formação técnica para desempenhar função política (e muito da política se aprende), bem como o fato de escolher a vida política como “opção” de vida e sustento, sem que isto implique em renúncia a ideais “mais elevados”.

Muitos são os fatores que levam alguém à política. Elenquemos alguns: i) vontade de dar sua contribuição à coletividade; ii) representar determinado segmento econômico, sindical ou ideológico; iii) vaidade; iv) busca de uma carreira pública como modo de sustento e v) obter algum tipo de vantagem (lícita ou ilícita) por estar em posição de poder.

Como dito, parte dos políticos brasileiros não fazem jus ao voto popular que receberam; traem a fidúcia emprestada pelos eleitores nas urnas; incidem em episódios de lamentável corrupção. Mas não são a maioria. Ainda estamos longe de ver exaustivas matérias na imprensa nacional destacando os bons projetos políticos, as boas iniciativas legislativas dos parlamentares, os bons projetos de gestão. Seriam notícias xoxas, sem graça.

Em uma sociedade vigilante da sua classe política, o *denuncismo*¹⁷ passa a ser importante, pois a “eletricidade das denúncias” move não apenas a mídia, mas captura a opinião pública. A mídia não cria propriamente o fenômeno, mas amplifica consideravelmente a nova política da desconfiança. Para se manter na política, os políticos revelam intimidades de suas vidas com o intuito de passar a imagem de simplicidade e transparência como virtudes fundamentais e manterem-se como políticos viáveis (ROSANVALLON, 2008).

A mídia brasileira merece um verdadeiro estudo de caso no modo como compreende a classe política. Oscila do ufanismo (mormente ao acompanhar o processo eleitoral, a apuração do resultado das eleições e da posse dos eleitos) à execração (após algum tempo de exercício do mandato) em questão de segundos. Ao mesmo tempo que aponta as mazelas – como lhe cabe fazer num regime de liberdade de imprensa –, raramente informa os sucessos. Esse processo reforça a percepção popular que nossa classe política seria a pior do mundo.

17. Pierre Rosanvallon trata do *denuncismo* desde a revolução francesa até os dias atuais, quando analisa o papel da mídia: “Revolutionaries celebrated what they called ‘the electricity of denunciation’ because it was seen as one aspect of an important form of civic participation, namely, the monitoring of government actions by way of publicity (...) To be sure, the journalism of redemptive denunciation adapted in various ways to different political contexts. From the point of view of intellectual history, however, its history is relatively coherent. Although sensibilities have changed, a continuous thread runs from the pamphleteers of the French Revolution to the investigative journalism of today. (...) What changed was primarily the social measuring instrument and people’s sensitivity to the issues. The media did not create the phenomenon but merely reflected and amplified the advent of a new politics of distrust. By the same token, political leaders exposed more of themselves to the media, opening up their private lives in an effort to enhance their credibility. No longer required to demonstrate their allegiance to a camp, they were instead obliged to give proofs of personal honesty and demonstrate their proximity to voters. Simplicity and transparency became cardinal political virtues. With the advent of the media age and the politician’s need to put himself on display, denunciation became a key form of democratic action.” (ROSANVALLON, 2008, p. 41-48).

O comportamento da mídia em relação à política segue a lógica da sociedade do espetáculo¹⁸, e, em defesa da imprensa brasileira dizemos que não se trata de problema nacional, mas mundial. Em vez de nos debruçarmos sobre os grandes problemas da organização política, há certa propensão a escarafunchar a vida privada dos políticos ou a deter no seu comportamento histriônico ou em suas declarações estapafúrdias, de modo a chamar a atenção do público cada vez mais ávido por atuações e enredos memoráveis protagonizados pela classe política.

Os perigos para democracia nesse cenário espetaculoso são bem descritos por Antoine Garapon:

“A democracia de opinião deriva de uma *representação selvagem*, isto é, tanto de uma delegação de poder em novos agentes que não escolhemos democraticamente (os jornalistas, e até os juízes) como de uma encenação de crueldade. A denúncia já é a condenação numa época em que o tempo é instantâneo – isto é, abolido –, à semelhança do mercado e dos meios de comunicação. As pessoas postas em causa correm o risco de se ver condenadas, e até presas ao pelourinho, antes mesmo de serem julgadas pela justiça. Assim, a condenação desmaterializa-se. É uma democracia reactiva, instintiva, que fala mais do que pensa e se agita mais do que age.” (GARAPON; SALAS, 1999, p. 168).

18. Guy Debord destaca: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de *espetáculos*. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. (...) A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente *espetaculista*. No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar tudo. O espetáculo não deseja chegar a anda que não seja ele mesmo.” (DEBORD, 1997, p. 13 e 17). Ainda sobre o papel do espetáculo em nossa cultura, fazemos menção a Mario Vargas Llosa: “O que quer dizer civilização espetáculo? É a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores cogentes é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se escapar do tédio, é a paixão universal. Esse ideal de vida é perfeitamente legítimo, em dúvida. Só um puritano fanático poderia reprovar os membros de uma sociedade que quisessem dar descontração, relaxamento, humor e diversão a vidas geralmente enquadradas em rotinas deprimentes e às vezes imbecilizantes. Mas transformar em valor supremo essa propensão natural a divertir-se tem consequências inesperadas: banalização da cultura, generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável da bisbilhotice e do escândalo.” (LLOSA, 2013, p. 30). Digno de nota são as reflexões de Marçal Justen Filho, em seu texto: “O direito administrativo de espetáculo”, onde faz importante conexão entre a sociedade do espetáculo e o direito administrativo de espetáculo, destacando: “A atividade administrativa do espetáculo consiste essencialmente na demonstração pública de grande azáfama governativa. Os administradores públicos produzem permanente informação à Platéia relativamente às ações imaginárias que desenvolvem. Essa atividade administrativa espetacular se produz por meio da utilização de conceitos aptos a manter o expectador na condição de um elemento passivo, ocupado em acompanhar a proliferação de notícias jurídicas. Trata-se de prender a atenção dos indivíduos comuns, neutralizando o seu senso crítico e impedir qualquer comparação entre a ação administrativa e o mundo real não imaginário.” (JUSTEN FILHO, 2009, p. 72).

Essa “democracia reativa” exige e propicia o surgimento de salvadores da pátria que fazem do combate à corrupção espécie de bandeira promocional de diversos políticos (lembramos o “varre, varre, vassourinha”, de Jânio Quadros, e o “combate aos marajás”, de Collor de Mello, em que ambas as plataformas moralizantes elegeram um presidente da república). Curiosamente, os projetos de Jânio e Collor marcaram a última eleição democrática antes da ditadura e a primeira eleição democrática após a ditadura. Com efeito, as eleições de 2018 não foram diferente e novamente a tônica do combate à corrupção — dado seu sucesso histórico — mostrou-se eficaz em arregimentar votos dos eleitores sendo pauta obrigatória dos programas de governo quer para Presidente da República, quer para governadores e parlamentares que prometem seu efetivo combate.

Mas não é só. A exigência reativa da sociedade civil propicia que certos integrantes dos órgãos de controle externo adquiram notoriedade midiática ao colocarem-se como mártires na cruzada contra a corrupção. Nesse cenário, combater a corrupção e seus delinquentes¹⁹ (para além dos aspectos positivos de tal intento) passa a ser um fim em si mesmo e modo autopromoção de certos agentes públicos, que atuam em nome de um fim “nobre” a justificar todo e qualquer arbítrio aos direitos fundamentais, por vezes vistos como “empecilho” ou “perfumaria constitucional” a atrapalhar o combate à corrupção.

No caso brasileiro é de supina gravidade o fato da população ou do parlamento “terceirizar” ao Judiciário a realização de reformas de caráter eminentemente político que deveriam ser exercidas com o envolvimento da população na vida partidária, atuação firme do parlamento e não apenas em esporádicos movimentos de rua. Em qualquer democracia contemporânea a democracia é exercida pela via dos partidos políticos, jamais pela via contramajoritária do Poder Judiciário.²⁰

De toda sorte, o conceito da classe política nacional há muito está deteriorado. Mas não se percebe ou divulga que a crise da democracia representativa não é problema unicamente brasileiro, fazendo parte de qualquer país de primeiro mundo, embora equivocadamente se acredite que corrupção e má qualidade do político seja coisa que só ocorra em solo tupiniquim. Não estamos desacompanhados.

19. A questão da delinquência e os aparatos de poder encarregados de reprimi-la, foi objeto de instigante reflexão de Michel Foucault: “A sociedade sem delinquência foi um sonho do século XVIII que depois acabou. A delinquência era por demais útil para que se pudesse sonhar com algo tão tolo e perigoso como uma sociedade sem delinquência. Sem delinquência não há polícia. O que torna a presença policial, o controle policial tolerável pela população senão o medo do delinquente?” (FOUCAULT, 2012, p. 225).

20. O fato de o parlamento omitir-se em questões que demandariam sua atuação é fenômeno que ocorre em qualquer país democrático do mundo. Todavia, em nosso caso além do Legislativo não querer enfrentar certos temas, a população não confia nas soluções dadas pelo parlamento e deposita enorme expectativa no Judiciário.

Para citar alguns exemplos de corrupção nos países de primeiro mundo envolvendo casos de corrupção ou mesmo de duvidosa conduta, citamos a renúncia do Primeiro-Ministro japonês Keyshu Tanaka por envolvimento com a Yakuza; na França as denúncias envolvendo o ex-presidente Nicolas Sarkozy; na Itália os casos envolvendo o então primeiro-ministro Berlusconi; e nos Estados Unidos, os casos envolvendo o ex-presidente George W. Bush e empresas armamentistas e de petróleo.

A busca ao combate à corrupção tem levado a reações, quer da sociedade civil (a exemplo das manifestações de junho de 2013),²¹ quer dos órgãos de controle que também procuram dar solução a esse estado de coisas. No afã moralizante a busca por respostas não raro excede os limites constitucionalmente aceitáveis.

Na atual quadra da história do controle externo brasileiro qualquer agente público que ordene despesa pública, tem enorme probabilidade de receber inúmeras multas, sanções políticas e econômicas, indisponibilidade de bens por infundáveis anos, além de ter sua honra e seu nome execrados perante a familiares e a coletividade. Tudo isso seria muito positivo se efetivamente praticassem malfeitos e danos ao erário.

O problema é que por vezes tais sanções não são juridicamente sustentáveis e se observa o crescente decisionismo do agente controlador sobre a Administração pública. Agiganta-se a insegurança na interpretação da norma jurídica de modo a colmatar os desejos do intérprete sobre as escolhas do agente ou ato administrativo objeto de controle. Evidente que todo texto normativo exige limites semânticos e sintáticos que comportam esforço exegético para bem aplicá-lo, o problema está em fazê-lo de modo a prestigiar mais a subjetividade do intérprete do que a objetividade e os limites dados pelo próprio texto normativo.

Todo esse cenário é decorrente de uma perspectiva ideológica de parte dos integrantes dos órgãos de controle externo que busca dar respostas urgentes a

21. Vejamos o resultado da pesquisa Ibope sobre o tema: “O aumento das passagens foi o estopim. Mas à medida que as ruas foram ficando cheias, elas também se tornaram um caldeirão de reivindicações e de protestos. Para outros 30% dos manifestantes, a principal razão de protesto não era o transporte público, era a política. E 24% disseram que estavam nas ruas contra a corrupção. ‘Chega de corrupção. Chega dessa palhaçada’, disse Igor Soares, de Porto Alegre. Outros motivos de protesto considerados prioritários pelos manifestantes na pesquisa do Ibope: em defesa da saúde, 12%; contra a PEC 37 - a medida que tira do Ministério Público a atribuição de realizar investigações criminais - 6%; 5% contra os gastos com a Copa do Mundo; e outros 5% pela educação. Mas quando o Ibope leva em conta não apenas a primeira, mas as três primeiras respostas dadas espontaneamente pelos manifestantes, o transporte cai para o segundo lugar. A política aparece em primeiro, com 65%. A questão política mais citada foi a corrupção, apontada por quase a metade dos manifestantes como motivo para protestar.” (grifo nosso). Disponível em: [http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/06/transporte-e-politica-sao-principais-razoes-de-manifestacoes-diz-pesquisa.html]. Acesso em: 24 de junho de 2015.

antigos problemas conjunturais e a supressão ou malferimento de direitos e garantias individuais parece justificar os elevados fins de combate a corrupção e, de consequência, o próprio modo do exercício do controle externo sobre os agentes públicos.

Para finalizar o ponto, tratemos muito brevemente de uma outra questão. A ênfase do controle externo no *controle de legalidade*, paradoxalmente, tem gerado trágicos problemas. Sem pretender apequenar o papel do controle de legalidade em nossa tradição jurídica, o fato é que o controle de legalidade como um fim em si mesmo leva a distorções e disfunções, visto que a hiperinflação do controle de legalidade²² por vezes imobiliza ou dificulta a tomada de decisão (em face das complexidades normativas que envolvem determinado caso), e propicia a “cômoda” verificação do descumprimento das normas jurídicas na atividade controladora.²³

22. A ênfase num controle de legalidade e crescente regulamentação da qual o agente não pode dar conta, foi bem assinalada por Agustín Gordillo: “Al insistirse en el control de legalidad como control predominante, se introduce entonces una tendencia hacia la creciente reglamentación para hacer más predecible y ‘más fácilmente controlable’ la conducta. Pero ocurre que lo que se refuerza de este modo es el control puramente formal, porque formales son en tal situación las normas que se dictan: Se llega inevitablemente a una exageración del análisis de juridicidad reglamentaria del acto, en desmedro de la apreciación de su mérito. Se afirma así la vigencia y la convicción de que si un funcionario dicta un acto válido o legal, nada puede objetársele; que si su decisión es inoportuna o inconveniente ello es materia librada a la discrepancia política, en todo caso, pero exenta del control y del reproche administrativo. Desde luego esto es un error, porque por lo general no suele ser demasiado difícil dar cumplimiento a los recaudos formales, si el funcionario simultáneamente se despreocupa de que sus actos sean además eficaces de acuerdo a las circunstancias. Así se va distorsionando todo el sistema, no sólo a partir del control sino también a partir de la emisión de normas que el control provoca para autosatisfacerse y autorrealizarse. Las normas innecesarias y detalladas que se van dictando constriñen cada vez más la creatividad e imaginación de los funcionarios, refuerzan la idea de que el actuar conforme a las normas es garantía suficiente de corrección y acierto, como si no fuera también posible actuar incorrecta e ineficazmente aún habiendo dado cumplimiento formal a las disposiciones vigentes: Y la profecía autocumplida a veces se realiza, de que la irregularidad y el abuso, cuando no el delito, pasan por medio del mejor cumplimiento y control reglamentario.” (GORDILLO, 2012).

23. Sobre os riscos do formalismo no controle gerarem eficiência e atuação servil da Administração valem as reflexões de Onofre Batista Júnior: “Para o modelo burocrático mais ortodoxo, comportamento eficiente, por pressuposto, é aquele conforme ao ‘bloco legal’. Para tanto, todo o sistema gerencial burocrático é desenhado de forma a possibilitar o alinhamento da atuação dos agentes à regulamentação administrativa. Exatamente por isso, os mais diversos estatutos burocráticos se limitam, na maioria das vezes, a trazer ‘deveres’ dos servidores públicos e a estabelecer ‘sanções’ pelo descumprimento desses deveres. O modelo gerencial autocrático, portanto, funciona com lastro no mecanismo ‘dever X sanção’. A preocupação central do corpo burocrático desses órgãos, na maioria das vezes, está em buscar equívocos, desatenções, descumprimentos de linhas e entrelinhas, culpados, e não na perseguição de

Ora, ainda que a não observância do princípio da legalidade possa levar à aplicação de pesadas sanções (a depender do caso concreto), o fato é que mais raramente se aplicam advertências e recomendações. Os órgãos de controle não raro partem daquilo que denominamos *Administração Pública idílica*, onde administrar – para usar a clássica expressão de Seabra Fagundes – é: “aplicar a lei de ofício”, como se a função administrativa fosse algo simples de ser exercida e o descumprimento da lei seu pecado mortal.

A diagnose aqui efetuada, apesar de preocupada com a crise política e institucional que perpassa toda sociedade, tem a esperança de que ao refletirmos sobre o tema possamos corrigir os excessos e evitar um mal ainda maior. Não compete aos órgãos de controle serem o bastião da democracia brasileira. Devem punir os agentes públicos na exata medida da sua responsabilidade, sem preconceitos nem superioridade em relação aos que exercem função administrativa. Passemos agora a enfrentar equívocos atribuíveis ao peculiar modo dos nossos órgãos de controle interpretarem a aplicarem o Direito.

2.3. Influxos do decisionismo e do protagonismo judicial na interpretação e na aplicação do direito no Brasil

Parte dos equívocos ideológicos narrados anteriormente decorrem do modo como os órgãos de controle externo interpretam e aplicam o Direito na realidade jurídica brasileira. Há gradativo incremento do decisionismo do ente controlador e consequente desvanecimento do seu dever em motivar de modo juridicamente sustentável as razões pelas quais impõem sanções ou restrição a direitos políticos e individuais.

É dizer: não há qualquer preocupação do intérprete em fundamentar sua decisão, mas mera exteriorização de uma subjetividade descompromissada com o

uma atuação administrativa eficiente. Muitas vezes desconhecendo a realidade concreta ou a técnica utilizada, burocratas do controle tendem a agravar o quadro de ineficiência. O sistema jurídico administrativo sancionatório se mantém ultrapassado, não tendo ainda se desvencilhado do tradicional modelo de julgamento do processo administrativo disciplinar, vinculado à hierarquia funcional. Para agravar, o sistema de composição e de julgamento dos processos administrativos disciplinares é feito pela mesma autoridade administrativa que instaura e, ao mesmo tempo, nomeia os integrantes da Comissão Disciplinar, o que coloca sob suspeita a garantia de imparcialidade/impeccabilidade nas apurações/investigações disciplinares. A cultura administrativa reinante, nesse contexto, é a do medo, a do receio da punição. Não se tenta aperfeiçoar ou buscar a solução adequada, mas o receio enraizado aponta sempre para a solução de privilégio de uma interpretação literal dos regulamentos e ordens do hierarca. A eficiência administrativa e o bem comum são postos de lado em prol de uma atuação servil e, por vezes, medrosa e covarde.” (BATISTA JÚNIOR; CAMPOS, 2014. p. 38).

Direito. Outras vezes há a preocupação de elencar no plano argumentativo as razões pelas quais se decide, todavia, nem sempre de maneira coerente e satisfatória.

Sabemos que o controle sobre a Administração Pública visa aferir a conduta do agente em conformidade com as normas jurídicas (princípios e regras) que lhe servem de parâmetro. A atividade controladora não pode prescindir da análise da validade, interpretação e aplicação das normas jurídicas para verificar o agir administrativo dos agentes públicos na condução da atividade administrativa.

Com efeito, o debate em torno da interpretação do Direito, tem especial relevo no sentido de explicar como os agentes de controle fiscalizam o desempenho da função administrativa, pois a depender da postura teórica que adotam, podem oscilar dramaticamente de entendimento quanto a observância ou não da norma jurídica, afinal, os órgãos de controle interpretam, aplicam o Direito e controlam a atividade administrativa à luz daquilo que compreendem por Direito.

Como já visto anteriormente, um dos graves problemas a fundamentar esse viés ideológico deve-se ao protagonismo do Judiciário²⁴ e o fenômeno do ativismo judicial, que pode traduzir-se na criação de normas em descompasso com o direito positivo, por vezes com o intuito de dar vazão a certa perspectiva política aparentemente fundamentada juridicamente.

Para bem ilustrar a perspectiva ideológica da magistratura brasileira no tocante ao seu papel ético-moral e ainda como atuação substitutiva aos poderes políticos, nos servimos da recente pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados

24. A ascensão do Judiciário implica em graves riscos à democracia, especialmente quando a Justiça atua como consciência moral da sociedade, como bem elucida Ingeborg Maus: “Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social – controle ao qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma de organização política democrática. No domínio de uma Justiça que contrapõe um direito ‘superior’, dotado de atributos morais, ao simples direito dos outros poderes do Estado e da sociedade, é notória a regressão a valores pré-democráticos de parâmetros de integração social. No desdobramento dessa tendência e de seus fundamentos – em que as condições sociais estruturais, assim como seu apoio em mecanismos psíquicos, devem ser levados em consideração –, convém investigar se se trata de uma simples regressão social ou antes de uma acomodação às condições do moderno e anônimo aparato de administração do Estado, em que todas as figuras paternas são obrigadas à abdicação. Pode ocorrer que penetre nesse foro interno aquela instância que compreende a si própria como moral e que, de maneira tão incontroversa, é reconhecida como consciência de toda a sociedade, de tal modo que a imagem paterna à qual se resiste atue concomitantemente como ponto de partida do clássico modelo da transferência do superego e como representante de mecanismos de integração despersonalizados. A pergunta a ser feita é, portanto, a seguinte: não será a Justiça em sua atual conformação, além de substituta do imperador, o próprio monarca substituído?” (MAUS, 1989, p. 189).

Brasileiros: *Quem Somos. A magistratura que queremos*²⁵. Nas diversas perguntas dessa pesquisa constava: “Questão 66: Dentre as afirmações abaixo, assinale aquela com a qual mais se identifica:” Dentre as respostas, figurava: “O Poder Judiciário se deve atribuir um papel ético-moral na sociedade, educando-a para a vida pública.”

A resposta acima foi afirmada apenas por 12,8% dos magistrados em primeiro grau em atividade, o que aparentemente contrariaria a ideia de que o Judiciário estaria no exercício da vigilância ética da sociedade²⁶. Todavia, não passam despercebidos dois problemas nas respostas da *Questão 66* submetidas à pesquisa. O primeiro, que dificilmente alguém se afirma como detentor de papel ético-moral, assumindo abertamente tal protagonismo. O segundo problema é que as demais respostas ofertadas aos magistrados na mesma *Questão 66* havia uma de óbvia escolha, direcionando as respostas, afinal, quem não se identifica com a assertiva: “O Poder Judiciário deve promover a realização plena do Estado de Direito, garantindo a aplicação da lei e a sua correta interpretação?”

Essa postura mais interventiva do Poder Judiciário na sociedade brasileira, ficou mais evidente na resposta a *Questão 64* da pesquisa da AMB, onde perguntou-se: “Desde a Constituição de 1988, o Poder Judiciário vem expandindo sua presença na sociedade brasileira. Indique a alternativa com a qual mais se identifica:”

Dentre as respostas a *Questão 64*, apenas de 17,8% dos magistrados de primeiro grau em atividade entenderam que: “A presença do Poder Judiciário em diferentes

25. A pesquisa *Quem Somos: a magistratura que queremos* realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, pesquisou amplo universo de magistrados brasileiros, desde o primeiro ao último grau de jurisdição, inclusive inativos. Considerando que ainda são raras as pesquisas empíricas no Brasil e mais raro ainda que possamos aferir a opinião da magistratura brasileira sobre temas tão diversos, certamente serão necessários muitos anos para digerir todo o material pesquisado, cujos dados irão subsidiar inúmeros trabalhos acadêmicos a serem desenvolvidos. Disponível em: [www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_QUEM_SOMOS_AMB_completa_para_site.pdf]. Acesso em 19 de fevereiro de 2019.

26. Esta opinião foi compartilhada na introdução da pesquisa AMB quando afirma: “Outras questões são igualmente relevantes para se atestar continuidades e descontinuidades na magistratura, como a recusa à autocaracterização dos magistrados como *intelligentsia* privilegiada, superposta à sociedade e vocacionada para o exercício de um papel pedagógico na educação cívica dos brasileiros. A *Questão 66* – que indagava se ‘o Poder Judiciário se deve atribuir um papel ético-moral na sociedade, educando-a para a vida pública e a cidadania’ – foi respondida positivamente por apenas 14% dos magistrados em 1996 e por cerca de 13% deles em 2018, contrariando perspectivas hoje correntes em certas parcelas da opinião pública ecoadas pela imprensa, que tomam o Judiciário como vigilante ético da sociedade.” Referida afirmação dos pesquisadores foi realizada na p. 26. Disponível em: [www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_QUEM_SOMOS_AMB_completa_para_site.pdf]. Acesso em 19 de fevereiro de 2019. A resposta dos magistrados a *Questão 66* está na página 96-97 da referida pesquisa.

é, na verdade, a outra face do princípio da legalidade (*auctoritas non veritas facit legem*).” (FERRAJOLI, 2010, p. 41).

Outro autor é Dimitri Dimoulis, que propõe o resgate do positivismo jurídico de viés mais formalista, criticando a abordagem moralista²⁹ do fenômeno jurídico, resgatando a proposta positivista e trazendo debates mais recentes como os contributos de Joseph Raz e Neil MacCormick.³⁰

O positivismo formalista, dado os diversos tipos de positivismos, adota a separação entre Direito e moral, sujeito cognoscente e objeto cognoscível (HESPANHÁ, 2009, p. 435-436). Essa distinção já se mostrou filosófica e teoricamente insuficiente, na medida que a dissociação sujeito-objeto não se mostra factível como bem trabalhou Hans-Georg Gadamer em sua filosofia da linguagem³¹. Há

29. Para Dimitri Dimoulis: “O moralismo jurídico faz depender o reconhecimento da validade das normas jurídicas e sua interpretação de elementos vinculados a valores (e correspondentes mandamentos) de origem moral. Admite-se, assim, a tese da necessária conexão (junção, vinculação) entre direito e moral.” (DIMOULIS, 2006, p. 87). Para Dimoulis, ao adotar-se a postura moralista, teríamos um moralismo de validade (a norma jurídica apenas seria válida se atendessem à moral) ou um moralismo da interpretação (aplicador deve invocar valores morais ao interpretar a norma). Contemporaneamente, os partidários do moralismo de validade o adotam temperadamente, pois apenas em casos de extrema imoralidade ou injustiça é que a norma não integraria o sistema jurídico. Já o moralismo de interpretação apresenta uma sedutora resposta ao problema da hermenêutica jurídica. Quando houver conflito entre a norma jurídica e os valores morais do julgador, este deverá interpretar o direito sob critérios do direito justo (DIMOULIS, 2006, p. 91-93).

30. Acerca do *positivismo jurídico exclusivo* destaca-se Joseph Raz (RAZ, 1979), para quem o Direito consiste em considerações positivadas cuja existência e conteúdo podem ser afirmadas sem recurso a valorações morais. Quanto ao *positivismo jurídico inclusivo* a proposta (por muitos considerada pós-positivista) de Neil MacCormick que parte da premissa que o Direito é uma disciplina argumentativa em vez de uma ciência exata (MACCORMICK, 1994).

31. Sobre o tema pertinentes as reflexões de Néviton Guedes: “Tão logo se entremostra o primeiro sentido de um texto, e já o intérprete antecipa o sentido de seu todo, em outras palavras, o sentido da interpretação de um texto apenas se manifesta, segundo Gadamer, porque aquele que interpreta um texto o interpreta com determinadas expectativas, a partir de determinado sentido. Assim, a compreensão do texto que se põe ao intérprete consiste precisamente na elaboração e aperfeiçoamento daquele projeto prévio, que deve ser confirmado e revisado continuamente conforme se vai penetrando mais extensamente do sentido do texto. É compreensível, portanto, que, no processo hermenêutico, a objetividade só possa estar nessa possibilidade de revisão daquele projeto prévio. Isso apenas se alcança ao colocarem-se lado a lado projetos rivais até que se possa estabelecer uma unidade de sentido. Resumindo, toda interpretação começa com conceitos prévios que, no seu itinerário, serão substituídos por conceitos mais adequados. A esse processo de novo-projetar ou reprojeter permanente, que concretiza o movimento de conferir sentido à compreensão e à interpretação, Heidegger designava círculo hermenêutico (*hermeneutische Zirkel*).” (GUEDES, 2012a).

muito de ingenuidade na perspectiva formalista do positivismo em acreditar que este dispensaria esforço hermenêutico num modelo essencialmente subsuntivo.

O processo de interpretação do Direito passa num primeiro plano pela compreensão, sem a qual não é possível fazer qualquer interpretação ou aplicação do Direito. Assim, quando o intérprete “interpreta” é porque já compreendeu. Segundo Hans-Georg Gadamer trata-se de processo unitário, em que a própria compreensão passa pela aplicação:

“(…) o problema hermenêutico recebeu seu significado sistemático no momento que o romantismo reconheceu a unidade interna da *intelligere* e *explicare*. A interpretação não é um ato posterior e ocasionalmente complementar à compreensão. Antes, compreender é sempre interpretar, e, por conseguinte, a interpretação é forma explícita da compreensão. (...)”

“(…) se quisermos compreender adequadamente o texto – lei ou mensagem de salvação –, isto é, compreendê-lo de acordo com as pretensões que o mesmo apresenta, devemos compreendê-lo a cada instante, ou seja, compreendê-lo em cada situação concreta de uma maneira nova e distinta. Aqui, compreender é sempre também aplicar”. (GADAMER, 2013, p. 406-408).

Dessa assertiva não decorre a prevalência da subjetividade do intérprete, afinal, para Gadamer, tal tarefa não implica na *congenialidade*, é dizer: na união entre o criador e o intérprete de uma obra. Portanto, é possível reconhecer o que é significativo em um texto e seu sentido originário. (GADAMER, 2013, p. 410-411). A interpretação está inserida dentro de determinada tradição histórica que influencia a atuação do intérprete.

Como preleciona Castanheira Neves, a interpretação deve ter por objeto³² não apenas a *norma jurídica*, mas sua *normatividade*, dimensão intencional e jurídica pois inserida numa: “perspectiva normativo-pragmaticamente-adequada”:

32. E por objeto da interpretação destaca Castanheira Neves: “Vimos a resposta que o modelo tradicional dava a esta questão do objecto da interpretação – o objecto da interpretação seria o texto da norma jurídica. E vimos também porque essa resposta não pode manter-se: o problema da interpretação jurídica não é hermenêutico, mas normativo. Daí que o objecto em causa há-de ser correlativo a esta índole do problema, sendo certo que o problema interpretativo vai implicado pela natureza prática normativa do caso a resolver com apoio na solução desse problema. Por outras palavras, o objecto normativo interpretando não poderá ser um objecto meramente significativo, mas um objecto susceptível de oferecer um critério normativo para a solução judicativa do caso decidendo. E então o objecto da interpretação não será o texto das normas jurídicas, enquanto a expressão ou o *corpus* de uma significação a compreender e a analisar, mas a normatividade que essas formas, como critérios jurídicos, constituem e possam oferecer. Se distinguirmos na norma a sua expressão significativa (dimensão fenomenológica e cultural) da sua normatividade (dimensão intencional e jurídica) e que a faz ser *norma*, podemos dizer que a interpretação jurídica não visa a expressão da norma, mas a

dimensões da vida brasileira é um fenômeno prejudicial à democracia, pois pode levar a que o Judiciário exerça papéis substitutivos ao dos poderes políticos” Em nossa leitura, esses dados indicam que não está em primeiro plano das preocupações dos magistrados brasileiros um papel mais deferente do Judiciário para com os demais poderes ou mesmo de autocontenção.

Ao contrário, a resposta as demais alternativas da Questão 64 indicam clara postura ativista, pois 35,4% dos juízes de primeiro grau em atividade responderam que: “A presença do Poder Judiciário em diferentes dimensões da vida brasileira é um fenômeno positivo para a consolidação da democracia no país, na medida em que favorece a ampliação de direitos que não encontram passagem no Poder Legislativo” e 46,8% dos juízes de primeiro grau em atividade responderam que: “A presença do Poder Judiciário em diferentes dimensões da vida brasileira é um fenômeno positivo para a consolidação da democracia no país, na medida em que propicia um maior controle do funcionamento dos poderes Executivo e Legislativo”, asseverando o crescente desejo de protagonismo do Judiciário nos demais poderes.²⁷

Essa perspectiva ideológica mais interventiva nos poderes políticos também se aplica ao Ministério Público. É quase impossível ao ordenador de despesa, especialmente os prefeitos municipais – por mais corretos que sejam – deixarem seus mandatos sem responderem a inúmeras ações de improbidade. Por certo que o Ministério Público tem não apenas o poder, mas o dever de mover tais demandas quando necessárias. Como veremos mais à frente, o que amedronta é o volume de ações destituídas de qualquer fundamento sólido, ou quando tais demandas refletem o exercício oblíquo de função administrativa privativa das chefias de executivo, ditando e impondo moralmente qual conduta esperam dos agentes políticos.

Dos órgãos constitucionais autônomos da República Brasileira nenhum está a merecer maior reflexão que o Ministério Público. Se de um lado desejamos um MP atuante e cioso dos seus deveres constitucionais, de outro necessitamos de mecanismos de controle que melhor fiscalizem a atuação do *parquet*. A velha pergunta *quis custodiet ipso custodes*²⁸ ou *who guards the guards*? (quem controla o controlador?) nunca foi tão pertinente. O medo chega a tal ponto que os integrantes do Ministério Público têm receio em requerer o arquivamento de denúncias, pois o juízo que se fará dessa postura nos respectivos conselhos, “recomenda” a instauração que de ações de improbidade ou a deflagração de ações penais mesmo sem fundamento consistente.

De igual modo, se é desejável o amplo controle jurisdicional como corolário lógico do Estado democrático de direito, como decorrência do lícito exercício do controle externo e do sistema de pesos e contrapesos, de outro, as denúncias infundadas, as decisões nos processos de improbidade nos moldes atualmente exercidos tem levado a excessos e ao solipsismo decisório (STRECK, 2011), como se o magistrado pudesse exercer amplamente sua discricionariedade na interpretação do direito positivo (por vezes ignorando-o por completo), sem qualquer preocupação normativa, impulsionado por uma filosofia da consciência, e, a despeito das leis e da Constituição, pudesse encontrar a interpretação que moralmente melhor lhe apeteça; além da falta de discurso jurídico coerente e fundamentado, visando a incidência de sanções (especialmente nas ações de improbidade), a inobservância de parâmetros e de precedentes consistentes, visando a responsabilização (razoável e proporcional) dos agentes públicos.

O problema do decisionismo e do solipsismo do intérprete na aplicação da norma está tornando-se tão grave, que a percepção desse fenômeno pelos juristas está fazendo com que se procure recobrar a importância de uma abordagem normativista-formalista, quer ainda uma visão normativista mas permeada dos avanços do constitucionalismo, sem cair nos riscos do neoconstitucionalismo.

Um exemplo desse tipo de abordagem pode ser identificada em Luigi Ferrajoli, que no seu garantismo faz uma abordagem positivista-crítica, destacando a centralidade da constituição na análise da validade e da interpretação das normas jurídicas, ponderando:

“(…) Em síntese, bem mais que no modelo neoconstitucionalista – que confia a solução das aporias e dos conflitos entre direitos à ponderação judicial, inevitavelmente discricionária mesmo quando argumentada, enfraquecendo, assim, a normatividade das Constituições e a fonte de legitimação da jurisdição –, o paradigma do constitucionalismo rígido limita e vincula de modo bem mais forte o Poder Judiciário, em conformidade com o princípio da separação de poderes e com a natureza tanto mais legítima quanto mais cognitiva – e não discricionária – da jurisdição. Os juízes, com base em tal paradigma, não podem criar normas, o que implicaria numa invasão no campo da legislação, mas somente censurar a sua invalidade por violação à Constituição, anulando-as no âmbito da jurisdição constitucional, ou, então, desaplicando-as ou suscitando exceções de inconstitucionalidade no âmbito da jurisdição ordinária; em ambos os casos, intervindo, assim, não na esfera legítima, mas na esfera ilegítima da política. A legitimidade da jurisdição se funda, na verdade, a meu ver, sobre o caráter mais cognitivo possível da subsunção e formulação como regra – do grau de taxatividade e de determinação da linguagem legal; enquanto a indeterminação normativa e a consequente discricionariedade judicial são um fator de deslegitimação da atividade do juiz. O cognitivismo judiciário (*veritas non auctoritas facit iudicium*), mesmo como ideal regulativo,

27. A inteireza da Questão 64 submetida aos magistrados brasileiros pode ser encontrada na p. 92 a 93 da pesquisa: Quem somos: a magistratura que queremos. Disponível em: [www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_QUEM_SOMOS_AMB_completa_para_site.pdf]. Acesso em 19 de fevereiro de 2019.

28. A frase é de Juvenal (Decimus Iunius Iuvenalis) na Sátira n° VI. (IUVENALIS, [s.d.]).

“Tendo em conta tudo o que concluímos até aqui, facilmente se reconhecerá que a perspectiva actual para a consideração do problema da interpretação jurídica terá de ser outra. E essa mudança de perspectiva vem a traduzir-se, desde logo, no postular *o caso jurídico como o prius metodológico*. E com isto pretende afirmar-se que o caso jurídico não é apenas o objeto decisório-judicativo, mas verdadeiramente a perspectiva problemática-intencional que tudo condiciona e em função da qual tudo deverá ser interrogado e resolvido. Pelo que a interpretação jurídica só será entendida em termos metodologicamente correctos se for vista como a determinação *normativo-pragmaticamente-adequada* de um critério jurídico do sistema do direito vigente para a solução do caso decidendo. (...)” (CASTANHEIRA NEVES, 2013, p. 142).

A neutralidade metodológica do discurso positivista não é algo atingível, dada a impossibilidade de produção do conhecimento livre das influências ideológicas, não sendo factível a separação absoluta entre sujeito e objeto (FONSECA, 2009, p. 59-60). Já Dimoulis parece acreditar na neutralidade da postura metodológica do intérprete em conseguir diferenciar seu interesse pessoal das tentativas de dar significado às proposições normativas, visando encontrar a resposta correta ou alternativas autorizadas pelo texto normativo (DIMOULIS, 2006, p. 243). Concordamos em parte. É fato que o texto normativo deve limitar o intérprete, e isso, de *per se*, serve para estabelecer limites no processo interpretativo. Todavia, na esteira de Gadamer, somos céticos quanto à absoluta dissociação da relação sujeito-objeto.

O próprio Kelsen admite que a interpretação do direito compreende inevitável subjetivismo do intérprete, superando assim o positivismo exegético que como bem destaca Lenio Streck: “ainda hoje se pensa que, para ele [Kelsen], o juiz deve fazer uma interpretação ‘pura da lei!’” (STRECK, 2010). A visão kelseniana não acredita na possibilidade de aplicar-se automaticamente as leis. No mesmo sentido, caminha João Batista Gomes Moreira: “A teoria pura do direito, conforme esclarecimento do próprio Kelsen, não é o mesmo que teoria do direito puro.” (MOREIRA, 2005, p. 115).

Porém, mesmo reconhecendo a impossibilidade de dissociação da relação sujeito-objeto, isto não autoriza que a interpretação possa ser assistemática, e, uma vez admitida a necessidade da interpretação sistemática, supera-se a irrestrita subjetividade do intérprete pelos parâmetros oferecidos pelo sistema.

norma da norma – não sua expressão (texto) que tem uma significação, mas a sua norma que tem um sentido especificamente jurídico. O objecto da interpretação jurídica é, pois, a norma enquanto norma não o seu texto enquanto expressão da norma – não o objecto expressivamente significativo, mas o objecto intencionalmente normativo-jurídico”. (CASTANHEIRA NEVES, 2013).

Como bem destaca Juarez Freitas acerca da interpretação sistemática do Direito

“Os meios e os fins são justificáveis uns pelos outros. Por isso, ao interpretar aplicar determinada norma individual não há como deixar de considerá-la sistemática ou não. Contudo, *tal julgamento não deve ser a erupção de um decisionismo usurpador das competências*. Ao intérprete incumbe – convém frisar – *conferir sistematicidade às normas, vale dizer, harmonizá-las, formalmente, na garantia salutar e democrática coexistência das liberdades e igualdades, no presente em que ocorre a evolução hermenêutica*.” (FREITAS 2010, p. 78). (grifos do original)

Dimitri Dimoulis com acerto aduz: “A definição inicial da interpretação indica que o intérprete atribui sentido às normas jurídicas, mas isso não o libera da obrigação de utilizar determinados métodos e argumentos para justificar sua proposta interpretativa. Esses métodos e argumentos constituem meios de atribuição de sentido interpretativo.” (DIMOULIS, 2006, p. 228-229).

Partindo das premissas acima expostas, parece ser crescente a preocupação da teoria do direito com a ampla discricionariedade na interpretação e na aplicação da Lei, extensível a todos os órgãos de controle externo nos moldes propostos neste texto. Tal exagero possibilita ao intérprete a fazer “o que bem entende” na aplicação da norma jurídica³³, dando vazão a sua plenipotenciária subjetividade, e, em assim fazendo, traz não apenas medo, mas pânico aos agentes públicos sujeitos ao controle externo.

Afinal, se a aplicação da norma jurídica na realidade brasileira não passa mais pelos parâmetros contidos na própria norma, nem mesmo por métodos argumentativos explícitos que lhe deem sentido, os agentes públicos ao receberem as duras sanções hoje contidas no ordenamento jurídico brasileiro nas ações de improbidade, nos processos de julgamentos de contas ou em matéria eleitoral, dependerão em grande parte – ou exclusivamente – da “boa vontade”, da magnanimidade e da condescendência dos órgãos de controle, pois se esses desejarem,

33. Sob a perspectiva ideológica do neoconstitucionalismo assevera Carlos Blanco de Moraes: “Precisamente na órbita da ‘nova hermenêutica’, assumem especial protagonismo contemporâneo os neoconstitucionalistas, que rescrevem os princípios da democracia e da separação dos poderes, em termos tais que permitem a emergência ativa de um binómio entre uma Constituição dirigente e um poder jurisdicional competente para, na esfera dos direitos sociais, legislar materialmente a partir dos seus princípios, criando normas de decisão prevalentes sobre as do legislador ou até substitutivas deste último em caso de omissão. Trata-se, no fundo, de um *dirigismo constitucional ideológico*, que: i) faz repousar sobre as normas da Constituição social, o seu programa de governo; ii) que utiliza o *poder judicial como instrumento de controle intenso* (e por vezes como *poder substitutivo*) das políticas públicas do legislador; iii) e que recorre à *ponderação de valores e princípios*, em sede interpretativa, como critério dúctil do exercício do referido controlo.” (MORAIS, 2014, p. 698).

poderão literalmente defenestrá-los do espaço da política, dos seus bens e dos seus direitos políticos.

Esse cenário de total insegurança jurídica remete-nos ao Hino de Duran de Chico Buarque, que agora pode ser entoado aos agentes políticos no Brasil: “♪♪ Se pensas que burlas as normas penais, insuflas agitas e gritas demais, a lei logo vai te abraçar infrator com seus braços de estivador. ♪♪”³⁴

O esvaziamento da importância da racionalidade jurídica, implica necessariamente na ascensão da política nos órgãos de controle. Todo político vai aonde a política está. A partir do momento que o Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas detiverem – como já detêm – o poder de vida e morte civil dos agentes políticos, assistiremos a crescente politização dos órgãos de controle, pois não nos basta mais o Direito para assegurar um mínimo de segurança jurídica, fazendo com que os controladores corram o risco de tornarem-se o que pretendem consertar: políticos.

Não por acaso estamos a verificar que a classe política completamente aturdida (e perdida) com esse estado de coisas, procure os órgãos de controle não como forma de aconselhar-se e bem direcionar suas ações administrativas, mas para pautar sua conduta pelos ditames dos órgãos de controle, tentando angariar a simpatia e o olhar clemente daqueles que a qualquer momento podem suprimi-los do exercício do poder, naquilo que em nosso último Capítulo denominaremos de: *estratégia de relacionamento informal interadministrativo*.

2.4. Os problemas na aplicação da teoria dos princípios no Brasil e suas conexões com o controle externo

Por certo não podemos impor as disfuncionalidades do controle externo como tributários a uma “teoria dos princípios”. Mas, certamente, é possível afirmarmos que a teoria dos princípios – do modo que absorvida em solo brasileiro – pode dar

34. O clipe e letra da música estão disponíveis em: [http://letras.mus.br/chico-buarque/45134/]. Acesso em: 27 de julho de 2015. A atualidade da canção é tamanha, que basta imaginarmos que se em vez de Hino de Duran, a música se intitulasse: Hino aos Políticos. Não se trata de mera coincidência. Guardadas as devidas proporções, a perseguição realizada na ditadura a direitos e liberdades aos opositores ao regime, agora, em plena democracia, encontra novas vítimas por vezes corporificada na figura dos políticos acusados de improbidade e corrupção. Se não é mais possível a tortura física, frequentemente viola-se sem qualquer fundamento jurídico consistente outros bens e valores fundamentais à dignidade da pessoa humana igualmente torturantes, a exemplo da generalização das prisões preventivas meramente antecipatórias da pena, além de afetar o exercício do cargo, bens e o próprio sustento (em face das limitações decorrente da suspensão de direitos políticos e inelegibilidade). O quadro é agravado porque a opinião pública anseia pela punição dos novos subversivos.

fundamento “jurídico” ao modo de concretização dos excessos de controle que estamos a criticar.

Os avanços no controle da Administração sob a égide da Constituição de 1988 não foram pequenos. A busca pelo conteúdo jurídico dos princípios constitucionais, a ideia que temos uma Constituição *para valer* e que devemos levar a Constituição *a sério*, com razão está no centro dos debates do constitucionalismo brasileiro.

O constitucionalismo jurídico contemporâneo, segundo Luigi Ferrajoli, pode ser denominado de constitucionalismo jusnaturalista e constitucionalismo juspositivista. Os defensores de uma concepção antijuspositivista nem sempre se consideram jusnaturalistas, mas não positivistas ou pós-positivista, adotando uma distinção estrutural entre regras e princípios, aproximados pelos princípios éticos-políticos das normas constitucionais, e distinção forte, qualitativa e estrutural entre princípios e regras. (FERRAJOLI, 2012, p. 17).³⁵

O papel do neoconstitucionalismo nesse debate tem lugar de destaque. Em que pesem as divergências sobre o que seja ser um neoconstitucionalista, e de muitos tentarem fugir do seu rótulo, podemos elencar (sem pretensão de ser exaustivo ou conclusivo), alguns pontos que lhe subjazem, como: 1) pretensão de superação do positivismo jurídico³⁶; 2) impossibilidade de resolver certos casos jurídicos pela

35. Importante ainda frisar na linha de Sérgio Urquhart Cademartori: “(...) o modelo garantista reivindica a recuperação pelo legislador de sua centralidade como fonte normativa, não sendo mais os juízes os encarregados de colmatar eventuais lacunas na ausência de concretização de direitos fundamentais sociais.” (CADEMARTORI; STRAPAZZON, 2012, p. 209).

36. Sobre velha questão do positivismo jurídico como causa dos males propagados pelo nacional-socialismo (argumento trazido por muitos juristas com finalidade de impor uma argumentação *reductio ad hitlerum*), lembremos que quem foi banido da Universidade de Colônia foi Hans Kelsen, e não Carl Schmitt, que recusou-se a assinar o abaixo-assinado para manter Kelsen na cátedra, sendo forte opositor ao positivismo jurídico por entender que outros valores como honra, lealdade e disciplina (e o “princípio da direção unitária”) é que deveriam prevalecer (DIMOULIS, 2006, p. 262), acusando o positivismo de proteger criminosos e sonegadores. A crítica continua a ser feita na atualidade por muitos juristas, e, acrescentamos nós, para além dos criminosos e sonegadores: os políticos. Em verdade, Carl Schmitt propôs mudar todo o direito sem que fosse necessário mudar lei alguma, posição teórica que exonera o positivismo jurídico da responsabilidade pelas barbáries cometidas na segunda grande guerra. *In verbis*: “En Alemania se puede ver hoy del modo mas claro en que medida ha llegado a su fin el tiempo del positivismo jurídico. En todas partes y en todos los campos de la vida jurídica penetran las llamadas «clausulas generales» en detrimento de la «seguridad» positivista: conceptos indeterminados de todo tipo, reenvíos a medidas y conceptos extralegales como buenas costumbres, lealtad y buena fe, exigibilidad y no-exigibilidad, razón suficiente, etcétera, que suponen una renuncia al fundamento del positivismo, a saber, la decisión legal, a la vez contenida y desvinculada de la norma. (...) En el momento en que conceptos como «lealtad y buena fe», «buenas costumbres», etc., se aplican no a una sociedad civil de tráfico

subsunção, aplicando-se a ponderação; 3) centralidade dos princípios constitucionais no sistema jurídico; 4) aproximação entre Direito e moral; 5) concepção do direito como prática jurídica confiada a atividade dos juízes (em convergência com o realismo e o neopandectismo do direito como “fato” em vez de direito como “norma”).

A expressão neoconstitucionalismo (POZZOLO, 1998) tem levado a alguns equívocos que podem ser bem sintetizados por Lenio Streck:

“Em linhas gerais, é possível afirmar que, na trilha do *neoconstitucionalismo*, percorremos um caminho que nos leva à jurisprudência de valoração e suas derivações axiológicas, temperada por elementos analítico-conceituais provenientes da ponderação alexyana.

Desse modo, esse belo epíteto – cunhado por um grupo de constitucionalistas espanhóis e italianos – embora tenha representado um importante passo para afirmação da força normativa da Constituição na Europa Continental, no Brasil, acabou por incentivar/institucionalizar uma recepção acrítica da jurisprudência dos valores, da teoria da argumentação de Robert Alexy (que cunhou o procedimento de ponderação com instrumento pretensamente racionalizador da decisão judicial) e do ativismo norte-americano.” (STRECK, 2012, p. 60-61).

Dimitri Dimoulis compreende o neoconstitucionalismo ou como i) sinônimo de constitucionalismo no sentido de levar-se a sério a constituição ou como ii) espécie de moralismo jurídico que decorre da modernização do jusnaturalismo.³⁷

individualista, sino al interés de la totalidad del pueblo, cambia de hecho todo el derecho sin que sea preciso que cambie una sola ley. Yo estoy, por tanto, convencido de que con esas cláusulas generales puede introducirse un nuevo modo de pensamiento jurídico. Ahora bien, no pueden ser utilizadas como mero correctivo del positivismo actual, sino que deben ser utilizadas como medios específicos de un nuevo tipo de pensar jurídico.” (SCHMITT, 1996, p. 67-68). A par do antisemitismo de Carl Schmitt e do seu papel de *Kronjurist* do III Reich de 1933 a 1936, muito de sua postura teórica deve-se à forte oposição ao liberalismo e crítica ao individualismo contratualista.

37. Sobre o tema assim entende Dimoulis: “Como independentemente da opção teórica que será feita por cada autor, é importante entender que a abordagem que parece se cristalizar em torno do termo neoconstitucionalismo deve escolher entre dois caminhos. Primeiro, considerar o termo como sinônimo do constitucionalismo, insistindo na necessidade de levar a sério a normatividade constitucional, tendo-se simplesmente uma nova geração de partidários do bicentenário movimento constitucionalista sem pretensão teórica própria. Segundo, considerar que o neoconstitucionalismo aplica os ensinamentos do moralismo jurídico no campo do direito constitucional, formulando uma proposta teórica baseada em análises das últimas décadas que modernizam o jusnaturalismo, rejeitando categoricamente o positivismo jurídico. Isso permite duvidar da utilidade de manter no vocabulário jurídico um termo que seria, na primeira hipótese, sinônimo do constitucionalismo tradicional e, na segunda hipótese, sinônimo (ou

Comumente, apontam-se como principais juristas “neoconstitucionalistas” Ronald Dworkin (princípios na sua dimensão de peso e de aplicação de regras nas hipóteses de tudo ou nada) e Robert Alexy. O rótulo é controverso e tanto Dworkin quanto Alexy provavelmente dele discordassem. Alexy partiu do modelo dworkiniano e o desenvolveu com fundamento na jurisprudência e na experiência do tribunal constitucional alemão. Para Alexy princípios são mandamentos de otimização e podem ser preenchidos em graus diferentes e tal preenchimento depende das possibilidades fáticas e jurídicas.³⁸

No Brasil existem sérios problemas na importação da teoria dos princípios. O primeiro foi que na teoria alexyana a ponderação dos princípios (com base na doutrina do tribunal constitucional alemão) foi pensada para limitar e racionalizar a ação dos juízes. No Brasil a mesma teoria passou a significar permissividade e liberdade ampla, geral e irrestrita dos magistrados e dos órgãos de controle externo. Passou-se acriticamente a “ponderar-se” tudo e diante da insatisfação do juiz quanto ao conteúdo normativo de uma regra, basta que invoque um princípio qualquer e chegue a um resultado que lhe apeteça.

O segundo problema é que raramente se utiliza dos métodos e dos filtros das máximas parciais da i) *adequação*, para passar-se ao exame da ii) *necessidade* e menos ainda se verifica na máxima parcial da iii) *proporcionalidade em sentido estrito* para utilizar-se do sopesamento como otimização da colisão de princípios. Segundo Alexy, a lei do sopesamento pode ser dividida em três passos. “No primeiro é avaliado o grau de afetação de um dos princípios. Depois, em um segundo passo, avalia-se a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve ser avaliado se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a afetação ou a não-satisfação do outro princípio.” (ALEXY, 2015, p. 588-594).

Isso levou os magistrados e os órgãos de controle a elegerem – de modo equívoco – um princípio da sua predileção subjetiva³⁹ (dentre eles o corifeu é o princípio

aplicação concreta) do moralismo jurídico. Mas em nenhum caso o neoconstitucionalismo adquire significado próprio e original. A regra da parcimônia, conhecida como ‘navalha de Ockham’, diz que os conceitos não devem se multiplicar além do necessário. Concluímos, portanto, que o termo neoconstitucionalismo é uma nova denominação utilizada para designar velhas práticas e crenças do mundo jurídico. Assim como todas as redundâncias o neoconstitucionalismo não pode ser considerado uma necessidade real.” (DIMOULIS, 2011).

38. Como preleciona Alexy: “(...) principles are norms commanding that something be realized to the highest degree that is actually and legally possible. Principles are therefore *optimization commands*. They can be fulfilled in different degrees. The mandatory degree of fulfilment depends not only on actual facts but also on legal possibilities.” (ALEXY, 2000, p. 295).
39. Estas justificações principiologias de ordem subjetiva são bem tratadas por José Sérgio Cristóvam: “Uma trágica espécie de ‘principiorragia’ faz jorrar princípios que passam a funcionar como

da moralidade⁴⁰), e com fundamento na norma parâmetro-principiológica escolhida, declararem a inconstitucionalidade de normas e aplicar sanções aos agentes públicos sem qualquer método interpretativo típico-sistemático.

Já a equivocada utilização da doutrina de Ronald Dworkin no Brasil, fez crer que os juízes teriam ampla discricionariedade na busca das melhores soluções ao caso concreto. Contudo, não é isso que propõe o autor em sua obra: *O império do direito*, pois os juízes estariam limitados a decidir em conformidade com “as exigências morais da comunidade”⁴¹. Em verdade Dworkin pretende restringir o papel do intérprete (DWORKIN, 2014).

Dworkin propõe a construção da interpretação com fundamento nos acréscimos em determinada tradição. Para tanto, concebe o famoso “romance em cadeia”, donde parte da hipótese que se diversos romancistas escreverem um mesmo livro a partir dos capítulos antecedentes, cada escritor deverá ter compromisso em fazer o melhor romance possível, portanto, não há ampla liberdade criativa. O mesmo ocorreria na aplicação do Direito (DWORKIN, 2014, p. 275-285).

A proposta dworkiana do romance em cadeia (em que trabalha o famoso *Conto de Natal de Dickens* e seu célebre personagem *Scrooge*) ao justificar que um romancista em cadeia deve continuar a escrever o conto tendo em consideração

genuínas ‘chaves mestras’ que abrem todas as portas (fundamentam decisões de todos os matizes), invadindo o discurso judicial sem a menor preocupação teórica e de argumentação racional. Parâmetros como razoabilidade e proporcionalidade viram ‘mantras de justificação’ para toda e qualquer subjetivismo judicial. Como que por um passe de mágica surgem novos princípios, obscuramente drenados de uma Constituição que cada vez mais é aquilo que os tribunais dizem ser e não o resultado da vontade normatizada do legislador constituinte. Não que o Judiciário não seja legítimo intérprete da ordem constitucional, mas isso não o autoriza a funcionar como constante e onisciente legislador constituinte positivo.” (CRISTÓVAM, 2019, p. 1.002-1.003).

40. O princípio da moralidade foi adequadamente tratado por Márcio Cammarosano que o vincula ao princípio da legalidade, no sentido de limitar sua leitura desconectada do sistema jurídico. (CAMMAROSANO, 2006). Thiago Marrara igualmente trata do conteúdo jurídico do princípio da moralidade e sua conexão com outros princípios jurídicos, defendendo sua autonomia. (MARRARA, 2012).

41. Segundo Dworkin “Aceitamos a integridade como um ideal político porque queremos tratar nossa comunidade política como uma comunidade de princípios, e os cidadãos de uma comunidade de princípios não têm por único objetivo princípios comuns, como se a uniformidade fosse tudo que desejassem, mas melhores princípios comuns que a política seja capaz de encontrar. A integridade é diferente da justiça e equidade, mas está ligada a elas da seguinte maneira: a integridade só faz sentido entre pessoas que querem também justiça e equidade. Assim, a escolha final de Hércules da interpretação que ele considera mais bem fundada em sua totalidade – mais equitativa e mais justa na correta relação – decorre do seu compromisso inicial com a integridade. Ele faz essa opção no momento e da maneira que a integridade tanto o permite como o exige, e portanto é totalmente enganoso dizer que ele abandonou o modelo de integridade exatamente nesse ponto.” (DWORKIN, 2014, p. 314).

seus primeiros parágrafos, nos parece problemática. Para demonstrar nossa crítica, basta que façamos a leitura dos primeiros capítulos de *Os Irmãos Karamázov*. Supondo que um romancista em cadeia tivesse de prosseguir o romance antes de saber da morte de *Fiódor Pavlovitch Karamázov* é certo que ninguém – ou muito poucos – ousariam matar um personagem tão impressionante, o que levaria, inexoravelmente, a um romance totalmente diferente. Claro que Dworkin refuta a crítica ao dizer que houve “deformação” do seu exemplo do romance em cadeia, argumentando que não se trata de um romance escrito por “um único autor”, de modo que a continuidade do romance deve adequar-se ao texto entregue pelos autores antecedentes (DWORKIN, 2014, p. 285-286). Mas divergir sobre o que significa respeitar os textos anteriores pode implicar em novos romances radicalmente diversos e com isso derruir a ideia de integridade.

Claro que o mérito da proposta dworkiana na busca da resposta correta é o compromisso com a integridade como *tarifa possível*, em contraponto com uma visão cética que abandonaria a busca de um projeto realizável (DWORKIN, 2014, p. 285). Todavia, a subjetividade do intérprete (ainda que engajado num projeto de integridade) não elimina a possibilidade de mais respostas, e com isso a fragilização lógica da proposta de Dworkin.

É certo que a Constituição e as leis permitem ao intérprete a busca de resposta mais adequada possível, mas isso não exclui a probabilidade de mais respostas corretas. Todavia, a possibilidade de mais respostas não permite inferir: *qualquer resposta*. A resposta constitucionalmente adequada pode até ser mais de uma⁴², todavia, a Constituição e as Leis têm texto e contexto, limites semânticos e sintáticos

42. Lênio Streck discorda da solução da melhor resposta dentre múltiplas possibilidades. Defende que resposta correta é dada sempre no caso concreto e que é possível encontrá-la numa cadeia de sentidos. *Verbis*: “Ou seja, de certo modo, o problema da tese da escolha da melhor resposta entre múltiplas possibilidades continua na subjetividade do intérprete, portanto, caudatária do paradigma da filosofia da consciência. É neste ponto que reside o problema principal da tese das múltiplas respostas e, quiçá, da melhor resposta. O ato interpretativo – que depende de uma pré-compreensão antecipadora – não é uma acoplagem de um significado a um significante, ou, para usar a linguagem tipicamente hermenêutica, não é uma acoplagem de sentido (ser) a um ente desnudo, que estaria à espera dessa operação.” (STRECK, 2011, p. 380). Para o jusfilósofo gaúcho “A resposta correta é, ao mesmo tempo, produto e produtor; é a síntese hermenêutica da *Sache selbst*, em que ocorre a fusão de horizontes (de onde surge algo que antes não havia). É onde se encontram integridade e coerência: a tradição filtrada/atravessada pela reconstrução linguística a partir do texto constitucional que representa o *locus privilegiado* do acontecer da atividade do jurista (*plus* normativo e qualificativo do texto constitucional compromissório e dirigente) e a garantia de que o intérprete está comprometido com a intersubjetividade que o coloca no interior de uma cadeia de sentidos: por isso ele não ‘dispõe’ dos sentidos (essa questão talvez seja a mais difícil para o intérprete do direito, formado em uma tradição filosófica de cariz solipsista).” (STRECK, 2011, p. 406).

que não podem ser simplesmente ignorados pelo intérprete. O tema dialoga com a questão do relativismo e da busca pela verdade no sentido epistemológico.⁴³

Também adequado esclarecer que para Dworkin a tese da resposta correta não descarta a possibilidade de uma pluralidade de respostas a serem juridicamente debatidas, como bem asseveram Luiz Henrique Urquhart Cademartori e Francisco Carlos Duarte:

“Desse modo a tese da resposta correta não combate a possibilidade de uma pluralidade de respostas que possam ser esgrimidas no campo do direito, combate, isto sim, o vazio ou carência de respostas a um dado problema que possa ser justificada em prol da discricionariedade do julgador à falta de instrumentos jurídicos suficiente para a solução do problema posto.” (CADEMARTORI; DUARTE, 2009, p. 122).

Ora, se as próprias ciências naturais já abandonaram o conceito de verdade (trabalhando, por exemplo, com o critério de falseabilidade de Popper) na primeira metade do século XX, não será o Direito quem pretenderá em pleno século XXI obter a resposta verdadeira ou correta.⁴⁴ Porém, isso não impede que se busque a verdade, tentando alcançar a resposta mais correta possível.

Quanto a Alexy, apesar de citado em verso e prosa em doutrina e jurisprudência nacional, a verdade é que dificilmente se verifica na prática judicial o emprego do método de ponderação por ele proposto, de modo a permitir e a possibilitar maior racionalidade às decisões. Boa parte dessa confusão se deve a uma falta de separação técnico-jurídica entre os princípios da proporcionalidade (que para Alexy é uma regra) e o princípio da razoabilidade.⁴⁵

43. A discussão na teoria do conhecimento foi bem trabalhada por Karl Popper: “Deve-se admitir, porém que há um cerne de verdade no ceticismo e no relativismo. O cerne de verdade é justamente o que não existe qualquer critério geral de verdade. Mas isto não abona a conclusão de que a escolha entre teorias concorrentes seja arbitrária. Significa meramente, muito simplesmente, que podemos sempre errar em nossa escolha — que podemos sempre não dar com a verdade, ou não atingir a verdade; que para nós não há certeza (nem mesmo conhecimento que seja altamente provável, como mostrei em vários lugares, por exemplo, no capítulo 10 de *Conjectures and Refutations*) que somos falíveis” (POPPER, 1987, p. 394). Ainda sobre o tema esclarece Popper: “Podemos estar mais ou menos certos de que uma proposição é verdadeira ou de que ela é falsa. Isso mostra claramente a distinção entre, de um lado, a certeza e, de outro, a verdade. A demonstrabilidade ou justificabilidade de uma proposição tem sua verdade como consequência, mas não o contrário: uma proposição pode concordar com fatos (ser verdadeira) sem que seja de algum modo justificável.” (POPPER, 2013, p. XXXI).

44. Noutra vertente epistemológica caminha Larry Laudan, no sentido de atribuir a ciência o papel de resolver problemas, não atribuindo-se verdade ou falsidade, devendo um complexo teórico aumentar a confiança na verdade ou probabilidade. (LAUDAN, 2011, p. 60-61).

45. Por todos, fazemos menção ao texto de Virgílio Afonso da Silva que bem assevera a distinção entre proporcionalidade e razoabilidade: “Mas, quando se fala, em um discurso jurídico, em

Por certo que na atividade cotidiana dos órgãos de controle, raramente se verifica qualquer preocupação em esclarecer ao destinatário da norma que “teoria dos princípios” quanto à validade e à aplicação das normas se está a ado. Todavia, isso é feito diuturnamente sem que muitas vezes os envolvidos na aplicação do Direito se deem conta disto.

Na esteira de Néviton Guedes, numa sociedade complexa com o natu agigantamento da função jurisdicional, impõem-se ao magistrado o dever i apenas de justificar sua decisão, mas de esclarecer as premissas que lhe dão s tentáculo.⁴⁶

princípio da razoabilidade ou em princípio ou regra da proporcionalidade, é evidente qu termos estão revestidos de uma conotação técnico-jurídica e não são mais sinônimos, pois pressam construções jurídicas diversas. Pode-se admitir que tenham objetivos semelhantes mas isso não autoriza o tratamento de ambos como sinônimos.” (SILVA, 2002, p. 28). Sc as distinções acerca do princípio da proporcionalidade e da proporcionalidade, relevan crítica de Humberto Ávila que trabalha estes princípios como *postulados*, asseverando: postulado da razoabilidade aplica-se, primeiro, como diretriz que exige a relação das r mas gerais com as individualidades do caso concreto, quer mostrando sob qual perspect a norma deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em virt de suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma geral. Segundo, como diretriz c exige uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, e reclamando a existência de um suporte empírico e adequado a qualquer ato jurídico, e demandando uma relação congruente entre a medida adotada e o fim que ela pretende at gir. Terceiro, como diretriz que exige a relação de equivalência entre duas grandezas. (... postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos em que exista uma relação de causalid entre um meio e um fim concretamente perceptível. A exigência de realização de vários fi todos constitucionalmente legitimados, implica a adoção de medidas adequadas, necessár e proporcionais em sentido estrito”. (ÁVILA, 2005, p. 131).

46. Acerca do tema explana Néviton Guedes: “A partir do Século XX, entretanto, a maneira conceber as tarefas do legislador e do juiz, ante o impacto de incontornáveis mudanças his ricas e sociais, foi também sofrendo inevitáveis alterações. Frente a um mundo cada vez m complexo em sua conformação e estrutura, não se podia mais esperar do legislador a capa dade de prever todas as possibilidades de casos concretos para encerrá-los em formulaç quase mágicas de normas abstratas, fazendo com que, necessariamente, a sua função fo concretizada em normas cada vez mais abertas e menos definitivas (*o caminho das regras po os princípios*) que acabam por conferir mais espaço para interpretações judiciais, de tal for a propiciar ao aplicador da norma uma melhor adaptação aos novos casos. Portanto, nes novo contexto, a função jurisdicional acaba por adquirir uma latitude indiscutivelmente m extensa. A interpretação da norma, aqui, é apenas um dos tortuosos caminhos a serem perc ridos na tarefa de aplicar normas jurídicas a casos complexos. Nesse espaço, tomará cada v mais importância o papel da argumentação no momento de concretização da regra de decisã Nesse novo momento, como o juiz não pode retirar automaticamente a sua decisão da norr geral, impõe-se-lhe como dever, de forma acentuada e crescente, a justificação não apenas, suas decisões, mas das próprias premissas (fundamentos) que as suportam (fundamentaç da fundamentação).” (GUEDES, 2012b).

Voltando à questão principiológica, o problema no inadequado exercício do controle externo sob uma perspectiva neoconstitucionalista é que tudo passa a ser uma questão de princípios. Esquecemos o real papel dos princípios que possuem caráter reflexivo, de abertura do sistema⁴⁷ ao seu (determinável) conteúdo jurídico. Assim, passou-se a utilizar a teoria dos princípios para solver problemas que dependem de regras. Mais que isso, no cotidiano dos tribunais, especialmente em improbidade administrativa, passou-se a desprezar as regras em nome dos princípios e a razão maior disso é porque a escolha (*à la carte*) dos princípios e a determinação do seu conteúdo jurídico, permite ao intérprete sentir-se “livre, leve e solto” para decidir como quiser.

No Brasil é especialmente grave o fenômeno do hiperprincipialismo⁴⁸, panprincipialismo⁴⁹, principiorragia, principiolatria, etc., em que cada vez mais princípios constitucionais e legais, explícitos ou implícitos, estimulam a fértil imaginação dos intérpretes e aplicadores das normas jurídicas, utilizando-os para fundamentar qualquer decisão, e com isso angariar pretensa juridicidade, mormente no tema que estamos a abordar acerca dos excessos do controle externo.

Tal prática fragiliza a teoria dos princípios pois o que serve para qualquer coisa, não serve para coisa alguma. Já começamos a produzir doutrina no Brasil cujo objetivo é exatamente combater tal equivocada compreensão dos princípios. Porém, é certo que ao colocarmos os princípios no lugar que lhes cabem no sistema, devemos cuidar para não cair no niilismo principiológico, esvaziando seu papel e força normativa. O adequado resgate das regras talvez possa remediar o excesso na utilização dos princípios como panaceia, todavia, sem renunciar à importância dos princípios no sistema jurídico.

A esse respeito vale transcrever as reflexões de Marcelo Neves:

“No caso brasileiro, o fascínio pelos princípios sugere a superioridade intrínseca destes em relação às regras. A essa compreensão subjaz a ideia de que as regras constitucionais (completas, quando já superadas as questões de exceções e eventual ponderação) podem ser afastadas por princípios constitucionais em

virtude da justiça inerente às decisões neles fundamentadas. Mas um modelo desse tipo implica uma negação fundamental de um dos aspectos do sistema jurídico que possibilita o processamento de decisões “justas”: a consistência. Um afastamento de regras cada vez que se invoque retoricamente um princípio em nome da justiça, em uma sociedade complexa com várias leituras possíveis dos princípios, serve antes à acomodação de interesses concretos e particulares, em detrimento da força normativa da Constituição”. (NEVES, 2013, p. 191-192).

E a propósito da fragilização do núcleo de princípios da constituição brasileira, preocupa que princípios como devido processo legal, contraditório, ampla defesa – núcleo do estado democrático de direito na tutela das liberdades – agora sejam sacrificados em nome de interesses “mais nobres” como *in dubio pro societate*, a proteção da moralidade administrativa, da efetiva punição dos corruptos, das prisões preventivas insubsistentes, da “condescendência” na obtenção de prova ilícita, das condenações penais e administrativas irrazoáveis, tudo em nome do novo *volksgeist* que permeia a sociedade brasileira.

Diante de tantas promessas a serem cumpridas pela Constituição da República e do justificado desejo por uma sociedade mais ética, menos violenta, mais justa e solidária, a equivocada percepção que o combate à criminalidade passa pelo enfraquecimento desses direitos e garantias fundamentais, abre o flanco para esfacelamento destas duras conquistas, fazendo que todos os cidadãos (enquanto potenciais criminosos) passem a sofrer as consequências do Estado plenipotenciário.

O papel da constituição como restrição foi bem abordada por Jon Elster:

“De acordo com John Potter Stockton, ‘constituições são correntes com as quais os homens se amarram em seus momentos de sanidade para que não morram por uma mão suicida em seu dia de frenesi.’⁵⁰ (...) De forma similar Friedrich Hayek cita a visão que uma constituição é um laço imposto por Pedro, quando sóbrio, sobre Pedro quando bêbado. Em uma declaração mais recente, Cass Sunstein escreve: ‘As estratégias de pré-compromisso constitucionais poderiam servir para superar a miopia ou a fraqueza da vontade da coletividade’”. (ELSTER, 2009, p. 120).

Portanto, o intérprete e os agentes controladores da Administração Pública não podem perder a dimensão da constituição como aquisição evolutiva (Niklas Luhmann⁵¹) evitando os riscos do hiperprincipialismo. O momento hipermora-

47. Como bem assinala Marcelo Neves: “Os princípios constitucionais, por implicarem certa distância do caso a decidir e uma relação mais flexível entre o antecedente e o consequente, são mais adequados a enfrentar a diversidade de expectativas normativas que circulam na sociedade. Por outro lado, os princípios apresentam-se subcomplexos perante o caso a decidir. As regras, em sua estruturação, mostram-se mais adequadas a oferecer fundamento imediato ao caso a decidir.” (NEVES, 2013, p. 118).

48. A esse respeito esclarece Carlos Ari Sundfeld: “Na emoção dos hiperprincípios livrescos, descritos de modo tão bonito e fácil nos manuais, os profissionais do direito administrativo brasileiro estão ignorando o direito positivo, desprezando o direito positivo e substituindo-se a ele.” (SUNDFELD, 2014, p. 180-181).

49. Acerca do panprincipialismo, destaca-se a doutrina de Lenio Streck (STRECK, 2012, p. 64-71).

50. “Constitutions are chains with which men bind themselves in their sane moments that they may not die by a suicidal hand in the day of their frenzy”. (FINN, 1991, p. 5).

51. Sobre o tema discorre Luhmann: “A própria Constituição deve interromper o círculo da auto-referenciabilidade, deve traduzir a simetria na assimetria. E alcançar esse resultado ao regular a produção do direito, inclusive a revisão da própria Constituição. Com o que ela constitui uma hierarquia de fontes jurídicas (tornadas possíveis no interior do sistema jurídico). Distingue, por exemplo, o direito constitucional (a si própria) do outro direito. Disciplina e delimita as

lista pelo qual passa a sociedade brasileira — e precisa passar para que aprenda com seus erros e acertos — impõem o resgate da tradição liberal e democrática do constitucionalismo brasileiro, como bem assevera Clèmerson Merlin Clève e Bruno Meneses Lorenzetto:

“Em suma, não é possível entender de maneira fragmentada as tradições que conformam o desenho institucional brasileiro. Se, por um lado, floresce demanda pelo robustecimento do republicanismo, das virtudes cívicas, da moralidade pública, por outro lado, as tradições liberal e democrática também presentes em nosso constitucionalismo não podem ser esquecidas” (CLÈVE; LORENZETTO, 2014, p. 134).

O problema metodológico inerente a esse debate é bem apontado por J. J. Canotilho, que aponta os riscos de um tribunal constitucional fundar suas decisões a partir da constituição não como um *sistema de normas* mas como uma *ordem de valores*, correndo-se o risco da visão paternalista e moralizante da jurisdição constitucional.⁵²

Nesse cenário, defende José Sérgio Cristóvam a *retomada da deferência* às regras como modo de concretizar-se a *legalidade democrática* e a aplicação apenas *subsidiária e excepcional do modelo ponderacionista* com balizas bem definidas, buscando a supremacia da Constituição e a defesa dos direitos fundamentais, é medida que se impõe (CRISTÓVAM, 2019, p. 1.018).

2.5. Conclusões acerca das premissas ideológicas do controle externo

A longo deste Capítulo, procuramos compreender as premissas ideológicas que norteiam o controle externo potencialmente produtoras de disfunções e de

possibilidades de delegação. No mesmo ato (embora com outras disposições) ordena a auto-descrição do sistema jurídico e lhe oferece, no mínimo, os pontos de apoio. A constituição indica, por exemplo, os valores em relação aos quais o direito é funcional. Essa indicação é também traduzida de uma forma assimétrica logicamente infundável. Em primeiro lugar vale o valor, assim pelo menos parece, e depois os instrumentos da sua realização.” (LUHMANN, [s.d.]).

52. De acordo com J. J. Gomes Canotilho: “A teoria da ordem de valores, que os autores associam à *teoria da integração* de Smend e à *filosofia de valores*, procura um sistema de garantias sem lacunas a partir da objectivação dos direitos fundamentais. Só que, como já várias vezes pusemos em relevo, ela é uma teoria perigosa: (1) a indagação da ordem de valores, através de um pretense método científico-espiritual, pode conduzir a uma ordem e a uma hierarquia de valores, caracterizadamente subjectiva, sem qualquer apoio em critérios ou medidas de relevância objectiva; (2) a ordem de valores tenta transformar os direitos fundamentais num *sistema fechado*, separado do resto da constituição; (3) a *ordem de valores* abre o caminho para a interpretação dos direitos fundamentais desembocar numa *intuição espiritual*, conducente a uma *tiranía de valores*, estática e decisionista”. (CANOTILHO, 2003, p. 1.397-1.398).

medo nos agentes públicos. Para demonstrá-la, utilizamo-nos da recente pesquisa da AMB (*Quem somos: a magistratura que queremos*) e situamos os órgãos de controle como sistema de *inputs* e *outputs* com a percepção da classe política na sociedade, e, no afã de darem respostas aos episódios de corrupção divulgados pela mídia, tendem a ter atitude pouco deferencial com os gestores públicos, impondo seu parâmetro moral mesmo que destituído de fundamento normativo, de modo a interferirem no exercício de típica função administrativa.

Finalmente, verificamos os graves problemas da aplicação da teoria dos princípios no Brasil, o que leva a inexoráveis disfuncionalidades no sentido de dar pretense fundamento jurídico a decisões de ordem puramente subjetivas mas que se servem do ponderacionismo excessivo e equivocado, o que leva a decisões despidas de racionalidade que afetam diretamente os agentes públicos e, portanto, capazes de gerar medo no processo de tomada de decisão, sendo fundamental resgatarmos o papel das regras e a utilização comedida da ponderação quando assim exigir o sistema.

No próximo Capítulo iremos nos debruçar sobre a casuística do controle externo nas ações de improbidade, nos tribunais de contas e na Justiça Eleitoral com o fito apontar os principais problemas dessas formas de controle, de modo a demonstrar através de dados empíricos as disfuncionalidades aqui apontadas e porque há razões que sobrelevam o risco e podem levar ao medo e à fuga da responsabilização dos administradores públicos.

Capítulo 5

Risco na administração pública e estratégias de fuga da responsabilização

Confira vídeo exclusivo de
apresentação do capítulo



SUMÁRIO: 5.1. Conceito operacional de risco e conceitos afins: perigo, risco residual, probabilidade e possibilidade. 5.2. O risco de responsabilização dos agentes públicos. 5.3. Interações entre risco e medo: as consequências do medo no processo de tomada de decisão. 5.4. Os agentes públicos nos mundos da fuga da responsabilização. 5.5. Estratégias de fuga da responsabilização: considerações preliminares. 5.6. Tipos de estratégias de fuga da responsabilização. 5.6.1. Estratégias de manipulação. 5.6.2. Estratégias de atuação. 5.6.2.1. Delegação. 5.6.2.2. Reorganização defensiva. 5.6.2.3. Coletivização das decisões. 5.6.2.4. Governo pelo mercado. 5.6.3. Estratégias de política pública ou estratégias operacionais. 5.6.3.1. Protocolização. 5.6.3.2. Gregarismo. 5.6.3.3. Individualização da responsabilização ou eleição de bode expiatório. 5.6.3.4. Inação ou imobilismo decisório: a paralisia administrativa. 5.6.4. Estratégias de judicialização ou substituição decisória externa. 5.6.5. Estratégia de relacionamento informal interadministrativo. 5.6.6. Estratégia de Blindagem Patrimonial. 5.7. Considerações finais: as estratégias de fuga da responsabilização são algo positivo ou negativo?. 5.7.1. Efeitos positivos. 5.7.2. Efeitos negativos.

5.1. Conceito operacional de risco e conceitos afins: perigo, risco residual, probabilidade e possibilidade

Para bem compreendermos o contexto do risco na administração pública, especialmente o *risco de responsabilização*, faz-se necessário compreendermos o que entendemos por risco e seus conceitos afins.

O conceito de risco tem acompanhado e se desenvolvido nas mais diversas áreas do conhecimento humano. A crescente percepção do risco de toda atividade humana e mesmo os riscos naturais a que estamos sujeitos têm impulsionado seu estudo nas mais diversas ciências. Da astronomia, geologia, sociologia, engenharia, medicina etc. nenhum ramo do saber está imune à noção de risco e às mudanças comportamentais e técnicas dele decorrentes.¹

1. Acerca do aumento dos riscos na sociedade contemporânea e da convergência de riscos, valem as considerações de Richard Posner: "The risks of global catastrophe are greater and more numerous than is commonly supposed, and they are growing, probably rapidly. They are growing for several reasons: the increasing rate of technological advance - for a number of the catastrophic risks are created or exacerbated by science and its technological and industrial applications (including such humble ones as the internal combustion engine), the growth of the world economy and world population (both, in part, moreover, indirect consequences of

Como nosso objetivo é trabalhar o risco dentro das ciências sociais, especialmente o Direito — que cada vez mais tem se ocupado do conceito de risco — impõe-se a referência ao trabalho do sociólogo Ulrich Beck como importante marco teórico na contextualização do risco naquilo que designou de *sociedade de risco* (BECK, 1992)². O fenômeno do risco é velho conhecido do Direito (v.g., responsabilidade civil do estado pelo *risco administrativo*), mas, hodiernamente, vem apresentando novas facetas³, mormente no Direito Ambiental, que se ocupa do risco ambiental diante das profundas intervenções do homem nos bens ambientais naturais.⁴

technological progress); and the rise of apocalyptic global terrorism. And the risks are, to a degree, convergent or mutually reinforcing. For example, global warming contributes to loss of biodiversity, an asteroid collision could precipitate catastrophic global warming and cause mass extinctions, and cyberterrorism could be employed to facilitate terrorist attacks with weapons of mass destruction" (POSNER, 2004, p. 245).

2. Como bem esclarece José Esteve Pardo, a obra de Beck não faz uma abordagem direta do Direito Público ou do Direito Administrativo, mas centra sua análise nas transformações da sociedade contemporânea, o que, certamente, afeta nosso sistema jurídico: "No existe propiamente una aportación de Ulrich Beck al Derecho público, menos aún al Derecho administrativo, si por tal aportación entendemos estudios o análisis suyos centrados en estas materias. (...) No hay en su obra una sociología del Derecho ni de la Administración, porque ha de centrar su atención en esas transformaciones profundas de la sociedad y sus referencias de las que habrá de salir una nueva configuración de sujetos y relaciones que apenas podemos avizorar. La principal y relevante aportación de Ulrich Beck se sitúa precisamente ahí, en hacernos bien visibles las profundas transformaciones de la sociedad y en ofrecernos una perspectiva desde la que podemos contemplar como esas transformaciones están afectando a muchas instituciones y principios de nuestro sistema jurídico y constitucional al variar los presupuestos y referencias sobre los que se levantaron" (PARDO, 2016, p. 96-97).
3. O conceito de *sociedade de risco* proposto por Beck faz referência a uma sociedade sujeita ao aumento e ao surgimento de novos perigos, cujas dimensões podem abalar sua sobrevivência.
4. Acerca do tema, calham as reflexões de Frank Furedi: "Safety consciousness is not simply the direct consequence of the growth of prosperity. Society's obsession with safety has also gained momentum through the growth of scepticism towards innovation, change, and experimentation. Throughout modern times, people looked to medicine, science, and technology to make their lives safer. They still do, of course. But there is now a powerful mood of suspicion towards innovation and change. The very term 'human intervention' has acquired negative connotations. Terms like 'human impact', 'human intervention', and 'ecological footprint' convey a negative sense of folly and destruction. Human intervention has always been associated with the belief that its positive consequences outweighed its downside. This modernist orientation has given way to a more pessimistic account wherein human intervention is associated with loss as much as gain, and the former is increasingly seen to outweigh the latter. Rather than serving as a solution to our problems, new technology is often indicted for its potential to increase the power of human destructiveness. Former American Vice-President Al Gore expressed this concern when he warned that the 'power of technologies now at our disposal vastly magnifies the impact each individual can have on the natural world'" (FUREDI, 2009, p. 217).

O trabalho de Beck revelou não apenas o lado progressista, mas também o lado mais ameaçador da modernidade,⁵ com o aumento dos perigos com que a nossa sociedade se depara cotidianamente. Ao lado dos efeitos benéficos da técnica, também nos confrontamos com a crescente escalada de riscos, dantes inimagináveis, dando início a uma nova percepção de modernidade (MENDES, 2016, p. 118).

O conceito de risco no direito é um conceito jurídico indeterminado, pois seu conteúdo e extensão não são identificáveis *a priori*.⁶ Sua polissemia (multiplicidade de sentido), vaguidade (informação ampla e compreensão escassa); ambiguidade (refere-se a vários elementos no contexto em que é inserido) e porosidade (trata-se de um conceito que pode ser preenchido ou esvaziado, a depender do caso concreto) fazem do risco um conceito jurídico indeterminado.⁷

A respeito do tema dos conceitos indeterminados, importantes as considerações de Sérvulo Correia, no sentido que não se deve confundir conceitos indeterminados com conceitos que suscitem dificuldade de interpretação. Afinal, todo conceito tem certa imprecisão condicionada pela linguagem, que demanda argumentação para explicitar seu conteúdo. A verdadeira indeterminação consiste na *avaliação e valoração* da situação concreta. Trata-se de juízo de *prognose* sobre como uma pessoa poderá atuar futuramente, *a futura utilidade de uma coisa ou o futuro desenrolar de um processo social*. Desse modo, o conceito jurídico indeterminado está fundado em método *causal-teorético*, e não *teorético-discursivo*, de

5. Acerca dos riscos da modernidade, destaca Ulrich Beck: "The concept of risk is directly bound to the concept of reflexive modernization. Risk may be defined as a systematic way of dealing with hazards and insecurities induced and introduced by modernization itself. Risks, as opposed to older dangers, are consequences which relate to the threatening force of modernization and to its globalization of doubt. They are politically reflexive" (BECK, 1992, p. 21).
6. Para adequada delimitação da ideia de conceito indeterminado, servimo-nos do entendimento de Antônio Manuel Cordeiro: "A ideia de conceito indeterminado foi utilizada já neste estudo. Tal característica ocorre sempre que um conceito não permita comunicações claras quanto ao seu conteúdo, por polissemia, vaguidade, ambiguidade, porosidade ou esvaziamento: polissemia quando tenha vários sentidos, vaguidade quando permita uma informação de: extensão larga e compreensão escassa, ambiguidade quando possa reportar-se a mais de um dos elementos integrados na proposição onde o conceito se insira, porosidade quando ocorra uma evolução semântica com todo um percurso onde o sentido do. Termo se deva encontrar e esvaziamento quando falte qualquer sentido útil" (CORDEIRO, 2013, p. 1.176-1.177).
7. Nesse sentido, caminha Pedro Melo: "Atento o exposto, isto é, por um lado, em face da ausência de um conceito normativo de risco genérica e uniformemente aplicável em todos os domínios do Direito e, por outro lado, em face das diversas configurações doutrinárias sobre a noção de risco, não apenas se reforça a ideia inicial de que o conceito de risco é multifacetado e, nessa medida, difuso, ambíguo, desconhecido, como se robustece consequentemente a importância de ser recortado um conceito jurídico operativo de risco" (MELO, 2011, p. 65).

modo que, para se aplicar a norma jurídica, deve-se avaliar a situação concreta (CORREIA, 1987, p. 474).

Como assevera Carla Amado Gomes, o conceito de risco passa pela *probabilidade* da sua ocorrência e seu *potencial lesivo*:

"O risco é um perigo pressentido, mas não comprovado; o perigo é um risco de altíssima probabilidade. A fronteira entre os dois é, teoricamente, a da previsibilidade, que se debate com o ineliminável obstáculo da finitude do conhecimento humano."

Falar de risco é, por isso, falar de incerteza. Incerteza introduzida pela técnica, incerteza geradora de imprevisibilidade, incerteza convertida em problema jurídico. A dificuldade de previsão pode incidir sobre a verificação do próprio fenómeno, sobre o momento da sua eclosão, sobre o tipo de efeitos que esta provocará, sobre o alcance destes efeitos, sobre o seu potencial lesivo. Por outras palavras, pode dizer-se que o risco se desdobra em dois elementos: a probabilidade de ocorrência de um evento, por um lado, e o potencial lesivo deste, por outro lado." (GOMES, 2007, p. 226-227)

Concordamos com a ideia de que, quando estamos diante de uma probabilidade elevada, estamos mais próximos da noção de perigo.⁸ Portanto, o conceito de risco implica menor probabilidade que o de perigo (GOMES, 2007, p. 228).

Richard Posner realiza a distinção entre *risco* e *incerteza*⁹. O primeiro pode ser estimado tendo por base a frequência em que pode ocorrer, já a incerteza não pode

8. Sobre o tema, posiciona-se Pedro Melo: "Ainda assim, apesar da fronteira entre estes conceitos ser ténue, parece-nos existir uma diferença de natureza ou, pelo menos, de grau, que habilita a uma distinção conceptual entre 'risco' e 'perigo'. Nesta conformidade, dir-se-á que se em ambos os casos estamos perante eventos incertos, no caso do risco existe apenas uma possibilidade de ocorrência dos mesmos, enquanto que no caso do perigo essa ocorrência prefigura-se como provável ou até como muito provável. Assim, num caso (risco) temos um evento incerto e de concretização (apenas) possível, e, noutro caso (perigo), temos um evento incerto e de concretização provável ou inclusivamente muito provável (probabilidade esta que se baseará em juízos de experiência de situações semelhantes, 'lugares paralelos', ou em dados factuais e científicos relativamente seguros) (MELO, 2011, p. 72).

9. This point is illuminated by the old distinction between "risk" and "uncertainty," where the former refers to a probability that can be estimated, whether on the basis of observed frequency or of theory, and the latter to a probability that cannot be estimated. Uncertainty in this sense does not, as one might expect, paralyze decision making. We could not function without making decisions in the face of uncertainty. We do that all the time by assigning, usually implicitly, an intuitive probability (what statisticians call a "subjective" probability) to the uncertain event. But it is one thing to act, and another to establish the need to act by conducting fruitful cost-benefit analyses, or using other rational decision-making methods, when the costs or benefits (or both) are uncertain because they are probabilistic and the probabilities are not quantifiable, even approximately" (POSNER, 2004, p. 171-172).

ser estimada em termos probabilísticos. Portanto, a incerteza gera paralisia de sória, pois não se sabe o que esperar. Mas uma coisa é agir, e outra, estabelece a necessidade de agir tendo por parâmetro a relação de custo-benefício (POSNER, 2004, p. 171-172).

Diante da proximidade dos conceitos de *risco* e *perigo*, ora nos deparamos com um critério quantitativo, ora com uma perspectiva qualitativa. Na óptica quantitativa, o grau de probabilidade do evento é o grande diferenciador entre perigo e risco. Já na tese qualitativa, tem-se duas vertentes. Uma tripartite: 1) *perigo* = *risco intolerável*; 2) *risco em sentido estrito* = *risco intolerável*; 3) *risco residual* = *risco tolerável*. Outro modelo é o bipartite: *riscos toleráveis versus riscos intoleráveis*. De toda sorte, a diferenciação quantitativa não é de todo excluída da perspectiva qualitativa, sendo mais defensável a tese de que não há oposição entre risco e perigo, mas apenas graus de probabilidade distintos (GOMES, 2007, p. 226-234).

Também importante trazermos o conceito de risco residual, que reside no risco de *baixa potencialidade lesiva*, desobrigado da adoção de medidas de prevenção de riscos, devendo ser socialmente tolerado (GOMES, 2007, p. 234).

A despeito da multifacetada compreensão do conceito de risco a depender de cada ramo do saber em que esteja inserido, neste trabalho adotamos o seguinte conceito operacional: *Risco na Administração Pública é toda incerteza que pode afetar a atividade administrativa tendo por consequência impactos negativos ou positivos nos objetivos por ela pretendidos.*

Outro ponto a merecer atenção é que, embora no Direito nos ocupemos mais dos efeitos "negativos" do risco — e, de fato, aí reside o fio condutor de nosso trabalho — ao enfrentar as disfunções e o medo com que se deparam os gestores públicos diante do risco de sua decisão, nada impede que possamos abordar efeitos "positivos" ou favoráveis do risco, que, especialmente nos contratos de obra pública, podem ter efeitos muito interessantes para fins de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Os riscos positivos permitem maximizar as oportunidades.

Exemplo de risco positivo pode ocorrer nas obras de infraestrutura, em que, durante a perfuração de um túnel, a rocha pode apresentar grau de dureza inferior

10. Nesse sentido, a contribuição de Carla Amado Gomes: "Propendemos, pois, para concordar com OSSENBUHL, quando afirma que a noção de risco não se opõe à de perigo, mas antes constitui uma evolução desta para domínios de crescente incerteza da determinação dos pressupostos de facto. Esta adesão não põe em causa a reserva de lei, na medida em que só aceitamos a utilização da norma habilitante de defesa de perigos em situações de risco quando o grau de probabilidade seja suficientemente alto e na medida em que o poder de ingerência não fira intoleravelmente a esfera jurídica dos particulares. Claro que esta solução, especialmente útil em períodos de transição, tende a esbater-se no médio e longo prazos, assim que o legislador identifique os riscos e proponha abordagens procedimentais específicas para os avaliar e gerir" (GOMES, 2007, p. 233).

às indicadas nas amostras geológicas iniciais, implicando “risco positivo” da execução do contrato por ser mais favorável ao contratado e demandar reequilíbrio contratual em prol da Administração (MELO, 2011, p. 72-74).

Também não há que se confundir a *probabilidade* com *possibilidade* de risco. Afinal, o conceito de probabilidade ocorre numa escala de até 100%. Já o conceito de possibilidade é binário, ou 0 ou 1, correspondendo a extremos e com pouca utilidade para fins de estabelecimento de estratégias de prevenção e riscos (TORRES, 2015, p. 12-13). Nessa senda, os gestores dedicam maior atenção a riscos que têm alta probabilidade de ocorrer, com altos impactos deles decorrentes, pois são riscos de grau de incerteza mais baixo diante da alta probabilidade de ocorrerem (TORRES, 2015, p. 10).¹¹

Na esteira da ISO 31.000, *risco é o efeito da incerteza em determinada atividade, traduzindo-se no binômio probabilidade versus impacto. Risco envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto para perdas como para ganhos.*

5.2. O risco de responsabilização dos agentes públicos

Este livro quer chamar atenção a um tipo de risco pouco estudado no âmbito da Administração Pública e do Direito Administrativo. Trata-se do *risco de responsabilização dos agentes públicos*. Essa espécie de risco pode ser definida como: *toda incerteza que pode implicar a responsabilização administrativa, civil, penal ou política dos agentes públicos pelo exercício de suas funções, especialmente as decorrentes da atividade decisória.*

Se fôssemos compreender esse tipo de risco na concepção de Ulrich Beck, poderíamos enquadrá-lo na noção de *risco tradicional* (enquanto risco pessoal), eis

11. Elisabeth Fischer destaca o relevante papel da Administração na avaliação de riscos num contexto entre uma perspectiva ciência (racional-instrumental) e democracia (deliberativo-constitutivo), alertando que esse debate polarizado, por vezes, oblitera a adequada percepção do tema: “What the science/democracy dichotomy has really blinded us all to is that technological risk evaluation is an activity of public administration. In other words, what this book has shown is that the science/democracy dichotomy is not only irrelevant but also an obstructive dichotomy. Thus, for example, much of the analysis of the BSE crisis has been so focused on demarcating the line between science and democracy that most commentators have ignored the fact that decisionmaking was the product of public administration and that there exists one of the most comprehensive studies of administrative decision-making to prove that fact. Likewise, in chapter five I illustrated how the dichotomy is distorting understandings about the World Trade Organization (WTO) Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement). If I have one hope for this book it is that it moves debate beyond much of the fruitless discourse that is presently being carried out. That leads me on to the real starting point of this book—public administration. What can be seen in each of these case studies is that some form of public administration plays a central role in technological risk evaluation” (FISHER, 2007, p. 245-246).

que não se trata de *risco moderno* que afeta globalmente nossa civilização e cujos processos causais são de difícil identificação e fruto dos avanços tecnológicos. Trata-se da transformação da sociedade industrial na modernidade reflexiva que afeta os mais variados campos do saber e da vida social (BECK, 1992, p. 21).

Não temos por objetivo pesquisar as manifestações mais usuais do risco ou sua prevenção no campo da técnica ou os impactos das novas tecnologias na sociedade contemporânea. Tampouco os riscos ambientais – terreno em que a noção de risco está assaz desenvolvida – será por nós abordado.

É certo que há riscos nas decisões administrativas inerentes por adotar-se esta ou aquela política pública; também há riscos em implementar medidas de prevenção que possam evitar ou minimizar riscos a que está exposta a sociedade; nessas hipóteses, está-se diante de *riscos públicos*, pois se trata de tarefas típicas do Estado pós-liberal, quer como fiscal das atividades desenvolvidas por particulares, quer de suas próprias atividades.

O *risco de responsabilização dos agentes públicos* que ora investigamos não é costumeiramente tratado na temática dos riscos públicos nem na gestão de riscos. Os chamados *riscos legais*¹² a que estão sujeitas as organizações pelo malferimento das normas jurídicas no exercício de suas atividades ou funções e a consequente responsabilização dos seus integrantes, tangenciam nossa abordagem teórica sobre o tema, visto que riscos legais podem ser detectados no processo de gestão de riscos e podem implicar responsabilização dos agentes envolvidos.

12. Sobre o conceito de riscos legais, esclarece Tobias Mahler: “In summary, risk is the combination of the probability of an event and its consequences. A risk is a legal risk if its source involves a legal norm. Thus, the risk needs to be the manifestation of a legal norm’s potential detriment. Both factual and legal uncertainty may influence legal risk” (MAHLER, 2007, p. 21). Igualmente define Roger McCormick: “Legal risk is a particular kind of risk. It is commonly understood to relate to the risk of being sued or being the subject of a claim or proceedings due to some infringement of laws or regulations, or the commission of a tort such as negligence or some other act giving rise to civil liability (referred to as ‘Type 1 risks’ in this book). However, in the context of the financial markets, the phrase is also frequently used to mean the risk of technical defects in the manner in which a transaction is carried out, resulting in loss, sometimes very serious financial loss, for those that put money at risk in the transaction. (We shall call that kind of risk a ‘Type 2 risk’)” (MCCORMICK, 2006, p. 10). Acerca da definição de risco legal na União Europeia, valem as considerações de Aurélien Raccach: “... we may sketch a definition of legal risk as the prejudicial occurrence arising from an unclear, imprecise or uncertain normative provision imposing obligations to an individual, a company or an authority, which would be inequitable or financially unreliable. The legal risk management done by public authorities and companies consists, therefore, in identifying, assessing and anticipating any potential legal risk before it occurs. Once it occurs, it becomes an infringement that may be judged by the competent jurisdictions to determine the respective liabilities. Decision makers are thus raising a major issue to ensure the compliance and effectiveness of EU law (RACCAH, 2016, p. 20-21).

Mas não há que se confundir o risco de responsabilização dos agentes públicos e suas interações com o medo e técnicas de fuga da responsabilização com os riscos legais normalmente identificados no processo de gestão de riscos. Todavia, isso não impede que vejamos pontos de contato entre essas categorias. Com efeito, a adequada identificação de riscos legais pode evitar a responsabilização tanto da organização como daqueles envolvidos no processo decisório. Nesse sentido, a adoção nas organizações de gestão de riscos legais pode fazer parte das estratégias de evasão da responsabilização do modo que estamos a enfrentar.

Mas há claras diferenças. No processo de gestão de riscos, a identificação, avaliação e tratamento e monitoramento dos riscos legais nada têm de disfuncional. Muito pelo contrário. No processo de gestão de riscos no âmbito do setor público — mormente dos riscos legais que podem redundar em responsabilização individual —, os riscos são enfrentados abertamente, e através de uma política e um sistema de gestão de riscos se pode implementar mecanismos visando definir a competência e a responsabilidade dos gestores de modo organizado, permitindo adequada tomada de decisão e mesmo da corresponsabilidade dentro de determinada hierarquia funcional.

Já o fenômeno do risco de responsabilização dos agentes públicos decorrente do controle externo disfuncional e as respectivas estratégias dissuasórias aqui tratadas, por vezes, são enfrentados de modo intuitivo e instintivo, pouco ou nada transparente, cuja finalidade precípua não é a gestão de riscos, mas evitar a possibilidade de responsabilização individual pela tomada de decisão, nem que para isso se procure nada decidir, ou transferir a terceiros os ônus da decisão, sem a preocupação de tratar riscos sistematicamente.

Como se pode perceber, muitas das estratégias de fuga da responsabilização são disfuncionais, e o são porque ainda carecemos de uma cultura de gerir de modo transparente e republicano esses riscos, a exemplo de um sistema de gestão de riscos. Ainda que adequadamente implementada a gestão de riscos, esta mostra-se insuficiente para garantir ao agente público segurança para definir os limites de sua responsabilização. Isso decorre diretamente do exercício do hipercontrole externo, cuja racionalidade não é previsível, maximizando o medo do agente em ser responsabilizado.

Tentaremos demonstrar que o risco da responsabilização pessoal do agente público por decisões administrativas é muito mais relevante do que normalmente pensam os estudiosos da temática do risco. Seu impacto na decisão administrativa é certamente muito maior do que se imagina, pois dificilmente o agente consegue dissociar de sua situação pessoal e eventuais consequências jurídicas em sua esfera de direitos subjetivos.¹³ Em certas situações-limite, tendo de escolher entre

seu próprio bem e o da coletividade, o agente até pode decidir em prol do bem comum assumindo riscos pessoais, mas há sérias controvérsias sobre se tal proceder seja a regra.

Exemplo de decisão em prol da coletividade em detrimento do próprio bem foi a decisão tomada por Stanislav Petrov, conhecido como: *o homem que salvou o mundo*, no episódio em que ignorou o alerta de ataque nuclear norte-americano em 1983 indicado pelos equipamentos soviéticos, deixando deflagrar conflito nuclear. Inicialmente, recebeu reprimenda do governo soviético, mas, depois, foi reconhecido como herói. Igualmente, é possível identificar situações envolvendo agentes da segurança pública que põem em risco a própria vida na defesa de civis. Mas isso não é a regra nas decisões tomadas nas estruturas burocráticas. Nesses casos, o agente sopesa os riscos de responsabilização a que está sujeito, pois isso pode custar-lhe seus bens por demais valiosos: a liberdade, o patrimônio e o cargo.

Os agentes já estão ou deveriam estar acostumados a arcar com o ônus da responsabilização por seus atos, o que leva — ao menos aparentemente — a concluir que não estamos diante de qualquer novidade. Afinal, não se pode presumir que o exercício de qualquer múnus público possa dar-se de modo irresponsável. Qualquer agente público na forma republicana de governo exerce suas funções alicerçado na ideia de *periodicidade, eletividade e responsabilidade* (ATALIBA, 1998). Se essa premissa é verdadeira, o que há de novo?

É que, no Brasil, o risco de os agentes públicos ordenarem despesas públicas ou tomar decisões administrativas é muito mais elevado do que em outros países. A probabilidade de eventual responsabilização por essas decisões é extremamente elevada. Isso decorre diretamente do controle externo disfuncional. Este trabalho procura demonstrar que hipertrofia da responsabilidade civil dos gestores públicos está a adquirir aspectos dantes inobservados ou mesmo inexistentes.

decorrente, põe em evidência exatamente o que estamos a destacar em nosso trabalho: que as pessoas têm aversão ao risco que lhes dizem respeito, não a riscos gerais: "My initial argument is that in its strongest forms, the Precautionary Principle is literally incoherent, and for one reason: There are risks on all sides of social situations. It is therefore paralyzing; it forbids the very steps that it requires. Because risks are on all sides, the Precautionary Principle forbids action, inaction, and everything in between. Consider the question of what societies should do about genetic engineering, nuclear power, and terrorism. Aggressive steps, designed to control the underlying risks, seem to be compelled by the Precautionary Principle. But those very steps run afoul of the same principle, because each of them creates new risks of its own. It follows that many people who are described as risk averse are, in reality, no such thing. They are averse to particular risks, not to risks in general. Someone who is averse to the risks of flying might well be unconcerned with the risks of driving; someone who seeks to avoid the risks associated with medication probably disregards the risks associated with letting nature take its course; those who fear the risks associated with pesticides are likely to be indifferent to the risks associated with organic foods" (SUNSTEIN, 2003, p. 4-5).

13. Acerca do ponto, parecem-nos muito interessantes as reflexões de Cass Sunstein. Além de fazer uma crítica quanto à incoerência do princípio da precaução e o imobilismo dele

O incremento da responsabilidade civil e administrativa está inserido num ambiente bem mais amplo da *modernidade reflexiva* — no sentido de *autoconfrontação*, e não no sentido de *meditação* ou *reflexão* (BECK, 1997, p. 16) —, que alterou os parâmetros tradicionais da sociedade como concebidos no início do século XX. A expansão e o aumento da responsabilidade civil não apenas dos agentes públicos, mas da adoção e ampliação da responsabilidade objetiva mesmo nas relações privadas (a exemplo da *teoria do risco* decorrente da atividade empresarial), mas que hodiernamente está a criar um cenário de hiper-responsabilização (v.g. indenizações punitivas)¹⁴ cujas consequências ainda são de difícil apreensão, mas que produz alguns efeitos deletérios.

Essa mudança de parâmetros, aliada a uma perspectiva de controle punitivista dos agentes públicos, está a gerar um novo fenômeno em termos de responsabilização. Passa-se a adotar parâmetros muito próximos da responsabilidade objetiva para sancionar-se os agentes públicos, em clara violação ao art. 37, § 6º, da CR, que tradicionalmente impõe a responsabilidade subjetiva para fins de regresso nos casos de dolo ou culpa.

Uma vez adotadas as equívocas premissas de responsabilização objetiva dos agentes públicos, simplesmente, toma-se a ação ou omissão do agente, aponta-se o dano e “cria-se” o nexo causal¹⁵, desprezando-se os parâmetros muito mais

14. Preferimos o termo “indenização punitiva” em vez de “danos punitivos”, por guardar melhor precisão semântica ao traduzir-se os *punitive damages* da tradição anglo-saxã. Igualmente, não há que confundir-se a ideia de *punitive damages* com o caráter punitivo ligado à responsabilidade extrapatrimonial. Sobre o tema, fazemos remissão ao texto *Usos e abusos da função punitiva: (punitive damages e o Direito brasileiro)*, em que Judith Martins-Costa e Mariana Souza Pargendler enfatizam: “Também chamados *exemplar damages*, *vindictive damages* ou *smart money*, consistem em soma de dinheiro conferida ao autor de uma ação indenizatória em valor expressivamente superior ao necessário à compensação do dano, tendo em vista a dupla finalidade de punição (*punishment*) e prevenção pela exemplaridade da punição (*deterrence*) opondo-se — nesse aspecto funcional — aos *compensatory damages*, que consistem no montante da indenização compatível ou equivalente ao dano causado, atribuído com o objetivo de ressarcir o prejuízo” (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 16). Também sobre uma perspectiva restritiva, de *lege lata*, da indenização punitiva no Direito Brasileiro, está Maria Celina Bodin de Moraes no seu texto *Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e perspectivas* (MORAES, 2004).

15. Já pudemos aprofundar o tratamento do nexo causal no texto *Nexo causal e excludentes da responsabilidade extracontratual do estado*, em que esclarecemos: “o estudo do nexo causal é de igual relevância tanto na responsabilidade subjetiva como na objetiva. Em sede de responsabilidade estatal, o dano deve ser necessariamente ligado a uma ação ou omissão estatal, e essa tarefa é exercida pelo nexo causal. Este deve ser efetivamente demonstrado e, dependendo das premissas teóricas do nexo, podemos chegar a resultados diametralmente opostos em matéria de responsabilidade extracontratual do Estado. Nesse contexto é possível falar em um nexo causal mais ou menos elástico, dependendo dos pressupostos teóricos que balizam a análise

seletivos da responsabilização subjetiva (dolo ou culpa por imperícia, negligência ou imprudência). Por vezes, o fundamento normativo para responsabilização está assentado em princípios jurídicos, cujo elevado grau de abstração não poderia ensejar aplicação de sanções sem que fossem cotejadas sistematicamente as demais regras do ordenamento, tampouco descurar das peculiaridades do caso concreto.

Nesse cenário, há elevado risco pelo exercício da função administrativa. Com efeito, já sabendo que as probabilidades de sofrer ações de ressarcimento ou improbidade com grandes chances de êxito, o agente público passa a atuar de modo a gerir estratégias preventivas de fuga da responsabilização.

Como vimos no Capítulo antecedente, esse contexto estimulou a primeira tentativa legal de limitação da responsabilização dos agentes públicos estrategicamente inserida na Lei 13.655/18, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB. Diante da responsabilização indiscriminada do agente público, o legislador tentou fixar certos parâmetros para que o controle externo seja exercido. O principal argumento foi a busca da segurança jurídica (e de fato é um dos pontos centrais para a edição da referida norma), mas, em nossa percepção, seu principal intento foi tentar dar um basta na responsabilização indiscriminada dos agentes públicos através da imposição de critérios mais objetivos para o exercício do controle externo, bem como de limitação à sua responsabilização pessoal, como veremos mais adiante.

Mas nem sempre a limitação legal da responsabilidade do gestor será suficiente para protegê-lo. Diante da alta probabilidade de responsabilização, passa ser natural que o gestor adote medidas de *prevenção de riscos* a que está sujeito. No *plano organizativo*, tal intento pode ser realizado pela adoção de *compliance* (aqui adotada em sentido amplo para abranger a ideia de conformidade com normas legais e regimentos internos ou externos) com vistas à prevenção, que pode ser editada sem necessidade de lei específica, eis que a matéria pode ser editada por atos administrativos infralegais. Já no *plano estratégico*, a proteção contra riscos pode utilizar-se de estratégias de gestão de risco ou, ainda, da evasão de responsabilização, como veremos mais adiante.

No *plano organizativo*, a prevenção pode implicar a elaboração de plano de prevenção de riscos, que podem ser estruturados considerando: i) as atribuições e a

de qualquer caso concreto. Justamente pelo fato de ser o caso concreto indispensável à boa inteligibilidade da ocorrência ou não do nexo causal, é que a jurisprudência pátria se mostra tão rica e ao mesmo tempo tão contraditória em matéria de responsabilidade do Estado. Em parte, acreditamos que tais divergências encontram fundamento não apenas no modo de apreciar os fatos, mas na compreensão teórica do tema, nem sempre abordada com a profundidade desejável, principalmente se considerarmos a aplicação das teorias que dão fundamento ao nexo causal, por vezes não tratadas com o rigor técnico necessário” (SANTOS, 2006b).

missão da instituição ii) o contexto em que é desenvolvida a atividade; iii) a forma que está organizada; iv) e estabelecimento de objetivos estratégicos e operacionais (TAVARES; CÂMARA, 2010, p. 37). -

Não é objeto de nossa pesquisa nos determos na estruturação de *mecanismos de integridade* (como modo de densificação prática da ideia de *compliance*). Também há que se distinguir entre programa de integridade e programa de gestão de riscos. O *programa de integridade* é mais amplo que a *gestão de riscos*, envolvendo aspectos da cultura da organização no sentido de *fazer o certo por convicção* (GIOVANINI, 2018, p. 74). Com a adoção de um programa de integridade, a organização ficará seguramente mais protegida no desempenho de suas atividades.

Já o programa de gestão de riscos, como pudemos verificar no Capítulo anterior, visa estabelecer mecanismos para gerir especificamente os riscos da atividade desempenhada, dos quais destacamos a metodologia COSO e ISO 31000.

A responsabilidade do agente público, especialmente o agente político, ao gerir e prevenir possível responsabilização não é fenômeno exclusivamente brasileiro, ainda que sejamos forçados a reconhecer que o caso brasileiro oferece peculiaridades que não existem noutros países, especialmente na alta judicialização das decisões tomadas pelos gestores públicos, seja como ordenadores de despesas públicas, seja mesmo quando julgados administrativamente pelos tribunais de contas, importando em grande probabilidade de condenação.

Importante, ainda, distinguir a diferença na cultura da organização e seus dirigentes da adoção de mecanismos de integridade no sentido de agir conscientemente de modo correto e a mera proteção do gestor, cujo foco passa a ser apenas a autoproteção da organização e seus gestores diante dos riscos a que está sujeita.

Nessa senda, Wagner Giovanini destaca que a mera prevenção da ocorrência de ilícitos e proteção da organização sem que haja um compromisso cultural em fazer o certo por convicção aproxima-se do conceito "*compliance*" como arma de proteção. Já a adoção de efetivos mecanismos de integridade vai muito além do cumprimento de normas de proteção dos agentes, pois revela efetivo compromisso em atuar corretamente (GIOVANINI, 2018, p. 74-75). Tendemos a concordar com o autor, mas referida distinção entre proteção da organização e efetivo programa de integridade tem maior complexidade, e uma coisa não exclui a outra.

Ocorre que todo programa de integridade, ainda que leve em conta os melhores fins e intenções da organização e seus integrantes, não deve ser visto como algo de todos alheio a estratégias de blindagem decisória e mera proteção da organização e seus agentes.

A despeito de o apelo romântico de efetivamente fazer-se o certo por convicção na cultura de uma organização privada ou pública, não podemos dela fazer um *silly duck*. O compromisso da organização é com sua existência e o atingimento de

seus objetivos e, sem dúvida, blindar-se e proteger-se para atingir esses objetivos, ainda que conciliáveis com valores éticos e comprometida em *fazer a diferença*, para usar uma expressão corrente na atualidade.

Neste Capítulo, ocupar-nos-emos das estratégias de evasão de responsabilização, relativamente às quais nosso propósito é fazer uma abordagem meramente descritiva e não propriamente sua defesa, pois muitas dessas estratégias podem ser altamente negativas no sentido de agravar ainda mais a ocorrência de riscos para as organizações pública ou privadas por implicar, assumidamente, apenas a blindagem do agente sem qualquer compromisso com a organização.

Essas estratégias de fuga da responsabilização consistem em fenômeno novo cuja reflexão, especialmente na doutrina estrangeira, se debruça sobre os riscos da atividade política em face de sua eventual responsabilização. Trata-se dos denominados: *blame games*, ou jogos de culpa, cuja finalidade é desviar a responsabilidade do gestor por intermédio de estratégias adrede escolhidas para evitar as consequências políticas e jurídicas da responsabilização.

Com efeito, o "*blame risk*" ou "risco da culpa" (HOOD, 2014), que pensamos melhor denominar de *risco de responsabilização*, trata de risco muito diferente daqueles a que estamos acostumados, v.g., os tradicionais riscos da atividade administrativa para a sociedade ou para a atividade empresarial, corporificados em riscos ambientais, de segurança ou riscos alimentares.¹⁶

O que está em relevo é o risco de o próprio agente público ser responsabilizado por simplesmente decidir no exercício de cargo ou emprego público. Ao contrário do que se poderia imaginar, a despeito de o agente político ocupar o

16. O texto condutor de nossa pesquisa nesse ponto foi o trabalho de Christopher Hood denominado *El juego de la culpa: manipulación, burocracia y autoconservación en el estado* (ou, em inglês: *The blame game: spin, bureaucracy, and self-preservation in government*). Acerca do tema, bem resume o autor: "Toda esa actividad de gestión de riesgos en el gobierno actual y en los negocios se ha solido notar, documentar y comentar. Pero la mayor parte está preocupada oficialmente por los riesgos para la sociedad o para las organizaciones empresariales. Por el contrario, este libro pone de relieve el riesgo de culpa personal que afrontan los cargos públicos, incluidos los políticos, los gestores, los profesionales y los burócratas de primera línea. Ese es un tipo de riesgo y de gestión del riesgo que se identifica con bastante menos frecuencia en el circuito de los seminarios de gestión. Y curiosa o reveladoramente, no tiene ningún término o consabida etiqueta de última generación. Podríamos llamarlo «riesgo de reputación», una de las categorías convencionales del análisis moderno de riesgos, pero ese término se suele utilizar más para marcas corporativas que para cargos públicos individuales. Podríamos llamarlo «riesgo político», pero ese término se usa convencionalmente en la industria de la gestión del riesgo en el sentido de los riesgos a los que las empresas o los inversores se exponen por las decisiones del gobierno que sean adversas a ellos, por ejemplo, la posibilidad de expropiación, de imposición depredadora o de regulación obstructiva. Así que vamos a llamarlo simplemente «riesgo de culpa» para los fines de este libro" (HOOD, 2014, p. 22).

protagonismo — especialmente midiático — em termos de responsabilização, esse tipo de risco não se restringe à classe política, atingindo todos os gestores públicos e mesmo os servidores mais subalternos. Esse tema nem de longe ocupa qualquer prioridade nas escolas de gestão ou governança, mas seus impactos são tão expressivos que nos parece ser impossível atualmente compreender o próprio conceito de gestão pública sem os considerar.

As decisões dos administradores orientadas à sua própria proteção têm efeitos drásticos sobre a Administração Pública, pois o objetivo primeiro do gestor passa a ser de ordem subjetiva-protetiva (de ordem pessoal), e não objetivo-finalística (busca do interesse público). Curiosamente, tal forma de proceder nem sempre é verbalizada ou expressada publicamente. Tal forma de administrar oblitera completamente o que se entende por boa administração pública¹⁷, pois o verdadeiro móvel do agente público é esquivar-se de eventual responsabilização, mesmo que isso importe em má administração.

5.3. Interações entre risco e medo: as consequências do medo no processo de tomada de decisão

A alta probabilidade de ser responsabilizado pelo exercício de função pública, num sistema de controle disfuncionalizado, leva ao *medo de responsabilização* do agente público. Ao mesmo tempo que o medo é *consequência* dos excessos do controle, também é *causa*, à medida que produz respostas disfuncionais visando a autoproteção dos agentes públicos, a exemplo do imobilismo decisório decorrente do medo em decidir, o que pode levar a uma postura mais firme dos órgãos de controle no exercício de sua atividade.

Assumir riscos pode ser algo positivo. Em verdade, a humanidade convive com riscos desde os primórdios da sua evolução.¹⁸ Nesse sentido, a assunção de

17. Acerca da boa administração pública, fazemos referência a Juarez Freitas, que o define como: “direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência e sustentabilidade, motivação proporcional, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas” (FREITAS, 2014, p. 21).

18. Sob a perspectiva de que os riscos podem ser desejáveis e levam à evolução da espécie humana, encontra-se Frank Furedi: “The culture of fear estranges people from one another. It breeds an atmosphere of suspicion that distracts people from facing up to the challenges confronting society. This book is motivated by the conviction that risk-taking is, most of the time, a creative and constructive enterprise. Today's sad attempt to stigmatize risk-taking has the effect of undermining the spirit of exploration and experimentation. There is indeed a major health threat facing our society. Even more than passive smoking — passive living can damage your health” (FUREDÍ, 2002, p. xvi).

riscos passa a ser algo desejável na medida em que nos impulsiona a novos desafios e novos riscos. Mas o mesmo não se passa com o medo. O medo reflete no *incapacidade de gerir riscos*, quer por limites pessoais, quer por fatores exógenos ao indivíduo; ou mesmo porque o grau de probabilidade de ameaça é tão alto que naturalmente dá lugar ao medo. Os administradores públicos deparam-se com o medo porque não sabem o que fazer para evitar riscos; ou pior: mesmo que tu façam para evitar riscos pessoais no processo decisório, ainda assim estarão sujeitos às mais diversas penalidades e responsabilidades.

Por *Direito Administrativo do Medo*, queremos significar: a interpretação e aplicação das normas de Direito Administrativo e o próprio exercício da função administrativa pautadas pelo medo em decidir dos agentes públicos, em face do alto risco de responsabilização decorrente do controle externo disfuncional, priorizando a autoproteção decisória e a fuga da responsabilização em prejuízo do interesse público.

A situação é especialmente grave porque o medo não apenas inibe uma atuação mais criativa e propositiva dos Administradores, mas mesmo no curial cumprimento das normas jurídicas os administradores sequer podem aplicar o Direito como lhes parece adequado. Primeiro, pensam em como os órgãos de controle agirão em caso de fiscalização, o que leva a se absterem em decidir, decidirem de modo lento, ou decidirem de modo a antever as expectativas dos órgãos de controle postergando ao máximo a decisão com consulta a órgãos consultivos ou aos próprios órgãos de controle.

Em princípio, é de todo salutar que as decisões administrativas levem em conta os precedentes e entendimentos já exarados por órgãos de controle, orientando o administrador a bem decidir. Nesse contexto, é importante o papel do controle externo e o próprio sistema de pesos e contrapesos inerentes às funções estatais. Mas o fenômeno indesejável a que nos referimos trata de outra coisa. Não se trata de um salutar receio em decidir. Trata-se de algo mais grave. Falamos da *percepção dos agentes públicos que, pouco importando o que decidam, mesmo que apresentem substanciais razões de decidir, estarão, de qualquer modo, sujeitos à elevada responsabilização por suas decisões*. Tal percepção pode levar à cultura da não decisão ou a outras disfuncionalidades visando a evasão da responsabilização.

O medo, enquanto expressão dos instintos mais primais, tanto na selva como na Administração Pública, pode implicar comportamento muito conhecido: a paralisia¹⁹. Diante de uma grave ameaça, por vezes o ser humano se comporta de

19. A paralisia pode ser uma das consequências de um medo que, na dicção de Emilio Mira y López, pode ser definido como medo *racionalsensato*: “Este es el miedo que podríamos denominar ‘profilático’; el que generalmente se piensa cuando se habla de él sin calificación específica. Para nosotros se diferencia del anterior en que aquél se siente a posteriori (reacción ante el daño) y éste a priori (reacción ante el peligro, o sea, ante la señal anticipadora del daño).

modo não reativo. Fica em choque. Não sabe como agir. Diante do medo em decidir, o agente público passa a adotar a cultura do imobilismo ou paralisia decisória, buscando formas de fuga da responsabilização.

Mas nem sempre o medo implica imobilismo ou mesmo lentidão nas decisões tomadas pelos gestores públicos. Por vezes, há resposta imediata e célere diante da ameaça, mas são respostas disfuncionalizadas, cujo propósito é livrar o gestor de qualquer risco de responsabilização, independentemente do custo para a Administração, a exemplo da transferência da responsabilidade a outros agentes públicos de modo a esquivar-se de sua própria responsabilização.

Em certo sentido, o risco faz parte do ônus decisório. Decidir implica a assunção de riscos. Todavia, *o risco transmuda-se em medo quando na percepção do agente público poderá ser punido pelo simples fato de decidir, ou, no mínimo, que estará sujeito a processos sancionadores no âmbito administrativo ou jurisdicional por sua decisão*. Como já vimos, as principais causas desse medo na realidade brasileira residem na elevada insegurança jurídica: i) quer em decorrência de normas jurídicas que regem a atividade administrativa excessivamente abertas, fazendo que quaisquer agentes públicos possam incorrer em sua violação; ii) quer diante do fenômeno da hiperinflação legislativa que quase impossibilita o conhecimento de todas as normas pelos agentes públicos; iii) quer mesmo pela pouca deferência dos órgãos de controle externo às decisões administrativas tomadas pelos agentes públicos controlados.

Como vimos em nosso Capítulo 2, a fronteira entre o que é permitido e o que é proibido pela norma jurídica assume caráter patológico em razão de nossa alta

Es, pues, un miedo condicionado por la experiencia y va del brazo de la razón; por eso también puede designarse como un miedo 'lógico'. Su característica es la de ser comprensible para quien no lo siente directamente, pero es, no obstante, capaz de 'figurarse' que lo sentiría si se hallase en las circunstancias en que se originó. Si por ejemplo, nos preguntan qué sentiríamos ante la presencia de un tigre, si estuviésemos solos e inermes, no hay duda que la respuesta sería unánime, porque el miedo en tal situación resulta racional (lógico, comprensible, sensato), ya que todos hemos sido capaces de condicionar la idea de 'tigre' con la de 'daño inminente'. Ese miedo predictor se acusa, generalmente, en forma de tendencia a la huida previa. Su fórmula es 'no te metas'; su ropaje eufónico es: la actitud de la prudencia que, como pronto veremos, constituye la forma más leve o menos intensa del 'ciclo de invasión' de nuestro gigante. Por el hecho de ser pensado antes que sentido, el miedo racional dispone de tiempo para asegurar la puesta en marcha de los dispositivos funcionales que eviten al sujeto la presentación de la anterior modalidad descripta, o sea, el miedo instintivo orgánico. Surge, pues, primero en él lo que se llama la 'intelección miedosa' — en forma de idea del posible daño — y es ella (no la directa percepción del daño) la que, desde las zonas de proyección de la corteza cerebral, difunde e irradia a todo el organismo, en un curso retrógrado y descendente (hacia los niveles mesencefálicos, protuberanciales y medulares) los impulsos creadores del malestar emocional y, a la vez, de las reacciones defensivas previas" (MIRA Y LÓPEZ, 1994, p. 43).

insegurança jurídica²⁰. O resultado disto é que o risco se transmuda em medo, e medo, por natureza, é instintivo e irracional.

Por conseguinte, a miríade de decisões tomadas pelo administrador público visando esquivar-se da responsabilização nem sempre serão racionais. O ônus e decisório passa a ser muito menos uma questão de escolha da melhor decisão a ser adotada no caso concreto, para tornar-se forma de autoproteção do agente, que passa a agir de modo a transferir ou desviar-se dos riscos de responsabilização.

Quando o risco é excessivo e impossibilita sua gestão e enfrentamento, a resposta natural é o medo. Relutamos em tratar do medo como categoria a ser enfrentada sob o ângulo do Direito, bem como suas correlações com a gestão pública. Aparelhos, estamos diante de algo *pouco* jurídico, de difícil conceituação e verificação no processo de tomada de decisão, o que, aliás, não deixa de ser parcialmente verdadeiro.

Por mais que tenhamos receio de enfrentar o medo sob a perspectiva jurídica não há como escapar dessa realidade. Quando nos propúnhamos a perguntar o porquê de o agente público adotar estratégias de fuga da responsabilização, buscando blindar-se do processo de tomada de decisão, não nos vinha outra resposta *medo das consequências decorrentes de um controle externo disfuncional*.²¹

20. A bem da verdade, a insegurança jurídica fruto da inflação legislativa é problema mundial, como esclarece Jacqueline Morand-Deville: "A importância da jurisprudência do Conselho de Estado entre as fontes do Direito não é mais tão forte quanto antigamente. Como se verá mais adiante, a concorrência com outras jurisdições supremas é dura e sobretudo pelo fato de tais fontes terem se tornado cada vez mais normativas. A França, como a maior parte dos países, sofre uma inflação legislativa e regulamentar crescente, fenômeno recorrente que se acelerou nos últimos anos (aumento, em 30 anos, de 35% do número anual de leis e de 25% do número de decretos). A esse crescimento de documentos normativos se adiciona a mediocridade de sua redação, marcada por excessiva extensão, complexidades e obscuridades, suscitando o problema da segurança jurídica e da igualdade de acesso ao Direito. Aos princípios da acessibilidade e da inteligibilidade do Direito já se reconheceu hierarquia constitucional, mas seu respeito é dificilmente assegurado. O papel de censor vigilante desempenhado pelo Conselho de Estado na elaboração de um Direito famoso por sua qualidade de redação se enfraquece. Os projetos de lei ou de decreto que suas comissões consultivas tornam claros e coerentes perdem logo em seguida toda sua legibilidade por conta de emendas parlamentares cada vez mais numerosas e desordenadas" (MORAND-DEVILLER, 2012).

21. Esse aspecto foi bem percebido por Fernando Vernalha Guimarães, que verificou no controle excessivo a causa do medo em decidir: "O administrador público vem, aos poucos, desistindo de decidir. Ele não quer mais correr riscos. Desde a edição da Constituição de 88, que inspirou um modelo de controle fortemente inibidor da liberdade e da autonomia do gestor público, assistimos a uma crescente ampliação e sofisticação do controle sobre as suas ações. Decidir sobre o dia a dia da Administração passou a atrair riscos jurídicos de toda a ordem, que podem chegar ao ponto da criminalização da conduta. Sob as garras de todo esse controle, o administrador desistiu de decidir. Viu seus riscos ampliados e, por um instinto de autoproteção,

O controle externo disfuncional — justamente por exacerbar qualquer previsão racional — só pode fomentar o medo. Nessa acepção, o medo é produto do risco não controlado ou incontrolável. Suas consequências na gestão pública são expressivas. Além de ser velho conhecido do Direito, o medo, atualmente, revela novas facetas que requerem análise jurídica do fenômeno.

Entre as tradicionais aproximações entre Direito e medo, está o Direito Penal²². O medo do crime e do processo de vitimização a que todos estamos sujeitos tem levado à produção legiferante visando atender ao clamor social por segurança e o consequente recrudescimento da legislação penal como tábua de salvação para os conflitos da sociedade contemporânea, evidenciando conexões entre Direito e medo.

O medo como condutor de políticas criminais tende a valorizar a segregação do criminoso em detrimento da sua ressocialização e convívio social após o cumprimento da pena. De igual modo, as garantias do cidadão tributárias ao estado liberal são postas de lado, afinal, entre assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e, doutra banda, a eliminação e encarceramento do criminoso, com rápida punição do infrator, fica-se com a última opção.

Portanto, conexões entre Direito e medo não são nenhuma novidade. Thomas Hobbes sempre viu no medo fator de cumprimento da lei, inclusive defendendo a compatibilidade entre medo e liberdade.²³

demarcou suas ações à sua 'zona de conforto'. Com isso, instalou-se o que se poderia denominar de *crise da ineficiência pelo controle*: acuados, os gestores não mais atuam apenas na busca da melhor solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger. Tomar decisões heterodoxas ou praticar ações controvertidas nas instâncias de controle é se expor a riscos indigestos. É compreensível a inibição do administrador frente a esse cenário de ampliação dos riscos jurídicos sobre suas ações. Afinal, tomar decisões sensíveis pode significar ao administrador o risco de ser processado criminalmente. Como consequência inevitável da retração do administrador instala-se a ineficiência administrativa, com prejuízos evidentes ao funcionamento da atividade pública" (GUIMARÃES, 2016).

22. Ao tratar do discurso do medo em nossa cultura, destaca Sérgio Francisco Carlos Graziano Sobrinho: "Sob o primeiro ponto de vista, a violência e a cultura do medo exercem papel fundamental em nossa sociedade. Fundada a partir da lógica da dominação, a sociedade interpreta determinados fatos conforme a ideologia vigente naquele momento histórico, ou seja, a lógica hegemônica do grupo dominante deve prevalecer, difundindo a ideia principal através de pequenas justificações, as quais permitirão, ante a presença do fato indesejado, mas real, que parcelas da sua liberdade sejam reprimidas a fim de manter (ou restaurar) a ordem, ainda que em troca de arbitrariedade ou opressão. Diante disso, é notável o tratamento político a ser evidenciado nesta correlação de forças, visto que o medo é traduzido como mecanismo de dominação política e social, tolhendo a liberdade do indivíduo e reduzindo direitos dos cidadãos" (GRAZIANO SOBRINHO, 2010, p. 147).

23. Acerca das relações entre medo e liberdade, assim tratou Hobbes: "Fear and liberty are consistent, as when a man throweth his goods into the sea for fear the ship should sink, he doth it nevertheless very willingly, and may refuse to do it if he will; it is therefore the action of one

Categorias por vezes classificadas como pouco (ou nada) jurídicas podem tornar-se jurídicas, a depender de como o fenômeno do Direito pode observá-las e problematizá-las. O Exemplo clássico é a categoria *política pública*. O tema do controle das políticas públicas comporta viés inegavelmente jurídico, embora não o fosse há poucas décadas. Se há trinta anos alguém escrevesse sobre política pública, o provável é que estaria a fazer um trabalho de ciência política ou gestão pública, jamais um trabalho jurídico.

Mas os desdobramentos do tema *política pública* e seu enfrentamento pelo Direito juridicizaram o assunto. Hoje, falar em controle das políticas públicas pelo Direito e os parâmetros que norteiam seu controle jurisdicional é de inegável atualidade e juridicidade.

O mesmo se passa nas inter-relações entre Direito e medo. É perfeitamente possível abordarmos o *medo* como fenômeno jurídico, especialmente: i) na produção da norma jurídica visando proibir ou fomentar certos comportamento, a exemplo do que ocorre no Direito Penal ou na responsabilização por improbidade administrativa; ii) na adoção de estratégias de fuga da responsabilização pelo agente público visando evitar sua responsabilização; iii) na organização e implementação de processos decisórios de modo a distribuir ou alocar riscos de modo a reduzir o medo em decidir.

Como bem revela Zygmunt Bauman: "*Medo* é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito — do que pode e do que não pode — para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance" (BAUMAN, 2008, p. 8). O sociólogo polonês, ao enfrentar a questão do medo em sua obra *Medo líquido*, assevera que o medo, além de ser compartilhado com os animais, encontra na espécie humana um medo de segundo grau, que orienta suas escolhas e comportamentos. Mesmo que não haja uma ameaça diretamente presente, o medo secundário (rastro de uma experiência passada) modela a conduta humana mesmo que não haja ameaça visível (BAUMAN, 2008, p. 9).

Se, dantes, assumir riscos era algo desejável, ousado e desafiante, hoje está cada vez mais associado a algo perigoso, sujeito à desaprovação social, de maneira que todo ser humano, quer desenvolvendo atividades privadas, quer esteja no exercício de função pública, vem adotando estratégias de evasão de responsabilização para se evitar expressivas condenações, como bem destaca Frank Furedi:

So today, when we speak of risk, what we have in mind is the danger of an adverse outcome. We describe less and less the decision we are likely to take as a

that was free; so a man sometimes pays his debt only for fear of imprisonment, which (because nobody hindered him from detaining) was the action of a man at liberty. And generally all actions which men do in commonwealths for fear of the law are actions which the doers had liberty to omit (HOBBS, 1994, p. 136-137).

'good risk'. Not surprisingly, as risks become more and more equated with danger, there is a tendency to adopt strategies that are selfconsciously about risk avoidance. Indeed the positive connotations traditionally associated with 'risk-taking' have given way to condemnation. Consequently, in many situations, 'to take risks' is to court social disapproval (FUREDÍ, 2002, p. 18).

Para ter medo dos órgãos de controle externo, sequer é necessário comportamento ousado e inovador. Mesmo que o agente público se proponha a atuar de modo sóbrio e acanhado estará sujeito a riscos elevados. Ainda que se proponha a cumprir estritamente a norma jurídica em sua atuação administrativa, correrá o risco de ser responsabilizado por sua má aplicação e estará sujeito a prejuízos imaginários (a exemplo da responsabilidade *in re ipsa*) que lhe serão imputados. Portanto, têm boas razões para o medo não apenas os ousados, mas também os tímidos.

As interações entre risco e medo atingem todos os agentes públicos, especialmente os agentes políticos. Se, de um lado, há crescente descrédito na política e nos políticos e uma tendência de encarmos a atuação política como algo suspeito, além da perspectiva cínica no sentido que as ações dos políticos não podem redundar em melhorias e resultados positivos²⁴, de outro, os políticos têm receio do exercício disfuncional do controle externo, pois além de estarem envolvidos nesse cenário de descrença, podem receber as mais diversas sanções, fazendo dessa ameaça algo bastante real e factível.

Esse temor fica ainda mais evidente a partir da pluralidade de instâncias e órgãos de controle que geram inúmeras redundâncias, em que um mesmo fato é investigado pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pela Controladoria-Geral da União, pelas agências reguladoras etc., gerando graves ineficiências e custos, pois a multiplicidade de órgão para investigar um mesmo fato evita que esses órgãos possam direcionar seu controle a outros fatos que demandariam investigação.²⁵

24. A visão cínica e desacreditada da classe política pode levar a uma perspectiva fatalista, de modo que pouco importa o que façam os políticos, tudo dará errado, reforçando a ideia de que os limites da humanidade nos obrigam a aceitar qualquer que seja nosso destino, como bem esclarece Frank Furedi: "Unfortunately, the growth of cynicism towards society's institutions benefits no one. Cynicism about politicians or any section of the elites does not on its own lead to any positive outcomes. In the absence of an alternative, such cynicism can lead to the conclusion that any form of human intervention is suspect. Cynical criticism does not strengthen critical thought. Rather, it can reinforce the view that there are no choices and that the limits of human effectiveness oblige us to accept our fate" (FUREDÍ, 2002, p. 169).

25. A respeito dessa multiplicidade de instâncias controladoras, calham as observações de Priscilla de Souza Pestana Campana: "Não há, portanto, como se mostrar efetiva uma estratégia de controle fundada na presença de múltiplos atores, agindo de forma independente e controlando, retrospectivamente — e sem qualquer divisão de tarefas —, os mesmos fatos, principalmente quando de elevada relevância. Ou seja, nosso sistema de controle é formado por uma rede de

Por todas essas razões, o medo tem reflexos na atividade administrativa, fazendo com que os juristas passem a enfrentar a temática.²⁶ As correlações entre risco e medo no processo decisório impõem a necessidade de tratarmos do tema perscrutando não apenas suas causas, como já visto anteriormente, mas identificando seus efeitos. Nessa linha, necessário compreender como se portam os agentes públicos nos mundos da fuga da responsabilização. É o que veremos a seguir.

5.4. Os agentes públicos nos mundos da fuga da responsabilização

Neste tópico, trataremos das formas de evasão de responsabilização utilizadas para evitar a reponsabilidade civil, administrativa, política ou penal dos agentes

diversos órgãos públicos especializados e descentralizados que atuam com pouca harmonia, ampliando os custos do exercício da fiscalização pelos controladores, assim como os custos dos próprios controlados. Sem dúvida, essa falta de coordenação compromete a efetividade da atuação estatal à medida que gera redundância e incoerência entre ações, dando oportunidade a graves lacunas no controle, já que, considerando a escassez de recursos e a limitação do tempo, enquanto se desperdiça esforços na fiscalização de determinado fato também investigado por outras instâncias, outros tantos deixam de ser investigados" (CAMPANA, 2017, p. 196).

26. Acerca das relações entre medo e *Direito Administrativo*, importantes as considerações de Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, donde indica os perigos do controle ameaçador na intimidação do agente público no processo de tomada de decisão, bem como a redistribuição do Poder no âmbito estatal, delegando aos órgãos de controle a prerrogativa de decidir: "E quais as consequências do medo de praticar tais atos? São duas consequências extremamente graves. A primeira é a perda manifesta de condições mínimas para a tomada serena de uma decisão, com evidente distorção dos seus motivos. Ora, à medida que órgãos de controle passam a adotar a estratégia da ameaça como metodologia corriqueira para alcance dos resultados por eles fixados, o agente passa a tomar a decisão — deixa de emitir a licença, deixa de fazer a contratação emergencial, manda retirar o cartaz que dizia "Fora Temer" —, não porque ela seja justa, necessária, legal, recomendada pela melhor técnica, mas sim por medo de ser punido. Com efeito, é difícil negar que alguém que, antes de decidir determinado processo, recebe aviso explícito de que, se decidir em sentido contrário àquele escolhido pelo órgão que o ameaça, será processado em duas esferas, não tem mais serenidade para tomar a decisão, não pode mais avaliar se aquela decisão era de fato necessária, e passará a avaliar, em especial, as consequências pessoais que aquela decisão pode lhe acarretar. Se a recomendação for por não praticar a medida — o que sempre pode ser (mal) justificado por uma interpretação extrema do princípio da legalidade — ainda mais fácil, afinal, como costumava lembrar o saudoso Marcos Juruena (crítico das interpretações que sempre conduziam ao imobilismo), 'Dorme tranquilo quem indefere'. A segunda consequência, esta de inegável dimensão constitucional, é a de uma silenciosa redistribuição de Poder dentro do aparelho de estado. Com efeito, sem qualquer alteração da Constituição, nem de qualquer lei, decisões que a Constituição atribuiu ao Poder Executivo — órgão jurídica e politicamente responsável — passam, de fato, a ser tomadas por órgãos de controle, órgãos que, além de serem irresponsáveis politicamente (salvo num grau muito remoto de responsabilidade política difusa), raramente são juridicamente responsabilizados por seus excessos" (MASCARENHAS, 2016).

públicos no exercício de suas funções. O marco teórico de nossas reflexões sobre o tema foi Christopher Hood, que identifica e classifica os agentes públicos em diversos mundos de responsabilização.

No *primeiro mundo*, estariam os “gerais”, que são os que estão na primeira posição de liderança, muitos deles agentes políticos ou mesmo os detentores de funções públicas diretamente ligadas aos agentes políticos, cuja responsabilidade vem à tona diante de uma crise que demanda culpados (HOOD, 2014, 46).

Já no *segundo mundo* da fuga ou evasão da responsabilização está a “infantaria”, os servidores da “linha de frente”, aqueles que tratam diretamente com o público e sofrem as pressões dos cidadãos em seu cotidiano (HOOD, 2014, p. 46).

Hood nos fala, ainda, de um *terceiro mundo* da fuga da responsabilização, que compreende aqueles que estão entre os *gerais* e a *infantaria*, a exemplo dos reguladores de serviços públicos, os administradores e gestores de recursos públicos (HOOD, 2014, p. 46).

Finalmente, no quarto mundo da fuga da responsabilização resta um grupo muito heterogêneo, que compreende todos que têm relação com o Poder Público, a exemplo dos concessionários de serviços públicos, clientes, usuários, pacientes etc. Veja-se que esses personagens da sociedade civil estão em posição de cobrar responsabilidades, mas os titulares de cargos públicos podem imputar responsabilidade a integrantes da sociedade civil, quando então lhes é “passada a bola” no mundo da fuga da responsabilização (HOOD, 2014, p. 46).

Independentemente do acerto ou desacerto da classificação anteriormente trazida sobre os agentes públicos nos mundos da responsabilização, sem dúvida, podemos encontrar um grau hierárquico de agentes públicos alto, médio ou baixo que estão sujeitos à responsabilização e nela estarem envolvidos. Também interessante na classificação proposta que mesmo a sociedade civil pode estar envolvida no jogo da fuga da responsabilização quando a ela é atribuída a responsabilidade pelo mal funcionamento dos serviços públicos, a exemplo dos casos de depredação de bens públicos.

Traduzindo essa proposta para a realidade de nossa organização administrativa brasileira, podemos identificar como “gerais” no mundo da fuga da responsabilização o Presidente da República, Governadores e Prefeitos. Típicos exercentes de cargos políticos, são altamente visados pela mídia e pela opinião pública. Seu interesse em desviar a responsabilidade tem tanto um viés exclusivamente político, no sentido de evitar decisões ou atitudes que lhes causem desgastes que os impossibilitem ou dificultem sua reeleição, como uma preocupação na blindagem contra ações cíveis que busquem ressarcimento por alegado dano ao erário, ou ações de improbidade administrativa, evitar a cominação e inelegibilidades ou mesmo deflagração de processos-crime, especialmente porque, em nosso sistema jurídico, um mesmo fato pode ensejar processos judiciais e administrativos

autônomos e com consequências distintas. Também os Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais podem ser alocados nessa categoria.

O segundo mundo da fuga da responsabilização no Brasil é composto dos exercentes de cargo ou emprego responsáveis por fazer a “máquina funcionar”, atuando na *linha de frente* ou na *infantaria* da Administração Pública. Abrange servidores ou empregados que atendem diretamente ao público, como médicos; professores; policiais etc., enfim, a grande massa de servidores que atua na prestação dos serviços públicos à sociedade. Igualmente, pode abarcar esses servidores quando no exercício de funções de confiança ou cargos em comissão (art. 37, V, CR), nas funções de chefia, direção ou assessoramento. Nos “jogos da culpa”, em regra, tentam desviar a responsabilização para os que estão acima deles, ou mesmo alegar problemas estruturais que impossibilitem o adequado exercício de suas funções pelas más condições de trabalho, podendo, ainda, responsabilizar os usuários dos serviços como os verdadeiros causadores dos problemas ou danos a eles imputados.

No terceiro mundo da fuga da responsabilização em nossa estrutura organizacional estão aqueles agentes públicos que de algum modo se encontram entre o *generalato* e a *infantaria*, abrangendo, por exemplo, as chefias de gabinete do poder executivo; dirigentes de agências reguladoras; administradores de recursos públicos etc. Em verdade, essa categoria é ampla para abranger aqueles não previstos no primeiro e no segundo mundo.

Por fim, o quarto mundo da evasão da responsabilização em nosso sistema pode compreender os cidadãos, usuários de serviço público, estudantes, pacientes etc., que, à primeira vista, seriam os que culpabilizam, e não os culpabilizáveis. Contudo, no jogo da evasão da responsabilização, podem ser elencados como os responsáveis pelos danos ou mau funcionamento do aparato administrativo. Isso ocorre normalmente por atribuir-se ao comportamento da vítima a verdadeira causa dos males por ela sofridos; ou nas hipóteses de sabotagem ou depredação de patrimônio público (HOOD, 2014, p. 62-65). Passemos a analisar os riscos de responsabilização e respectivas estratégias dos gestores para evitá-las:

5.5. Estratégias de fuga da responsabilização: considerações preliminares

O tema da *fuga da responsabilização* está inserido no contexto das medidas de prevenção de danos. Mas, em vez de falar-se em prevenção de danos externos ao agente público ou de formas de a Administração Pública atuar preventivamente quanto a ameaças e riscos que deve gerir no Estado pós-liberal, o enfoque da prevenção é proteger o próprio agente público e seus bens jurídicos.

O princípio da prevenção decorreu do surgimento do Estado Democrático e Social de Direito, pois os riscos e perigos que o Estado deveria intervir estão a aumentar *quantitativa e qualitativamente*.

Quantitativamente, perigos cingiam-se à manutenção da ordem e segurança do Estado-polícia. Qualitativamente, porque houve aumento da atuação estatal deixando de atuar de modo absenteísta e com autocontenção no tocante aos deveres do Estado contemporâneo (GOMES, 2007, p. 246).

Não trabalharemos as estratégias de fuga sob o ângulo do princípio da precaução²⁷ (com inspiração na legislação alemã: *vorsorgegrundsatz*), pois, a despeito da polissemia e da alta fluidez do princípio da precaução²⁸, pode ser compreendido como uma margem de segurança adicional à prevenção diante da mera possibilidade (e não probabilidade) do risco (GOMES, 2007, p. 253).

Mas, se tomarmos o medo como aspecto imobilizante na tomada de decisão, curiosamente o princípio da precaução parece adquirir certa “densidade”, pelos altos riscos a que está sujeito o agente público no Brasil, afinal, por vezes, as estratégias de prevenção não são apenas racionais, mas beiram a total irracionalidade, pois o medo em decidir pode adquirir tal magnitude que afeta a qualidade das políticas de desenvolvimento nacional, o atingimento do interesse público e mesmo gera paralisia administrativa.

Nesse passo, por vezes, o agente público age não apenas preventivamente, mas precaucionariamente, por não querer correr riscos; sua intenção é a autoblindagem total e absoluta, e, em nome do risco-zero, quer eliminar qualquer possibilidade (e não apenas probabilidade) de responsabilização. As restrições à liberdade e à autonomia do agente público (obviamente balizadas pela Constituição), levam a novos perigos.

27. O princípio da precaução ganhou maior notoriedade com a Declaração do Rio de 1992: Princípio 15: Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 18 de maio de 2018. Relevante, ainda, a adoção pelo atual art. 174, 2, do Tratado de Roma do princípio da precaução, a saber: Artigo 174 (...) 2. A política da Comunidade no domínio do ambiente terá por objectivo atingir um nível de protecção elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da Comunidade. Basear-se-á nos princípios da precaução e da acção preventiva, da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador. Disponível em: <https://respublicaeuropeia.wordpress.com/2002/12/24/tratado-de-roma-versao-consolidada/>. Acesso em 18 de maio de 2018.

28. Nesse sentido, segue a crítica de Carla Amado Gomes: “A precaução afigura-se, assim, como uma noção perversa, potencialmente atentatória, quer da liberdade individual, quer da paz jurídica essencial à convivência no seio de uma comunidade democrática. Isto porque, apelando à corda sensível do público e alimentada pela imprensa, sempre em busca de notícias sensacionalistas — o risco “vende” bem —, a ideia subjacente à fórmula embrionária da precaução seduz a opinião pública enquanto a sequestra na armadilha da segurança” (GOMES, 2007, p. 366-367).

As estratégias de fuga da responsabilização são utilizadas consciente ou inconscientemente pelos gestores públicos. Todavia, com o aumento da insegurança jurídica, da irracionalidade do controle externo disfuncional e a efetiva percepção de que os agentes públicos estão sujeitos a riscos políticos, jurídicos e patrimoniais de monta, fazem tais estratégias serem adotadas de modo mais planejado e consciente. Se considerarmos, ainda, o impacto de tais estratégias na Administração Pública, em que a autoproteção passa a ter primazia sobre a boa administração, estamos diante de um fenômeno intrigante, novo e pouco estudado²⁹.

Estratégias de fuga da responsabilização podem ser previstas de modo transparente e institucional, nesse ponto aproximando-se da ideia de gestão de riscos, a exemplo da estratégia de delegação, em que a norma jurídica prevê a delegação ou mesmo a responsabilidade solidária dos envolvidos no processo decisório, o que equivale ao compartilhamento do risco enquanto espécie de tratamento do risco.

Todavia, muitas estratégias de fuga da responsabilização são disfuncionais. Afinal, a resposta ao controle externo disfuncional pode também ser igualmente disfuncional, a exemplo da estratégia da abstinência decisória, em que, a despeito do dever de tomada de decisão, adota-se a inação como mecanismo, visando adiar a decisão ou mesmo nada decidir.

Trataremos das estratégias de fuga da responsabilização no âmbito da Administração Pública, visto que a ideia de evadir de riscos é algo ínsito ao ser humano. Pesquisas demonstram que o ser humano prefere deixar de ganhar que correr o risco de perder (HOOD, 2014, p. 27).

Esse comportamento é conhecido por *aversão ao risco* ou *viés de negatividade*,³⁰ em que se dá mais atenção às informações negativas que às positivas. No âmbito

29. Num certo sentido, o ser humano sempre buscou evitar riscos e precaver-se. Isso é natural e nada tem de novo. Mas a sociedade contemporânea tem elevado esses riscos e os institucionalizado, o que faz com que o fenômeno da evasão da responsabilização adquira novos contornos, como bem traz Frank Furedi: “Taking precautions is not in itself a novel phenomenon. People have always used their common sense to protect themselves from potential hazards. There have always been some individuals who are particularly cautious and devote their energies to shielding themselves and their families from dangers. However, such attempts to gain security should not be confused with developments in contemporary society. Today, caution has become institutionalized to cover every aspect of life. This institutionalization is often interpreted technically — as a responsible way of minimizing risk” (FUREDI, 2002, p. 108).

30. Como assevera Cass Sunstein: “People tend to be loss averse, which means that a loss from the status quo is seen as more undesirable than a gain is seen as desirable. When we anticipate a loss of what we now have, we can become genuinely afraid, in a way that greatly exceeds our feelings of pleasurable anticipation when we look forward to some supplement to what we now have. So far, perhaps, so good. The problem comes when individual and social decisions downplay potential gains from the status quo, and fixate on potential losses, in such a way as to produce overall increases in risks and overall decreases in well-being” (SUNSTEIN, 2003, p. 41).

da política, os fracassos acabam sendo mais lembrados que os êxitos, fazendo com que os agentes políticos sejam mais prejudicados pelos eleitores pelos erros que pelos acertos. Igualmente, essa percepção é muito clara na mídia, que tende a acentuar os fracassos em detrimento dos sucessos (HOOD, 2014, p. 27-29).

Nesse ponto reside um dos mais perversos efeitos das técnicas de fuga ou evasão da responsabilização de que trataremos. Na dúvida entre buscar o melhor ao interesse público em cotejo com os riscos negativos da atividade decisória, o agente público acaba por escolher o caminho da mediocridade. Os agentes públicos que atuam no cotidiano das burocracias contemporâneas sofrem por nossa tradição de controle examinar não o que funciona (visando extrair exemplos de boas práticas administrativas), mas em valorizar o que não está a funcionar, sob o argumento — aparentemente correto — de que o que funciona é mero dever, e o que não funciona é que deve ser fiscalizado e corrigido.

A despeito da necessidade de verificar-se os equívocos e erros administrativos, esse sistema de controle leva a graves equívocos e efeitos perniciosos. O primeiro deles é que toda atuação administrativa passa a centrar-se em evitar erros — que, aliás, parece desejável — mas, ao se fazer assim, as boas práticas administrativas, as ideias inovadoras, o constante repensar da Administração Pública, ficam em segundo plano.

Já o segundo problema decorre da impossibilidade um agente público não cometer erros. Evidente que, se sua conduta decorrer de atuação culposa ou dolosa, ele estará sujeito ao respectivo ressarcimento, mas esse erro não poderá ser um erro qualquer, deve estar revestido de dolo ou culpa grave, posto que, se toda atuação culposa dos agentes públicos resultar em responsabilidade civil ou perda do cargo, não restará qualquer incentivo para o desenvolvimento de sua atividade.

Diante da iminência de qualquer agente público sofrer responsabilidade por seus atos, e do medo que perpassa a realidade administrativa brasileira, é que se colocam as *estratégias de fuga da responsabilização* (HOOD, 2014), a exemplo da estratégia de *paralisia decisória*, onde a *arte de não decidir* passa a ser modo de sobrevivência do gestor na Administração Pública (CONESA, 2014).

5.6. Tipos de estratégias de fuga da responsabilização

Antes de adentrarmos nas especificidades das estratégias de fuga da responsabilização, necessário fazer algumas considerações acerca do que nos levou a eleger as estratégias tratadas neste trabalho. Primeiramente, os tipos de estratégias de fuga da responsabilização elencadas adiante não são exaustivas. É possível incluirmos outras estratégias aqui não tratadas. Isso decorre do fato de que a pluralidade de atuações e peculiaridades do exercício de cada função administrativa pode ensejar a utilização de novos tipos de estratégias visando a fuga da responsabilização.

Portanto, não pretendemos apresentar um rol taxativo de estratégias de fuga da responsabilização, mas tão somente elencar as que nos parecem mais relevantes.

Importante esclarecer que as estratégias de fuga da responsabilização aqui descritas decorreram de nossa pesquisa bibliográfica, especialmente — ainda que não exclusivamente — do trabalho de Christopher Hood (HOOD, 2014), que verificou a utilização dessas estratégias de fuga da responsabilização (*blame avoidance*) no Reino Unido, que são adaptáveis ou utilizáveis integralmente na realidade brasileira. A segunda fonte das estratégias aqui mencionadas decorre de nossa observação empírica dos modos de evitar-se a responsabilização pelos agentes públicos no Brasil; observações decorrentes de nossa atuação no Direito Público na defesa de agentes públicos, bem como da verificação de como se comportam os órgãos de controle no exercício da sua atividade controladora. Portanto, importante que se diga que nossas observações não passaram por testes empíricos para saber se as estratégias por nós elencadas são utilizadas de forma generalizada, se funcionam, ou mesmo qual seu efetivo grau de proteção decisória.

E diga-se que a testagem dessas estratégias não é tarefa simples. Primeiro, porque muitas dessas estratégias envolvem revelar o móvel dos agentes públicos, o que implica revelar intenções publicamente inconfessáveis. E, quando dizemos inconfessáveis, não é porque sejam ilegais (embora possam sê-lo), mas porque é muito difícil ou inconveniente assumir publicamente que o gestor utilizou-se, por exemplo, da *estratégia de judicialização ou substituição decisória externa*, que consiste em deixar de decidir ou decidir contrariamente aos interesses do cidadão (mesmo que tenha direito), esperando que possa o Judiciário decidir em lugar do administrador, como forma de blindar-se de decisões que, na percepção do gestor, tragam algum grau de risco.

É igualmente difícil ao agente público admitir que, quando procura os órgãos de controle para trocar ideias sobre decisões a serem tomadas, ou de como deve conduzir certos projetos governamentais (*estratégia de relacionamento informal interadministrativo*), em verdade pode fazê-lo mais pela busca da autoproteção, com o fito de partilhar da sua responsabilidade decisória, que pela busca de soluções consensuais oriundas dos órgãos de controle.

Tampouco é provável que algum agente público assuma, publicamente, que transferiu todo seu patrimônio buscando valer-se da *estratégia de blindagem patrimonial*, antes mesmo de tomar posse num cargo público, visando preservar seu patrimônio pessoal diante do elevado risco de ter declarado indisponíveis seus bens, pelo simples fato de ordenar despesa pública.

Tendo em conta essas considerações introdutórias, os principais tipos de estratégias utilizadas para evasão ou fuga da responsabilização tendo em conta nossa pesquisa bibliográfica e nossas observações empíricas são: i) *estratégias de manipulação da opinião pública*; ii) *estratégias de atuação visando transferir a outros*

agentes a responsabilidade ou grau de exposição ao risco; iii) *estratégias de políticas públicas ou operacionais*; iv) *estratégias de judicialização ou substituição decisória externa*; v) *estratégia de relacionamento informal interadministrativo*; e, finalmente, vi) a *estratégia de blindagem ou proteção patrimonial*, em que, antes mesmo de assumir função pública, o gestor já realiza a proteção de seus ativos financeiros quer lícita, quer ilícitamente.

5.6.1. Estratégias de manipulação

As estratégias de manipulação estão ligadas a técnicas de propaganda e divulgação da ação estatal, de modo a acentuar seus aspectos positivos; ou, diante dos problemas enfrentados pela Administração e cobranças que lhes são legitimamente feitas, passar a impressões positivas para minimizar os efeitos negativos de determinando tema para o gestor. Por sua natureza, não podem ser utilizadas por qualquer agente público, mas especialmente pelos agentes políticos, eis que sua posição hierárquica, institucional e sua relação com o eleitorado permite sua utilização, ainda que seja pouco efetiva para fins de minorar sua responsabilização perante órgãos de controle.

Pode, também, implicar a criação de “distrações”, de modo a entreter a mídia e os cidadãos, a exemplo da iniciativa de projeto de lei polêmico com a finalidade de promover agentes públicos ou mesmo no anúncio de medidas administrativas controversas cuja principal e velada finalidade é desviar dos assuntos mais prementes para os menos importantes (HOOD, 2014). É a chamada *administração do espetáculo*, na feliz dicção de Marçal Justen Filho.³¹

Como bem destaca Marçal Justen Filho, o direito administrativo do espetáculo tem por pressupostos epistemológicos: 1) a posição do administrado como objeto e não sujeito, devendo conformar-se com sua posição inferior; 2) a preferência dos princípios em detrimento das regras, evitando controles mais precisos; 3) a consagração de princípios sem conteúdo material, que permitem preenchimento

31. Assim bem explica o autor: “A atividade administrativa de espetáculo consiste essencialmente na demonstração pública de grande azáfama governativa. Os administradores públicos produzem permanente informação à Plateia relativamente às ações imaginárias que desenvolvem. Essa atividade administrativa espetacular se produz por meio da utilização de conceitos aptos a manter o expectador na condição de um elemento passivo, ocupado em acompanhar a proliferação de notícias jurídicas. Trata-se de prender a atenção dos indivíduos comuns, neutralizando o seu senso crítico e impedir qualquer comparação entre a ação administrativa e o mundo real não imaginário. O Direito Administrativo do espetáculo é um instrumento essencial para o Estado do Espetáculo, eis que as ações imaginárias do governante envolvem a utilização de conceitos e expressões técnico-científicas, que são recepcionados pela Plateia com um misto de desconhecimento e espanto” (JUSTEN FILHO, 2009).

subjetivo pelo governante; 4) rígida organização administrativa permitindo que a vontade do governante prepondere sobre a da Administração (JUSTEN FILHO, 2009).

A estratégia de manipulação consiste em apresentar uma versão dos fatos com o fito de manipular a impressão que a opinião pública ou publicada dele tem. Christopher Hood destaca quatro modos diferentes: i) *fazer prevalecer seu ponto de vista*; ii) *arrepender-se publicamente*; iii) *enterrar más notícias*; iv) *manter perfil discreto* (HOOD, 2014, p. 74-93).

Ao adotar a técnica de fazer i) *prevalecer seu ponto de vista*, ou *ganhar a discussão*, o agente público tenta fazer valer sua versão dos fatos, demonstrando que o alegado problema a ele atribuído não ocorreu, ou, mesmo admitindo sua existência, minimizando seus efeitos negativos. Também pode implicar culpar fatores que, aparentemente, independem da vontade do agente público, a exemplo da falha de sistemas de informática; falta de pessoal ao longo de muitos anos; problemas crônicos herdados de outros governos; desconhecimento dos fatos etc. (HOOD, 2014, p. 74-78).

Já a técnica de ii) *arrepender-se publicamente* ou *confessar seus erros* tem por fito desarmar os críticos e angariar simpatias. Por vezes, é utilizada antes mesmo que as críticas sejam levadas mais adiante, blindando o agente público. Em geral, é empregada pelos agentes políticos de maior estatura, seja porque dificilmente alguém estará interessado em ouvir desculpas de servidores públicos de menor hierarquia, seja por não exercerem cargos políticos que necessitem do apoio de eleitores. Claro que tal estratégia tem seus riscos, pois poderá expor ainda mais o agente público, ou mesmo passar a impressão de que as desculpas são pouco sinceras (HOOD, 2014, p. 79-82).

A técnica de iii) *enterrar más notícias* é utilizada para não divulgar situações delicadas para os governos e que podem ensejar explicações da imprensa e da sociedade civil. Assim, aumento da violência, incremento de subsídio de parlamentares, avanço da poluição ambiental, em regra, não são notícias ou informações que se priorize divulgar. Quando a divulgação é inevitável, em regra, aproveita-se um momento em que a cobertura midiática sobre calamidades ou graves eventos esteja em curso, de modo a distrair a opinião pública (HOOD, 2014, p. 82-84).

Finalmente, no uso da estratégia de manipulação, o agente pode valer-se da tática de iv) *manter perfil discreto*. Como diz o dito popular: *falar é prata, mas calar é ouro*. Ter uma atitude *low profile* e esperar que as coisas se resolvam por si mesmas pode ser uma técnica de evadir-se da responsabilização. Como acentua Christopher Hood, ao trazer as palavras do Presidente estadunidense Calvin Coolidge (1923-1928): “Nunca vaya al encuentro de los problemas. Si solo se sienta tranquilamente, en nueve de cada diez casos alguien lo interceptará antes de que le alcance” (HOOD, 2014, p. 84-89). Por certo que há risco nessa estratégia (passar-se

por omissão), mas ela também admite variantes, pois, em vez de calar-se por completo, silencia-se parcialmente, esclarecendo fatos quando for inevitável fazê-lo. Nessa linha, por vezes se emite nota pública oficial e por escrito para evitar-se questionamentos diretos, ou mesmo aceitando dar entrevistas apenas sobre perguntas previamente formuladas ou não atendendo certos meios de comunicação (HOOD, 2014, p. 86), a exemplo do que tem feito o presidente norte-americano Donald Trump.

5.6.2. Estratégias de atuação

As *estratégias de atuação* (HOOD, 2014), diferentemente das *estratégias de manipulação* que vimos anteriormente, são amplamente manejáveis por qualquer nível hierárquico de agentes públicos. Enquanto a *manipulação* é amplamente utilizada por agentes políticos, as de *atuação* estão ao alcance de todos.

Por *estratégias de atuação*, quer-se significar a atribuição ou desvio da responsabilização a outros agentes públicos ou a pessoas estranhas à Administração. A partir da percepção da elevada probabilidade de responsabilização do gestor público, é natural que este tenda a responsabilizar outrem quando as coisas não corram bem, passando a utilizar a técnica de eleger *bodes expiatórios* ou, em nosso universo tupiniquim: *bois de piranha*.³²

O interessante da tática de *atuação* é que, diferentemente da *manipulação*, seus resultados são obtidos tanto no universo da política como na responsabilização jurídica *stricto sensu*, quer nas ações de improbidade, processo crime, quer perante a apuração administrativa no âmbito dos tribunais de contas. Com efeito, a estratégia de atuação e seus consectários podem efetivamente blindar o agente público da responsabilidade civil, política, criminal ou administrativa.

Com o fito de obter-se o desvio de responsabilidade, essas técnicas podem valer-se da delegação organizativa de responsabilidades, ou mesmo na privatização ou terceirização³³ de certas atividades que passam a ser executadas pela iniciativa privada, e não mais diretamente pelo Poder Público. A partir disso, a lógica da

32. Apenas para esclarecer os que desconhecem essa antiga prática pecuarista, a escolha do “boi de piranha” consiste em estratégia para atravessar rebanhos nos rios cheios de piranhas (vovozes peixes cujo *habitat* são a Amazônia e o Centro-Oeste brasileiro). Para tanto, elege-se um boi solitário para fazer a travessia do rio. Ao fazê-lo, o boi é devorado pelo cardume de piranhas em frenesi e os demais integrantes da manada podem atravessar ilesos noutro ponto do rio. A metáfora traduzida para o âmbito da Administração Pública é ainda mais feliz que a mundialmente conhecida expressão “bode expiatório”, de origem judaica.

33. Sobre o tema da terceirização na Administração Pública, Carolina Zancaner Zockun discorre sobre seus aspectos constitucionais e a sua instrumentalização para consecução das atividades estatais (ZOCKUN, 2014).

organização funcional da Administração Pública passa a ser a proteção de certos agentes políticos ou servidores, instaurando, assim, um novo e inquietante modelo organizativo.

Para melhor compreender essa eficácia, vamos analisar mais detidamente as variantes da técnica de atuação. Quatro tipos destacam-se: i) delegação; ii) reorganização defensiva; iii) associação coletiva nas decisões; iv) governo pelo mercado (HOOD, 2014, p. 98).

5.6.2.1. Delegação

A primeira delas: i) *delegação*, pode ser extremamente eficaz em nosso modelo organizativo e no modo de responsabilização dos agentes público no Brasil. Consiste na estruturação formal da cadeia decisória longe das mãos daqueles que estejam em posição hierarquicamente superior, e que poderiam ser responsabilizados pela prática de atos administrativos.

Um exemplo permite a clara compreensão do que estamos a dizer. É muito comum que nos municípios brasileiros as autoridades que deflagram e homologam (art. 38, VII da Lei 8.666/93) procedimentos licitatórios sejam os prefeitos municipais. Tal função é inglória porque esses agentes políticos, de regra, não têm a mínima ideia daquilo que estão assinando, tanto por confiarem nos seus assessores, que dizem estar tudo regular, como por carecerem de formação jurídica, sem condições técnicas de compreender o acerto ou desacerto dos referidos procedimentos ou atos administrativos que estejam a subscrever. Aliás, mesmo que tivessem formação técnica, isso ainda seria difícil, pois a proliferação de entendimentos sobre os temas de licitação no Brasil beira a insanidade.

Dentro dessas disfuncionalidades do sistema de controle em nosso País, uma vez que surja qualquer irregularidade ou ilegalidade nesses procedimentos licitatórios, os órgãos de controle partem da premissa de que, como o agente político assinou a deflagração ou homologação do certame, que a responsabilidade é sua. É bem verdade que, mais recentemente, os integrantes das Comissões Permanentes de Licitação ou Pregoeiros vêm sendo indicados como litisconsortes passivos nessas demandas, mas a regra ainda é incluir ou chamar exclusivamente os prefeitos como responsáveis.³⁴

34. As razões dessa predileção são de difícil explicação. A primeira hipótese é que, como o prefeito é agente político com visibilidade midiática, isso destacaria o trabalho dos agentes de controle externo no Brasil e a valorização do seu papel perante a sociedade civil e a mídia. A segunda hipótese é que os servidores efetivos de segundo escalão contam com maior beneplácito dos órgãos de controle, se comparados aos agentes políticos, como já vimos anteriormente, além de não chamarem tanta atenção em comparação aos agentes políticos. Esses fatores levam à maior apetência dos órgãos de controle externo pela “carne” dos prefeitos, mais que

Para prevenir esses efeitos danosos, a *estratégia de delegação* consiste em delegar a outros servidores ou agentes públicos (ex.: secretário municipal de administração) a responsabilidade por deflagrar ou homologar procedimentos licitatórios. Para tanto, se pode enviar projeto de lei ao parlamento municipal visando alterar a norma de competência quanto à subscrição desses atos administrativos por outras autoridades, ou mesmo editar decretos (se assim as leis orgânicas ou demais normas municipais permitirem) para elegerem outros ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança para exercerem esse espinhoso mister nas licitações públicas. Utilizando da metáfora aqui já apresentada, servem de verdadeiros *bois de piranha* para que certos agentes públicos possam cruzar indenes as turbulentas águas da Administração Pública brasileira.

Veja-se que essa estratégia nada tem de ilegal. Muito pelo contrário. Pode ser utilizada pelos agentes políticos para protegerem-se de quaisquer consequências jurídicas desfavoráveis, especialmente no âmbito do Judiciário e dos tribunais de contas, eximindo sua responsabilidade por nunca ter “tocado” nesses procedimentos administrativos. Tal estratégia também pode ser utilizada por servidores públicos de segundo escalão, para delegar a outros servidores tais responsabilidades, desde que a lei assim o possibilite.

Claro que, do modo disfuncional como é exercido o controle externo no Brasil, nem mesmo tal estratégia poderá assegurar de todo a irresponsabilidade dos agentes políticos, pois sempre se poderá utilizar da premissa – equivocada – de que o agente público que ocupa o ápice da estrutura administrativa não poderia “desconhecer” tais irregularidades aduzindo-se culpa *in eligendo* ou *in vigilando*.

A despeito disso, a estratégia de delegação pode revelar-se poderosa armadura na proteção de certos agentes em desviar os golpes que lhes são desferidos a outros de hierarquia inferior. Por certo que essa estratégia não elimina a responsabilização, apenas a transfere a outros agentes públicos. Esse aspecto leva à maior eficácia da estratégia, porque, de toda sorte (ou azar), alguém será condenado, e os órgãos de controle poderão ficar com a sensação de dever cumprido por terem condenado alguém.

5.6.2.2. Reorganização defensiva

Também a estratégia de ii) *reorganização defensiva* consiste na organização da administração pública de modo desordenado ou de modo a confundir quem

a qualquer outro cargo da República, especialmente porque aos demais chefes do Executivo (governadores e Presidente) é bem mais difícil ou restrito o exercício o controle externo, quer pela importância política de tais cargos, quer pela limitação de competência das autoridades que podem processá-los.

efetivamente deve ser responsabilizado, em razão de constantes mudanças organizativas e com consequente dificuldade em encontrar responsáveis. Um dos tipos mais frequentes dessa estratégia é a instituição de constantes mudanças nos cargos governamentais (ministros ou secretários) de modo que, quando surja a crise, já não se possa mais culpar os agentes públicos que estejam efetivamente à frente da pasta. Também pode ocorrer com a impessoalização dos atendimentos aos cidadãos, de modo que, quando são atendidos por um servidor, já não o serão posteriormente, dificultando saber de quem efetivamente é a responsabilidade pelo mau funcionamento dos serviços públicos (HOOD, 2014, p. 108-110).

5.6.2.3. Coletivização das decisões

Ainda dentro das estratégias de atuação, encontramos a utilização da iii) *coletivização das decisões*, em que a ideia é coletivizar e compartilhar ao máximo a tomada de decisão, de modo a desviar-se individualmente de qualquer responsabilização. Tal medida permite que a decisão seja adotada não de modo unipessoal, mas através de conselhos ou grupos, visando compartilhar responsabilidades entre seus integrantes ou entre aqueles que atuam de modo cooperativo nas organizações.

Nessa linha, observamos que, no Brasil, já se começa a utilizar dessa técnica, a exemplo dos advogados públicos que atuam na atividade consultiva de estados³⁵ ou municípios, através da subscrição coletiva de pareceres jurídicos por todos os integrantes das respectivas procuradorias, ou mesmo na exigência de unanimidade do corpo de procuradores no entendimento jurídico a ser adotado, de modo – senão para eximir – a compartilhar os riscos decisórios na atuação do parecerista.

As licitações públicas novamente podem ilustrar a prática de a autoridade apenas subscrever atos que sejam da sua competência se amparados pelo respectivo parecer jurídico, de modo que a autoridade possa dizer – caso venha a responder juridicamente – que apenas o fez por conta da orientação de sua equipe, e equipe qualificada e dos quadros permanentes da Administração.³⁶

35. Durante certo tempo, a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC adotou essa técnica de compartilhamento e subscrição dos pareceres jurídicos pelo Colégio dos Procuradores, ainda que seja escolhido um parecerista para ser o relator da matéria, de modo a pulverizar responsabilidades pela emissão de parecer.

36. A jurisprudência vem justamente ao encontro dessa efetiva estratégia de desvio de responsabilização, pois é sabido que, quando o administrador decide com base em parecer ou orientação jurídica, não poderia ser responsabilizado. Como decidiu pelo Ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR FEDERAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (Art. 89 DA LEI Nº 8.666/93). AUDIÇÃO PRÉVIA DO ADMINISTRADOR À PROCURADORIA JURÍDICA,

5.6.2.4. Governo pelo mercado

Por fim, ainda nas estratégias de atuação, a técnica de *iii) governo pelo mercado* se demonstra hábil estratégia de atuação para fuga da responsabilização. Nesse

QUE ASSENTOU A INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. Art. 395, INCISO III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. A denúncia ostenta como premissa para seu recebimento a conjugação dos artigos 41 e 395 do CPP, porquanto deve conter os requisitos do artigo 41 do CPP e não incidir em nenhuma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. Precedentes: INQ 1990/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 21/2/2011; Inq 3016/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 16/2/2011; Inq 2677/BA, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 21/10/2010; Inq 2646/RN, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 6/5/010. 2. O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (“Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”) atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação. 3. *In casu*, narra a denúncia que o investigado, na qualidade de Diretor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, teria solicitado, mediante ofício ao Departamento de Controle e Licitações, a contratação de bandas musicais ante a necessidade de apresentação de grande quantidade de bandas e grupos de shows musicais na época carnavalesca, sendo certo que no Diário Oficial foi publicada a ratificação das conclusões da Procuradoria Jurídica, assentando a inexigibilidade de licitação, o que evidencia a ausência do elemento subjetivo do tipo no caso sub judice, tanto mais porque, na área musical, as obrigações são sempre contraídas *intuitu personae*, em razão das qualidades pessoais do artista, que é exatamente o que fundamenta os casos de inexigibilidade na Lei de Licitações – Lei nº 8.666/93. 4. Denúncia rejeitada por falta de justa causa – art. 395, III, do Código de Processo Penal (Inq 2482, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012).

Idêntica orientação tem sido prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. Art. 89, DA LEI N. 8.666/93. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO E DE ELEMENTAR DO TIPO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I – A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

II – O recorrente foi denunciado por dispensa irregular de licitação, prevista no art. 89, da Lei n. 8.666/93, em razão da contratação direta de artistas para as comemorações do centenário de emancipação do Município de Conceição do Rio Verde/MG.

[...]

IV – Ademais, não se verifica a existência de vontade livre e consciente dirigidas à prática da conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais, uma vez que o recorrente

caso, os governos partem para privatizações e subcontratações, de modo a repassar a responsabilidade pelo mau funcionamento dos serviços públicos à iniciativa privada. Evidente que não se está a sustentar que o mote primeiro das privatizações e subcontratações seja a fuga da responsabilização, posto que questões econômicas quanto a eficiência e adequada prestação dos serviços podem ser a principal causa de delegação destes serviços públicos.

Todavia, é inegável que a atribuição dessas atividades econômicas ao setor privado traz consigo a conveniência de o Estado e seus dirigentes não assumirem diretamente os ônus da prestação de serviços, ainda que permaneça a sua titularidade. A terceirização de serviços é um modo de eximir-se – senão juridicamente – ao menos politicamente da responsabilização, pois sempre se poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Pesquisas apontam que a dispersão institucional de responsabilidade implica menor atribuição de culpa pelos cidadãos aos governos e seus fracassos (HOOD, 2014, p. 116). Igualmente no âmbito da responsabilização jurídica, parece-nos evidente que o governo pelo mercado pode implicar a responsabilização de terceiros

acautelou-se, consultando previamente o órgão competente sobre a inexigibilidade de licitação para depois promover a contratação direta dos artistas. “O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação” (STF – Inq n. 2482/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão, Min. Luiz Fux). Recurso ordinário provido para trancar a ação penal n. 0000181-64.2013.8.13.0177, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Conceição do Rio Verde/MG, pela atipicidade da conduta (RHC 48.916/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014).

Com efeito, no âmbito criminal, revela-se importante que o administrador tenha decidido com base em parecer jurídico, posto que não há nessas hipóteses consciência dos elementos subjetivos e objetivos do tipo penal, como destaca Cezar Roberto Bittencourt: “Em outros termos, a consciência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo deve ser real, efetiva, concreta, no momento da ação, sendo insuficiente mera possibilidade ou potencial consciência de tais elementos. Nesse sentido, fica completamente afastada essa consciência quando, por exemplo, o agente age respaldado em fundamentado parecer técnico-jurídico de assessoria especializada. Aliás, o parecer é, por si mesmo, a demonstração da ausência de consciência (e também de vontade) de infringir a norma proibitiva, é a comprovação do desejo de agir *secundum legis*, afastando, por conseguinte, o elemento subjetivo, ou seja, o *dolus*, e, por extensão, a tipicidade subjetiva. Eventual conclusão, posterior, em outras instâncias, de que a decisão foi equivocada e que era exigível licitação ou as formalidades dispensadas, não tem o condão de atribuir tipicidade ao comportamento que se respaldou em fundamentado parecer jurídico, pois, por óbvio, esbarra na ausência de dolo, na medida em que quem age escudado em estudos de experts não pretende violar a norma proibitiva, mas adequar-se a ela. Na verdade, admitindo que a conclusão posterior esteja correta, demonstrará somente que houve uma irregularidade (ou até mesmo uma ilegalidade) puramente administrativa, mas jamais uma infração penal, por falta de tipicidade subjetiva [...]” (BITTENCOURT, 2012, p. 161).

detrimentos dos agentes públicos, especialmente os agentes políticos, funcionando dessa estratégia como anteparo ou escudo protetor.

Todavia, as estratégias de atuação também encontram limites. Evidente que há decisões que não podem ser delegadas a terceiros, e mesmo as delegáveis podem não isentar de toda a responsabilidade da autoridade delegante, senão juridicamente (em que parece funcionar melhor), ao menos politicamente, pois nem sempre um chefe do Poder Executivo poderá isentar-se de responsabilidade política por decisões delegadas seus ministros ou de concessionárias que prestam serviços públicos.

5.6.3. Estratégias de política pública ou estratégias operacionais

As estratégias de políticas públicas ou operacionais visam organizar e estruturar a organização administrativa de modo a eliminar potenciais causas da responsabilização. Trata-se de manter processos operacionais que compreendem: i) *protocolização*, estabelecendo rotinas a serem cogentemente seguidas pelas autoridades; ii) o *gregarismo*, que consiste em decidir de modo coletivo, evitando a individualização da responsabilidade; iii) a individualização da responsabilização para *elementos externos*, a exemplo da sociedade civil, usuários, prestadores de serviço público; e iv) a *inação* ou *imobilismo decisório* (HOOD, 2014, p. 123-124).

5.6.3.1. Protocolização

A i) *protocolização* é largamente utilizada pela Administração Pública, mormente pelo avanço das tecnologias de informática, que fazem com que o cidadão tenha de seguir procedimentos-padrão com vistas a obter informações ou exercer seus direitos perante a Administração Pública.

A vantagem da estratégia para o gestor público é que a impessoalização do atendimento ao cidadão pela protocolização de requerimentos padronizados e a redução do exercício de competência discricionárias permitem que sempre se possa culpar (literalmente) o “sistema” de informática pelas decisões administrativas, reduzindo o risco ao administrador pela tomada de decisão.

Evidentemente que um elevado grau de ineficiência do sistema de protocolização leva à ineficácia dessa estratégia, podendo mesmo a potencializar, na medida em que as rotinas preestabelecidas não consigam atender minimamente às demandas dos cidadãos.

5.6.3.2. Gregarismo

O ii) *gregarismo* implica a adoção de decisões grupais, de modo a pulverizar a responsabilização. Não raro, pode ser detectado em situações em que a autoridade

decisora pode deliberar por si, mas prefere “colegiar” o processo decisório, quer formal, quer mesmo informalmente. Evidente que, para fins de evitar a responsabilização judicial, o ideal é que esses processos coletivos de decisão estejam formalmente regrados, de modo a eximir eficazmente a responsabilidade do gestor. Mas isso não impede a prática de medidas informais de decisão que visem demonstrar – em caso de questionamento da impessoalidade do administrador – que tomou sua decisão de modo isento e impessoal.

Exemplo disso é a prática de os agentes públicos atenderem os administrados, literalmente, de “portas abertas”, de modo que toda a equipe de servidores (e apoio) participe informalmente da conversa escutando seu inteiro teor. Tal técnica tem sido adotada, inclusive, por integrantes do Poder Judiciário. A publicidade desses diálogos, em última análise, visa a blindagem do agente público quanto à honestidade da sua conduta, tendo por testemunhas aqueles que o cercam, o que não deixa de ser espécie de estratégia de desvio de responsabilização. Como diz o adágio popular: “A mulher de Cesar não basta ser honesta, deve parecer honesta”.

5.6.3.3. Individualização da responsabilização ou eleição de bode expiatório

A técnica de iii) *individualização da responsabilização* ou eleição de um *bode expiatório* compreende importante técnica de fuga da responsabilização, ao eleger-se grupo ou indivíduo sobre o qual deverá cair a responsabilidade. Pode ser utilizada de cima para baixo (do superior hierárquico aos seus subordinados) ou mesmo de baixo para cima (dos subordinados ao superior hierárquico) (HOOD, 2014, p. 132-133).

Essa técnica, para sua plena eficácia, em geral é conjugada com outras, a exemplo das *técnicas de manipulação* por *delegação* administrativa, em que, estruturalmente (pela via legal ou infralegal), organiza-se previamente a Administração Pública com vistas a escolher qual o agente público será responsabilizado caso surja algum problema que demande reparação.

Tal técnica é, a princípio, intuitiva, com a negação da responsabilização e atribuição a outra pessoa ou grupo. Mas o que chama a atenção na atualidade é que, em um cenário de hiper-responsabilização dos agentes públicos, a técnica já é pensada antes mesmo que venha a ocorrer qualquer problema, pois a eleição de bodes expiatórios passa a ser considerada na organização administrativa e pensada na modelagem organizativa do ente.

5.6.3.4. Inação ou imobilismo decisório: a paralisia administrativa

A técnica da iv) *inação* ou *imobilismo decisório* vem crescendo cada vez mais em importância. Trata-se de fenômeno antigo, mas que atualmente assume novos contornos, consistindo simplesmente em negar atender a demandas dos cidadãos

ou situações que impliquem elevado risco. Ao deliberar sobre tema de elevado grau de responsabilização, a autoridade simplesmente “diz não” (HOOD, 2014, 134-137).

O assunto também foi tratado por Pierre Conesa no livro *Surtout ne rien décider: manuel de survie en milieu politique avec exercices pratiques corrigés* (CONESA, 2014)³⁷. O texto é ácido, provocante e atual. Ainda que o enfoque do autor tenha sido a sobrevivência no meio político pela arte da não decisão, e por isso mesmo sem maior aprofundamento quanto à responsabilização *jurídica* dos políticos, o texto chama atenção por diversas razões. A primeira delas, a percepção de que o fenômeno da paralisia decisória não acontece apenas em solo tupiniquim, mas também na França.

A despeito de Conesa tratar mais detidamente do tema, não podemos deixar de fazer menção do texto de Pierre Affuzzi *Pour une théorie politique de la non-décision*, que, antes mesmo de Conesa, já delineou aspectos fundamentais do imobilismo decisório em matéria de reformas administrativas (AFFUZZI, 2001).

O livro de Conesa pode ser resumido no seguinte parágrafo: “*Apprendre l’art suprême de la non-décision en laissant une trace dans l’histoire, tel est l’objet de ce petit ouvrage qui livre clés en main les techniques à connaître pour donner l’illusion de l’action sans jamais rien décider*” (CONESA, 2014, p. 17).

Conesa enfatiza a procrastinação das reformas administrativas como forma de sobrevivência no mundo da política. Mas esse adiamento decisório — por razões óbvias — não pode ser assumido explicitamente, pelo contrário, deve-se dar permanentemente impressão de se estar em constante ação e movimento. A ideia é deixar que as coisas “resolvam-se” por si, deixando temas espinhosos como reformas administrativas, previdenciárias ou quaisquer outros temas polêmicos, para o respectivo sucessor (CONESA, 2014).

Com efeito, uma vez adotada a técnica de não decisão, deve-se dar a ilusão da ação. Mas, como a inação aberta é politicamente arriscada e ilegal, fundamental o papel da comunicação para dar a ilusão da ação, seja através da progressividade, seja do aprofundamento do estudo da matéria controversa que aguarda decisão administrativa (AFFUZZI, 2001, p. 45).³⁸

37. A indicação desse texto decorreu da leitura do artigo O medo o ato administrativo, de Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (MASCARENHAS, 2016).

38. Como assevera Pierre Affuzzi: “Une fois la non-décision « adoptée », il est important de donner l’illusion de l’action. Une inaction avouée est politiquement risquée. Il faut que le politique conserve son apparente capacité de décision de crainte de perdre sa crédibilité. La communication joue alors pleinement son rôle. Différentes techniques peuvent être recensées. Considérons d’abord celle du report pour motif technique, qui prend habituellement deux formes: la progressivité ou l’approfondissement de la réflexion” (AFFUZZI, 2001, p. 45).

Também não se deve confundir a arte da não decisão com a indecisão. São coisas muito diferentes. Quem não quer decidir sabe muito bem o que está a fazer. Nada tem de indeciso. Utiliza-se da *não decisão* como tática planejada e programada.³⁹

Entre essas técnicas, podem ser destacadas: i) a demonstração da falta de urgência das reformas administrativas; ii) o anúncio de medidas ambiciosas; iii) a demonstração de que as medidas a serem adotadas exigem aprofundados estudos; iv) comunicação diária do governo para dar a impressão de permanente ação; v) quando todas as rotas de fuga para ação já tiverem sido esgotadas, sempre será possível criar a complexidade (CONESA, 2014, p. 29-45).

Nessa perspectiva de não ação, importante a utilização da participação popular como forma de se adiar as reformas ou decisões importantes, mas que podem trazer elevado ônus político à autoridade. Tal prática pode ser vista como deboche ao instituto da consulta pública enquanto forma de inserir o cidadão nas decisões da Administração, de modo a bloquear a possibilidade de decisão, razão pela qual não pode ser assumido abertamente (CONESA, 2014, p. 57-58). Mas a questão é mais complexa. Se, de um lado, podemos enxergar tal proceder como escárnio à participação popular, de outro, trata-se de efetivo medo em adotar decisões que possam repercutir na sua esfera política ou patrimonial do agente.

Nesse contexto, cunhou-se a expressão *Not In My Term Of Office* — NIMTO ou NIMTOO⁴⁰ (não em meu mandato), utilizada para decisões que não devem ser tomadas no curso do mandato.⁴¹ Essa expressão é a versão política da fórmula *Not In My Back Yard* — NIMBY (não em meu quintal), utilizada no Direito Ambiental para fazer alusão ao fato das populações não aceitarem projetos polêmicos em seus entornos, a exemplo de aterros sanitários.

39. Sobre a distinção entre indecisão e não decisão assim resume Pierre Conesa: “Un décideur indécis qui hésite entre plusieurs options peut finalement exprimer un choix. Le bonheur d’hésiter est de croire que l’on prend une décision avec la rassurante perspective de pouvoir ne pas en prendre. En revanche, la non-décision est un acte positif de refus, d’immobilisme, de contournement, mêlant technicité politique, communication habile, calinothérapie et traitement symptomatique. L’art de la non-décision se pratique comme la boxe chinoise, le tai-chi-chuan (la « boxe contre son ombre »). Le combat est simulé contre plusieurs adversaires imaginaires, les coups portés dans différentes directions doivent être élégants et parfaitement enchaînés. La satisfaction réside dans l’exécution la plus précise de la gestuelle” (CONESA, 2014, p. 22-23).

40. A terminologia NIMTO chamou atenção a partir do artigo O medo o ato administrativo, de Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (MASCARENHAS, 2016).

41. Acerca do tema, fazemos menção ao texto de Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas “Este fenômeno ganhou até uma sigla em inglês “NIMTO” (*not in my term of office*) para expressar exatamente a situação em que decisões sobre temas importantes, mas de extrema delicadeza política, são postergadas por agentes políticos, que consideram “melhor” (para si, e não para o interesse público) deixar que seu sucessor resolva o problema. Trata-se, portanto, de um medo de dupla face, que merece a atenção da doutrina (MASCARENHAS, 2016).

O imobilismo decisório também está ligado ao viés retrospectivo (*hindsight bias*) com que são escrutinados os atos administrativos pelos órgãos de controle externo. Diante dos riscos inerentes ao processo decisório, o agente público tende a tomar decisões burocráticas que preserve sua integridade patrimonial e pessoal.⁴²

Trata-se de fenômeno global, mas que varia no tempo e no espaço. No caso brasileiro, não se trata de mera arte da política ou em como sobreviver no meio político e alcançar altos cargos. Aqui se trata da própria sobrevivência civil, política e penal do agente público. A arte da não decisão no Brasil tem temperamentos inimagináveis noutros cantos do planeta. Ela passa a ser cogente, determinante e fundamental para a preservação do patrimônio pessoal, da honorabilidade e da liberdade do agente público.

A estratégia do imobilismo decisório brasileiro afeta a todos os agentes públicos, mesmo os servidores de carreira, que, por vezes, passam a ter mais medo que os próprios agentes políticos das consequências das suas decisões. Isso se explica porque o agente político, por vezes, está há pouco tempo na política e ainda não faz a mínima ideia dos riscos a que está sujeito em sua liberdade e patrimônio. Já os servidores de carreira, mais “calejados” dos perigos a que estão expostos, evitam a todo custo decidir ou subscrever qualquer documento que possa lhes trazer alguma responsabilização decisória.

O exemplo clássico é a assinatura dos aditivos contratuais. Encontrar agentes públicos dispostos a assinar aditivos contratuais não é tarefa fácil.⁴³ O tema das licitações públicas é deveras ilustrativo do que estamos a dizer, pois, além de muitos controladores presumirem irregularidades nos processos licitatórios, é nas licitações que são alocadas boa parte das verbas públicas, impondo um alto ônus a quem de algum modo está envolvido no processo licitatório.

42. Esse fenômeno foi bem abordado por Daniel Kahneman, que esclarece que o controle com viés retrospectivo leva a soluções burocráticas: “Com a adesão a procedimentos operacionais padronizados é difícil de ser analisada *a posteriori*, os tomadores de decisão que esperam submeter suas decisões a um exame retrospectivo são motivados por soluções burocráticas — e a uma relutância extrema em assumir riscos. Como processos por negligência se tornariam mais comuns, os médicos mudaram seus procedimentos de múltiplas formas: pedindo mais exames, encaminhando mais casos para especialistas, aplicando tratamentos convencionais mesmo quando há pouca probabilidade de serem de alguma ajuda. Essas atitudes protegeram mais os médicos do que beneficiaram os pacientes, criando o potencial para conflito de interesse. O aumento de responsabilidade é uma faca de dois gumes” (KAHNEMAN, 2012, p. 256).

43. Acerca das dificuldades burocráticas nas alterações contratuais e do risco que isso gera aos agentes públicos, fazemos referência a Joel de Menezes Niebuhr, no seu *Licitação pública e contrato administrativo*. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 893-901.

Esse imobilismo total ou parcial pode refletir-se em pareceres técnicos ambíguos, em que se aponta o caminho legal para a resolução dos problemas, mas, ao mesmo tempo, põe em dúvida a solução técnica adotada, de modo a resguardar-se quando surgirem questionamentos quanto ao teor do parecer.

Outro efeito deletério é a consagração do indeferimento generalizado como forma de autoproteção dos agentes públicos: A estratégia de imobilismo decisório, paralisia decisória, ou técnicas de não decisão podem ter efeitos devastadores sobre a boa gestão pública, mas que podem preservar com grande vantagem os bens jurídicos do gestor ou do ordenador de despesas e dos demais públicos que atuam na Administração.

Como dizia Marcos Juruena: “dorme tranquilo quem indefere”.⁴⁴ Essa mesma lógica já fora percebida por Roberto Dromi, ao estabelecer seu *Código do Fracasso da Administração Pública*, cujos artigos são os seguintes: “artículo 1º: *no se puede*; artículo 2º: *en caso de duda, abstenerse*; artículo 3º: *si es urgente, esperar*; artículo 4º: *siempre es más prudente no hacer nada*” (DROMI, 1995, p. 35).

O fenômeno da não decisão na Administração Pública não é novo. Mas é lícito concluir que há novidades na estratégia. É que a implementação maciça dos controles da Administração Pública implica aumento exponencial dos riscos. Se antes era uma mera cogitação o gestor público ser cobrado e responsabilizado por suas decisões, hoje isso é muito mais intenso; quer pelo aumento da informatização e grau de acuidade dos sistemas de controle, quer pela participação mais intensa do cidadão no controle social; seja por cobertura midiática cada vez mais intensa; ou, ainda, pela comunicação instantânea das redes sociais.

Mais uma vez, salientamos que o problema não está em ser “cobrado” pela sociedade ou controlado. É óbvio que o exercício de função administrativa implica *accountability* e eventual responsabilização. Afinal, não se imagina que alguém possa exercer tais funções sem ônus. O problema desenvolvido ao longo deste texto está no ônus disfuncional.

No caso brasileiro, a possibilidade de ações de improbidade, processos crime ou decisões condenatórias dos tribunais de contas fazem que o gestor tenha não apenas aversão, mas pânico em decidir, pois não se trata de mera reprimenda social ou administrativa, mas de pesadas consequências ao patrimônio pessoal, aos direitos políticos fundamentais ou mesmo à própria liberdade ambulatoria decorrente de erros que deveriam ser escusáveis.

44. RIBEIRO, Leonardo Coelho. “Na dúvida, dorme tranquilo quem indefere” e o Direito Administrativo como caixa de ferramentas. Disponível em: <<http://www.direitodoestado.com.br/columnistas/leonardo-coelho-ribeiro/na-duvida-dorme-tranquilo-quem-indefere-e-o-direito-administrativo-como-caixa-de-ferramentas>>. Acesso em: 15 de outubro de 2018.

Denmais disso, a técnica de indeferimento e consequente paralisia administrativa adquire importante variante no Brasil, ligada ao desequilíbrio entre as funções estatais por qual passamos. É que o gestor público, mesmo sabendo que é da sua competência decidir, prefere indeferir justamente para que o administrado busque o atendimento de seu pleito pela via judicial. Como veremos em seguida, o agente público, sabendo que estará sujeito à responsabilização disfuncional, pouco importando o que decida, prefere deixar ao Judiciário, o ônus em decidir e substituir por via oblíqua o lícito exercício da função administrativa.

5.6.4. Estratégias de judicialização ou substituição decisória externa

As estratégias de judicialização ou substituição decisória externa significam a atribuição a outros poderes ou órgãos constitucionais do poder de decisão exclusivo do administrador com o fito de proteger-se jurídica e politicamente. De certo modo, essa estratégia é o reconhecimento da falência da divisão funcional dos poderes e a tentativa de utilizar-se dessa disfunção para blindagem do agente ou autoridade decisória.

Esse fenômeno também é observável na política, como bem assinala Ran Hirshl,⁴⁵ tendo sido intuitivamente utilizada essa técnica pela classe política de modo a *redirecionar a culpa* e de maneira a terceirizar os problemas ao Judiciário.

45. Vale trazeremos a íntegra do pensamento de Ran Hirshl: “Do ponto de vista dos políticos, a delegação de questões políticas controversas para os tribunais pode ser um meio eficaz de transferir responsabilidade, reduzindo os riscos para eles mesmos e para o aparato institucional no qual operam. O cálculo dessa estratégia de “redirecionamento de culpa” é bastante intuitivo. Se a delegação de poderes é capaz de aumentar a legitimidade e/ou diminuir a culpa atribuída aos atores políticos pelo resultado da decisão da instituição delegada, então tal delegação pode beneficiar os atores políticos. No mínimo, a transferência de ‘abacaxis’ políticos para os tribunais oferece uma saída conveniente para políticos incapazes ou desinteressados em resolver essas disputas na esfera política. Essa transferência também pode representar um refúgio para políticos que buscam evitar dilemas difíceis, nos quais não há vitória possível, e/ou evitar o colapso de coalizões de governo em estado de fragilidade ou de impasse. Da mesma forma, a oposição pode buscar judicializar a política (por exemplo, peticionando contra políticas públicas do governo) para dificultar a vida do governo da vez. Políticos da oposição podem recorrer ao Judiciário na tentativa de aumentar sua exposição na mídia, independentemente de o resultado final da disputa ser ou não favorável. Com frequência, por trás da transferência para o Judiciário de questões envolvendo mudanças de regime encontraremos uma busca política por legitimidade (considere, por exemplo, a já mencionada legitimação do golpe de Estado militar pela Suprema Corte do Paquistão, em 1999). Estudos empíricos confirmam que, na maioria das democracias constitucionais, tribunais superiores têm mais legitimidade e mais apoio da opinião pública do que virtualmente todas as outras instituições políticas. Isso é verdade mesmo quando os tribunais se engajam em manifestações explícitas de jurisprudência política (HIRSCHL, 2013, p. 165).

quer porque pode oferecer saída conveniente, quer porque os políticos não têm capacidade ou mesmo interesse em resolver certos problemas na esfera da política (HIRSCHL, 2013, p. 165).

A utilização dessa técnica pelas autoridades políticas e administrativas proliferar-se cada vez mais em solo brasileiro. Trata-se de fenômeno conhecido por qualquer administrador, mas que nunca foi tratado como estratégia típica de fuga da responsabilização nos termos aqui propostos.

Vejamos como funciona. Imaginemos que um cidadão ou mesmo alguém que mantenha contrato com a Administração Pública venha a pleitear algum direito subjetivo. Para tanto, expõe suas razões de direito e, estando a matéria dentro do núcleo de competência da Administração (ex.: outorga do direito de construir ou mesmo reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos).

Na premissa que o Direito claramente agasalhe o pleito do cidadão ou contratado, dever-se-ia esperar o pronto atendimento do requerimento e o consequente deferimento do pedido. Todavia, a depender do grau de risco de responsabilização pela decisão, a autoridade pública, sem qualquer pudor, por vezes revela informalmente que concorda plenamente com as razões apresentadas, mas esclarece que, dados os riscos ou problemas que tal decisão poderá fazê-lo incorrer e que seria melhor que o contratado procurasse resolver judicialmente o problema. É dizer: se o Judiciário mandar, cumpro.

Mesmo situações mais curiais que demandariam imediata reparação por danos causados aos particulares pela Administração e que poderiam ser ressarcidas administrativamente encontram enorme resistência, pois, se o ordenador primário de despesas ordenar seu pagamento, estará sujeito às ações de improbidade que questionam o *quantum* indenizatório pago ou mesmo discussões quanto à extensão do efetivo prejuízo sofrido pelo particular e o que fora efetivamente por ele percebido.⁴⁶

Por mais que tal modo de pensar seja paradoxal e absolutamente desconcertante, do ponto de vista da fuga da responsabilização, a autoridade está absolutamente correta. Afinal, se a decisão sobre temas mais sensíveis for adotada ou homologada em processo judicial pelo Judiciário, rigorosamente nada poderá lhe acontecer. Terá simplesmente cumprido a decisão judicial.

A grande vantagem é que a “terceirização” da decisão ao Judiciário, de uma só vez, libera o administrador dos ônus de decidir. Curiosamente, o acerto ou desacerto daquilo que será decidido pelo Judiciário não sujeitará esse Poder a qualquer

46. Exemplo de norma que prevê o pagamento administrativo dos danos sofridos pelos particulares é o disposto nos artigos 65 a 71 da Lei Estadual Paulista de Processo Administrativo, a Lei 10.177/98.

onus ou responsabilidade por sua decisão, pois o exercício disfuncional de funções administrativas por outros poderes no Brasil não gera na casuística qualquer dever de reparação.

Mas não é apenas ao Judiciário que se delega a decisão que caberia fundamentalmente ao administrador. Os demais órgãos de controle estão cada vez mais decidindo em nome da Administração, exercendo obliquamente função administrativa que lhe seria defesa.

Se tomarmos por exemplo o Ministério Público, verificaremos – com preocupação – que muitas “recomendações” ou Termos de Ajuste de Conduta – TAC por ele encetados, em geral, visam definir políticas públicas e decisões que competiriam apenas à Administração. Não que tais atuações ministeriais não sejam possíveis ou desejáveis. Por vezes o são. Mas tem-se percebido que tais recomendações ministeriais, em alguns casos, são seguidas da explícita ameaça da interposição de ações civis públicas ou ações de improbidade, se não forem seguidas à risca.

Nessa hipótese, tem-se a substituição decisória pelo Ministério Público sem que haja efetiva vontade do agente em o fazer, mas, diante das circunstâncias do caso e da possibilidade de sofrer ações que podem repercutir nos seus direitos políticos fundamentais e das consequências patrimoniais, o agente prefere a substituição decisória externa “coercitiva” como modo de autoproteção.

5.6.5. Estratégia de relacionamento informal interadministrativo

Essa estratégia é mais uma daquelas amplamente adotadas na Administração Pública brasileira, mas até hoje não sistematizadas enquanto estratégia formal visando a fuga da responsabilização. É praticada amplamente por chefes de poderes visando blindar-se quanto a eventual atuação controladora. Por estratégias de relacionamento informal interadministrativo⁴⁷, queremos significar a adoção por

47. O conceito de relação interadministrativa nos parece adequado para demonstrar que tais relações jurídicas envolvem entidades administrativas distintas, que não deixam de ser espécies de relação jurídica administrativa. As relações interadministrativas podem envolver atividades entre entes dotados de personalidade jurídica própria a exemplo da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, como entre órgãos despersonalizados com particulares, no sentido mais amplo de Administração concertada, a exemplo dos termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público e particulares (BITENCOURT NETO, 2017, p. 202). Essas relações interadministrativas, quando ocorrem entre órgãos, constituem relações interorgânicas. Nesse sentido caminha a doutrina de Alexandra Leitão: “O conceito de relação jurídica administrativa proposto aplica-se às relações jurídicas interadministrativas, com a particularidade de estas se estabelecerem entre duas ou mais entidades administrativas, sendo, por isso, definidas em função de um critério subjectivo. Aliás, alguns dos Autores citados salientam a circunstância de as relações administrativas se poderem estabelecer quer entre a Administração e um privado, quer entre dois pólos dentro da Administração Pública. Por

parte do agente público – mormente o agente político – de atuação informal junto aos órgãos de controle externo que poderão, potencialmente, interferir no julgamento de processos que lhe digam respeito, ou nos atos administrativos a serem emanados pela Administração Pública, visando tanto demonstrar o acerto de sua decisão como buscar a orientação, consulta⁴⁸ ou aprovação informal daqueles atos administrativos, numa relação jurídica concertada⁴⁹.

É que o agente público, sabedor de que seus atos administrativos serão objeto de controle externo, precisa sensibilizar e esclarecer ao agente público controlador sobre as peculiaridades do seu caso e chamar a atenção das razões que o levaram a decidir desse ou daquele modo. Em regra, isso pode ser realizado formalmente, mas, no âmbito das relações informais, se pode justificar, esclarecer e precaver-se quanto à legalidade dos atos.

Como exemplo de relacionamento informal interadministrativo, mencionamos o contato junto aos órgãos de controle para prestar informações e buscar orientações de como melhor proceder. O exemplo clássico são os editais de licitação. É sabido que, antes mesmo de seu lançamento, os editais de licitação são submetidos informalmente aos órgãos de controle de modo a melhor depurar e lapidar o edital a ser lançado. Tal estratégia visa prevenir que as decisões administrativas

outro lado, as relações interadministrativas podem constituir-se não só entre pessoas colectivas públicas, mas também entre órgãos, dando lugar, respectivamente, a relações intersubjectivas e a relações interorgânicas. Assim, cumpre, nesta fase, analisar dois problemas distintos: por um lado, a questão das relações jurídicas interorgânicas; e, por outro lado, o conceito de pessoa colectiva pública” (LEITÃO, 2015, p. 29).

48. O fenómeno das consultas pelos administradores ao Tribunal de Contas da União de modo a procurar a aquiescência prévia do TCU já foi tratado por André Braga, que revela perfeitamente o fenómeno das estratégias de relacionamento informal interadministrativo: “No fim de 2018, em julgamento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o ministro Bruno Dantas afirmou que, em algumas situações, o governo federal apresenta consultas ao TCU com o intuito de obter um mero ‘conforto espiritual’ (sessão plenária de 12/12/2018). (...) Mas o receio da sanção parece não ser a única explicação. Consultas aparentemente sem sentido também podem ser um efeito colateral da expansão das atividades do TCU nos últimos 25 anos. (...) Nesse ambiente, obter manifestação prévia do TCU – por meio de consulta formal ou de alinhamento informal – é o caminho mais racional para se garantir segurança jurídica às partes envolvidas. (...) Ao buscar livrar a administração pública de todo e qualquer pecado, o TCU convida os fiéis gestores à sua porta” (BRAGA, 2019).

49. Sobre o conceito de administração concertada, calham as considerações de André de Laubadère: “Ainsi entendue, la concertation est volontiers présentée comme une caractéristique nouvelle de l’administration économique d’aujourd’hui. En particulier, selon ses promoteurs et théoriciens, elle se distingue, en la dépassant, de la technique classique de la représentation des intérêts, en ce qu’elle voudrait ne pas se contenter de permettre aux ‘gens de métier’ de faire entendre leur voix mais atteindre, de manière plus permanente et plus profonde, par un travail collectif, une élaboration en commun des objectifs et des moyens” (LAUBADÈRE, 1974, p. 413).

sejam bloqueadas pelos órgãos de controle, pois, se não houver tais tratativas informais, o edital será fatalmente impugnado⁵⁰, impondo, assim, a necessidade de se interagir com vistas à obtenção da colaboração dos controladores.

O conceito de atividade administrativa informal pode compreender diversos sentidos. Segundo Carla Amado Gomes, numa primeira acepção: *informal pode ser todo o acto ou regulamento destituído de imperatividade, ou qualquer acordo desprovido de vinculatividade formal recíproca*. Numa segunda acepção, *informal pode ser todo acto resultante de um desprocedimentalização, total ou parcial, eventual ou habitual, real ou virtual*. Já em uma terceira acepção seria *o acto/actuação gerador de efeitos puramente psicológicos (...) de um acto em tudo idêntico ao administrativo todavia destituído de imperatividade (...) constitui uma expectativa sustentada no princípio da proteção da confiança*. Finalmente, numa quarta acepção, informal seria *a aproximação entre actuações informais e operações materiais, decorrentes da ausência de efeitos jurídicos imediatos de ambas* (GOMES, 2013, p. 382-391).

O relacionamento informal interadministrativo não deve ser confundido com o velho fisiologismo, que consiste em indesejável troca de favores ou benefícios pessoais entre os integrantes dos parlamentos, Executivo ou Judiciário, fruto de vetustas relações de poder que ainda sobrevivem.

Trata-se, portanto, de algo diferente. Não se visa troca de favor algum. Nesse sentido, pensamos existir espaço republicano para a prática de relacionamentos informais interadministrativos desde que realizados de boa-fé, de modo ético e probo, dentro dos estritos princípios que norteiam a Administração Pública. Está assentado nos princípios da cooperação, colaboração e coordenação. As

50. A suspensão dos editais de licitação pelos tribunais de contas tem por fundamento a teoria dos poderes implícitos. A esse propósito, fazemos alusão à decisão do STF no MS 24.510, da relatoria da Min. Ellen Gracie: "(...) a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público. Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso *McCulloch v. Maryland* (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. (...) É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República" (MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 19-11-2003, Plenário, DJ de 19-3-2004).

estratégias de relacionamento informal interadministrativo estão vinculadas ao Direito e, conseqüentemente, à juridicidade, posto que, se tal concertação afrontar tais vinculações jurídicas, passará a ser ilícita (BITENCOURT NETO, 2017, p. 205).

Sempre haverá o risco de disfuncionalidades, com a imposição pelos órgãos de controle da sua visão ou modelagem jurídica em detrimento da eleita pelo administrador, ainda que a última seja mais adequada. Mas, a despeito disso, a estratégia vale a pena especialmente para prevenir desgastes e mesmo viabilizar a ação administrativa com a vantagem da blindagem do administrador. Com efeito, a despeito de a relação entre o gestor e os órgãos de controle dar-se sob o viés dialógico, pode assumir caráter impositivo pelos órgãos de controle, posto que eles detêm o poder de sancionar o administrador. Assim, novamente o administrador "terceiriza" sua tarefa decisória, não em nome de uma melhor gestão ou na busca da melhor decisão administrativa, mas simplesmente como estratégia de evasão de responsabilização.⁵¹

As relações informais interadministrativas que apontamos como salutares são fruto das chamadas: *relações informais da administração pública*, bem trabalhadas por Suzana Tavares da Silva⁵². Essas relações informais têm juridicidade e podem ser incorporadas nas formas de atuação material administrativa na busca do

51. Esse aspecto é particularmente destacado por Eduardo Jordão no texto *Administração dialógica ou amedrontada?*, apontando riscos na alegada eficiência da "conjunção de expertises", pois uma segunda opinião também pode prejudicar a atuação desenvolvida da Administração, sugerindo, ainda: "Se se quer um controlador atuando ao lado do administrador, o ideal é que se lhe retire o poder de sanção. Então teríamos de fato duas instituições dialogando como iguais, sem que uma delas ostente um tapete na mão, como a lembrar à outra da conveniência de aceder à sua opinião" (Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/control-publico/administracao-dialogica-ou-amedrontada-22052019>> Acesso em 22 de maio de 2019).

52. Assim expõem a autora: "As actuações administrativas informais devem, em nosso entender, ser integradas no léxico e na gramática do direito administrativo, sobretudo do novo direito administrativo. Começemos por recordar os vários significados propostos pela doutrina alemã. Para Bohne, as actuações administrativas informais consubstanciavam uma alternativa de facto (*faktische Alternative*) às actuações formais e, nessa medida, um conjunto de compromissos não vinculativos. Na sua perspectiva, as actuações informais centravam-se em relações de troca entre entidades públicas e grupos sociais (empresariais, colectivos, de interesses). Correspondiam a formas de actuação eficazes na prossecução de certos objectivos mais complexos ou que aparentemente originariam maior resistência, por se revelarem mais flexíveis e, sobretudo, não vinculativas. O objectivo final era transpor esses resultados para formas tradicionais, dotadas de vinculatividade. Com base nestes elementos, Bohne acentuava a necessidade de modificar as formas tradicionais da actuação administrativa, tornando-as mais flexíveis e capazes de assegurar uma melhor resposta às exigências da complexidade pós-moderna" (SILVA, 2008, p. 905).

interesse público. Trata-se do reconhecimento de que juridicamente a atividade administrativa não ocorre apenas pelas vias *formais*, mas especialmente por *atuações informais* que – mesmo não vinculativas – expressam materialmente a realidade administrativa brasileira. Referidas relações informais constituem atuação flexível de cunho complementar e preparatório das decisões administrativas ou mesmo das medidas de controle impostas sobre a Administração (SILVA, 2008).

Essas relações informais não deixam de ser relações jurídico-administrativas.⁵³ Portanto, antes que sejam rotuladas como informais em sentido pejorativo, são expressões de relação entre sujeitos públicos ou privados com vistas a realização e concreção do interesse público regradas pelo Direito Administrativo (LEITÃO, 2015, p. 27-29).

É bem verdade que, apesar de reconhecer espaço à atuação informal na Administração Pública, Alexandra Leitão busca na sua formulação para os contratos interadministrativos maior limitação das atuações informais, tendo em conta que elas não contribuiriam para a certeza e a segurança jurídica e de eficiência e eficácia na ação pública. Mas, a despeito disso, a autora não nega o fenômeno da informalidade das relações interadministrativas (LEITÃO, 2015, p. 18).

Exemplo dessas atividades informais na administração pública é a pesquisa de mercado realizada pela Administração através das suas Comissões Permanentes de Licitações – CPL ou mesmo por pregoeiros, que implicam contato administrativo informal com diversas empresas que potencialmente poderão participar do certame, justamente para obter-se – informalmente – o preço de mercado do objeto a ser licitado.

Esse direito administrativo cooperativo, embora tenha suas principais manifestações na própria atividade administrativa, seja com as entidades ou órgãos da Administração Pública, encontra espaço noutros domínios, como nos processos sancionatórios movidos contra a Administração ou seus agentes pelos órgãos de controle externo. Esse modo de atuar visa implementar modelagem concertada da Administração Pública.

Nesse sentido, é fundamental compreender as relações informais interadministrativas no âmbito da relação controlador-controlado. Afinal, a cooperação

permite melhores resultados com a superação de um modelo autoritário e inflexível, estabelecendo maior interação entre entes públicos e seus agentes e o atingimento mais eficaz do interesse público.

Não se pode mais imaginar que possam os órgãos de controle fazer mero “controle externo de gabinete” distantes da realidade administrativa. Devem assumir que suas funções compreendem não apenas a fiscalização, mas, sobretudo, a construção de relação jurídica cooperativa na busca de soluções mais adequadas à satisfação de necessidades coletivas. Essa “virada de Copérnico” é fundamental para definir nova forma de compreensão do sistema de controle administrativo. Distancia-se de um modelo de controle que tem por centro gravitacional os órgãos de controle e as sanções deles emanadas e passa-se a um modelo de *rede* da Administração *multinível*⁵⁴, com interação cooperada dos diversos “corpos celestes” no sistema de controle.

Por certo que, nesse modelo, a possibilidade de sanções administrativas não perde sua importância, mas o apoio e a regulação responsiva dos órgãos de controle externo na busca do interesse público não podem mais ser vistos com cômoda imposição de nulidades e sanções sem qualquer preocupação com a realidade vivida e com as consequências econômicas dessas decisões⁵⁵.

5.6.6. Estratégia de Blindagem Patrimonial

A blindagem patrimonial nada mais é que levar para o âmbito da proteção pessoal o patrimônio do gestor público. É importante destacar que não apenas mecanismos lícitos são utilizados nesse intento, mas também de conduta ilícita utilizadas como modo de proteção, o que não deixa de pôr em risco aqueles que a utilizam.⁵⁶

Quando a proteção patrimonial é praticada com o intuito de fraude ou abuso de direito, pode-se ensejar a *desconsideração da personalidade jurídica*⁵⁷, de modo afetar o patrimônio do agente público ainda que em nome de outra pessoa física ou jurídica.

54. Sobre a Administração Multinível, são relevantes as considerações de Alexandra Leitão (LEITÃO, 2015, p. 45) e Carla Amado Gomes (GOMES, 2013, p. 275-288).

55. Aqui, relevante lembrar o modelo de regulação responsiva bem exposto por John Braithwaite e Ian Ayres no seu *Responsive regulation*, representado na “pirâmide de apoio” e na “pirâmide de sanção” (AYRES; BRAITHWAITE, 1992).

56. Sobre a blindagem patrimonial, destaca-se a análise de Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede, que tratam especificamente da blindagem patrimonial e planejamento jurídico (MAMEDE; MAMEDE, 2013).

57. A doutrina da desconsideração da personalidade jurídica (*desregard doctrine*, *desregard of legal entity* ou *lifting the corporate veil*) teve por marcos os casos *Bank of United States v.s. Deveau*, nos Estados Unidos, e *Salomon v.s. Salomon CO*, na Inglaterra. No Brasil, nosso direito positivo regrou o tema no art. 50 do Código Civil Brasileiro: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade

53. Sobre o ponto, são pertinentes as reflexões de Eurico Bitencourt Neto: “Justamente por ser informal, esse modo de atuação administrativa não possui fundamento em uma dada norma legal, trata-se de um agir fora dos limites da institucionalidade procedimental. Não obstante, não se trata de atuação ilícita, na medida que possui alguns fundamentos constitucionais gerais, sendo mencionados, nesse sentido, um dever geral de atuação administrativa, a imposição de participação dos cidadãos nos negócios públicos, uma obrigação de esclarecer amplamente as circunstâncias que conduzirão a uma decisão, além de um dever de se obter a melhor decisão possível. Em síntese, a atuação informal precisa estar lastreada em alguma norma jurídica, sob pena de invalidade” (BITENCOURT NETO, 2017, p. 333).

A figura da blindagem patrimonial tem larga utilização na iniciativa privada, podendo compreender a doação de bens em vida; a criação de *holding* familiar (TESSARI; PINHEIRO; MOREIRA, 2018); doação de bens com reserva de usufruto; a instituição de cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade.

O problema do controle disfuncional é que, em vez de implementar segurança jurídica e contribuir para a efetiva reparação do dano, contribui para insegurança jurídica e com a consequente impossibilidade de reparação do erário pelos danos causados pelos agentes públicos.

Quando estamos diante de estratégias ilegais e grosseiras de “blindagem patrimonial” como doação de bens a filhos, netos, pais ou pessoas que emprestam seu nome para a prática de negócio jurídico (conhecidos “laranjas”) é mais simples detectar a fraude à execução. Mas a constituição das *offshore companies* já implica maior grau de sofisticação, de modo a evitar sejam executados os bens dos seus beneficiários.

A utilização dessa estratégia antes mesmo de o agente público assumir qualquer cargo, é prova direta da atividade disfuncional do controle externo em nosso País. Afinal, se, antes mesmo de subscrever qualquer ato administrativo, o gestor tem plena noção de que seu patrimônio estará em risco, a ponto de desfazer-se ou

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Mas não apenas o Código Civil prevê as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Destacamos, ainda, o art. 28 do Código do Consumidor, o art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; O art. 134, VII, do Código Tributário Nacional – CTN; Igualmente, o art. 4º da Lei 9.605/98, que regra os crimes ambientais. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica no direito administrativo não encontra tratamento normativo explícito, mas pode ser aplicada em certas hipóteses como se deflui do art. 54 da Lei 8.666/93. O Projeto de Lei PL 6814/2017, que pretende substituir nossa atual Lei de Licitações, trata explicitamente do tema: “Art. 112 (...) § 15. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa, do mesmo ramo, com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório e a ampla defesa.” Embora a recepção da teoria da desconsideração seja um inegável avanço, não podemos perder de vista que os excessos na aplicação da teoria podem conduzir à fragilização dos direitos e das garantias individuais e mesmo ao próprio instituto da pessoa jurídica, levando a efeitos e resultados não desejados pelo sistema jurídico. A autonomia patrimonial em nosso sistema é regra, e não exceção. Assim, exige-se cuidado para não se subverter a regra da autonomia, sob o risco de fragilizar-se o desenvolvimento econômico e o livre mercado. Outro aspecto interessante é que somente aquele que perpetrar o abuso, fraude ou ato ilícito ou desvio de finalidade é que poderá ser penalizado com a desconsideração. Evidentemente, essas situações deverão estar caracterizadas ou, ainda, contar com fortíssimos indícios para que seja estendida, ainda que cautelarmente, a desconsideração.

proteger seu patrimônio antecipadamente, é porque algo está profundamente errado. Decorre dos imensos riscos em ordenar despesas públicas num contexto normativo e hermenêutico brasileiro.

5.7. Considerações finais: as estratégias de fuga da responsabilização são algo positivo ou negativo?

Uma vez expostas as estratégias de fuga da responsabilização, fundamental saber se realmente funcionam ou mesmo saber se isso é algo positivo ou negativo para a Administração Pública (HOOD, 2014).

A resposta é que podemos detectar tanto aspectos positivos como negativos. Por certo, em países com controles estatais rudimentares, ou gravemente ineficientes, as estratégias de fuga da responsabilização não são relevantes. Nesse caso, o problema é inverso: a falta de controle e a necessidade de se responsabilizar agentes públicos.

Já nos estados ocidentais com relativo avanço institucional em que são plenamente exercidos os poderes dos órgãos de controle, o problema passa a ter maior relevância, visto que, de regra, ninguém deseja ser responsabilizado por suas ações ou omissões. Mas, mesmo nesses países, pode existir aspectos desejáveis e salutar nas estratégias de fuga ou evasão de responsabilização, pois denotam constante preocupação do gestor com os órgãos de controle e, portanto, uma autofiscalização permanente, de modo a não incidir em qualquer ilegalidade ou estar sujeito às sanções decorrentes da inobservância da lei. Doutra banda, podem ser identificados inúmeros aspectos disfuncionais e mesmo ilegais na adoção de certas estratégias de fuga da responsabilização. Vejamos alguns dos seus efeitos positivos e negativos.

5.7.1. Efeitos positivos

Como *efeitos positivos* das estratégias de fuga da responsabilização podemos apontar a preocupação de o gestor público pensar de modo consequencialista sua decisão, o que, até certo ponto, é salutar. Desse modo, estratégias de manipulação com a constante informação dos meios de comunicação das ações administrativas podem deixar os cidadãos mais bem informados das decisões e programas governamentais. Ao chamar atenção para um problema, pode-se, inclusive, suscitar maiores questionamentos quanto à melhor forma de resolvê-lo. Por certo que certa dose de medo pode ter efeitos benéficos à boa gestão pública e para a proteção daqueles envolvidos no processo de tomada de decisão, afinal, parafraseando Dostoiévski, numa sociedade sem culpa, tudo é permitido.⁵⁸

58. Acerca dos efeitos benéficos do medo dos agentes públicos da sua responsabilização, vale transcrevermos as reflexões de Christopher Hood: “La culpa y el miedo a la culpa no son

Estratégias de delegação podem propiciar uma melhor divisão de responsabilidade dentro das organizações administrativas, pois, sabendo que quaisquer agentes podem ser responsabilizados, cada qual fará sua parte com maior atenção, evitando que sejam objeto de sanções por suas decisões.

Doutra banda, ao delegar tarefas para servidores de carreira, tem-se como natural consequência o incremento da gestão pública, que passa a agir de modo mais técnico, abrindo espaço para os gestores profissionais (HOOD, 2014, p. 209).

Ademais, se os agentes públicos tiverem a percepção de que estão colocados em certa posição para servirem de para-raios ou ímãs de responsabilização, poderão tomar maior cautela nos atos administrativos que subscreverem na condição de ordenadores de despesas, exigindo que o ato seja também avalizado por outros agentes públicos.

Já as estratégias defensivas no estabelecimento de certas políticas públicas podem evitar que certos danos sejam causados à coletividade, afinal, políticas que potencialmente impliquem riscos poderão ser evitadas, fortalecendo a ideia de prevenção na Administração Pública (HOOD, 2014, p. 210).

Já os efeitos negativos das estratégias de fuga da responsabilização têm aumentado drasticamente nos últimos anos, especialmente se considerarmos a crise da divisão das funções estatais, que já não podem ser explicadas ou estudadas sem levar em conta o acirramento dos conflitos entre os poderes instituídos e a ampliação da importância e autonomia das estruturas burocráticas.

5.7.2. Efeitos negativos

Entre os efeitos negativos, destacam-se nas estratégias de manipulação: i) o desvio da atenção do gestor, seja ele político, seja servidor de carreira com temas que não são fundamentais à boa administração pública, perdendo-se considerável tempo com temas que ocupam a mídia e não são prioritários. Também pode ser elencada como efeito negativo ii) a crescente valorização da aparência em detrimento da essência e de agentes menos preocupados em desincumbirem-se da sua

atividade técnica que em proteger-se no curso de sua carreira ou mandato. Também a centralização das informações e a constante preocupação e intimidação dos agentes públicos levam a uma péssima cultura organizacional e ambiente de trabalho (HOOD, 2014, p. 212).

Os efeitos negativos das estratégias de atuação podem implicar: i) excessiva pulverização das responsabilidades por delegação, o que leva a grandes dificuldades em responsabilizar os agentes que efetivamente causaram danos; ii) delegação da prestação de serviços públicos a particulares podem implicar maiores custos para a Administração (HOOD, 2014, p. 213-214); iii) escolha de um agente público “útere” para centralizar a culpa em lugar do superior hierárquico pode levar a uma falsa responsabilização de quem deveria ser o efetivo responsável; iv) recrutamento de cargos em comissão ou função de confiança com base na subserviência dos nomeados, em detrimento do talento e da meritocracia que deveria nortear aqueles que ocupam estas funções.

Além disso, podemos identificar dentre os efeitos negativos das estratégias de política pública: i) a excessiva protocolização e impessoalização da Administração Pública; ii) o não enfrentamento de temas relevantes que ficam permanentemente postergados para outras administrações, quer por impopularidade, quer pelo risco da atividade; iii) o crescimento do imobilismo decisório como forma de autoblindagem na política, na Administração Pública e nos órgãos de controle externo; iv) a substituição decisória externa do administrador pelo magistrado; v) a blindagem patrimonial antes mesmo de se assumir o exercício de função pública; vi) o incremento de uma cultura organizacional da mediocridade tem efeitos negativos devastadores, pois o fundamental não é bem administrar, mas bem proteger-se, pouco importando se o interesse público está sendo efetivamente atendido.

No balanço entre os aspectos positivos e negativos das estratégias de fuga aqui tratadas, certamente há aspectos muito mais negativos que positivos. De toda sorte, resta claro que as estratégias de fuga da responsabilização estão a ocupar a centralidade do processo de tomada de decisão na atualidade e nos colocam o desafio de pensar racionalmente esse fenômeno, buscando o avanço das instituições e fazendo a reflexão crítica sobre o modo de se exercer controle externo na atualidade.

del todo perjudiciales, si nos llevan a pensar dos veces antes de forzar o desobedecer reglas importantes, o qué decimos a quién, y como desarrollamos nuestras vidas personales. Un mundo sin culpa social o legal sería aquel en el que la única presión para mantenerse en el buen camino tendría que venir de las propias brújulas morales de los individuos, instrumentos notoriamente inestables. Sería un mundo en el que no habría sanciones por la desvergüenza. Aunque a menudo el mundo de la culpa pueda parecer poco atractivo, un mundo sin culpa también estaría lejos de hallarse libre de problemas. Imagínesse lo que sería conducir su coche en una sociedad en la que no hubiera culpa asociada a los errores o los accidentes de tráfico. Imagínesse cómo podrían comportarse quienes nos gobiernan en caso de que no tuvieran que temer ninguna culpa” (HOOD, 2014, p. 229).